課程名稱：刑法刑法29

00:00:06 - 00:00:08
來，我們今天有發一本小講義，同學有拿到了嗎？

00:00:09 - 00:00:09
有啊，有拿到了。

00:00:10 - 00:00:12
好，我們打開這本講義來看一下，這個是我們之前說要補、一直忘記的東西，我們來看一下。

00:00:16 - 00:00:21
那個我們先來看到行走的部分，我們先來看到行走的部分。

00:00:26 - 00:00:29
後面忘了標刑分，沒差啦，後面有些東西是刑分。

00:00:30 - 00:00:38
來，那個我們先來講一下這一本，因為這個東西是我的總複習講義，就是今年度那個總複習講義當中有一些新的東西。

00:00:38 - 00:00:43
那這些新的東西是我們課本改版之後，我才整理的。

00:00:43 - 00:00:45
所以那個在你們的課本當中沒有。

00:00:45 - 00:00:51
我們來看一下，第一個是第一大點，這邊以適性犯，限縮抽象危險犯的成立，這是第一點。

00:00:52 - 00:00:55
那這個東西啊，我之前大概跟同學口頭講過。

00:00:56 - 00:00:57
來，我跟你們講一下。

00:00:57 - 00:00:59
你們沒有帶行總的課本沒有關係。

00:00:59 - 00:01:00
我跟你們講一下。

00:01:00 - 00:01:00
教這個在哪裡。

00:01:15 - 00:01:20
這個東西的話是對照到你們的行總課本74到75頁。

00:01:21 - 00:01:21
你寫一下。

00:01:22 - 00:01:25
這個議題是對照到我們的刑總課本74到75頁。

00:01:25 - 00:01:30
也就是抽象危險犯的危險可不可以去個案推翻的問題。

00:01:30 - 00:01:32
這個問題，我的課本上面原本是列可推翻說跟不可推翻說。

00:01:35 - 00:01:38
那這兩說其實都有被學者批評啊。

00:01:38 - 00:01:43
因為可推翻說的問題是說，這樣可能會導致抽象危險犯變成具體危險犯。

00:01:43 - 00:01:47
而且這樣的話等於會讓被告為自己的無罪去負舉證責任，

00:01:47 - 00:01:48
這個會有一些問題存在。

00:01:49 - 00:01:55
而不可推翻說的話呢，它等於又會讓一些被告在完全沒有危險的個案當中要成立犯罪。

00:01:55 - 00:01:57
這個也會有違反罪責原則的問題。

00:01:58 - 00:02:00
所以目前比較流行的說法是這個。

00:02:00 - 00:02:03
說法，叫做以事證犯限縮抽象危險犯的成立。

00:02:03 - 00:02:06
這個說法也是目前實務見解所採的。

00:02:07 - 00:02:10
所以，原本我課本裡面有列一個可推翻說，

00:02:10 - 00:02:12
那個已經是舊的實務了。

00:02:12 - 00:02:16
現在的食物對於這種原本是抽象危險犯的犯罪,

00:02:16 - 00:02:21
現在的食物採的態度叫做用事性犯的觀點去解釋,

00:02:21 - 00:02:27
所以食物目前會說呢,我們就乾脆直接用實質性犯的觀點來限縮抽象危險犯的成立,

00:02:27 - 00:02:35
也就是在抽象危險犯的要件當中,加入這一個足以產生法益損害的要件,

00:02:35 - 00:02:38
加上這個要件,讓實質性犯呢變得沒有那麼容易成立。

00:02:38 - 00:02:40
所以在什麼犯罪可以用,

00:02:40 - 00:02:44
像比如說下面112年這一則,聚眾施暴罪,

00:02:44 - 00:02:46
這個判決我們課本裡面有,這個我們前面有講過。

00:02:47 - 00:02:52
還有的話呢,像第三頁110年度187號判決,

00:02:53 - 00:02:56
這一則判決在講的是誣告罪跟偽證罪。

00:02:56 - 00:03:01
所以偽證罪的話，實務見解認為說也可以用事性犯的觀點去做限縮。

00:03:01 - 00:03:03
我們知道啊，事性犯什麼意思？

00:03:03 - 00:03:06
要足以產生法益的危險，

00:03:06 - 00:03:07
這個叫做事性犯。

00:03:07 - 00:03:12
所以從事性犯的觀點來限縮偽證罪的話，結果會變成是這樣子喔。

00:03:12 - 00:03:13
各位想,

00:03:14 - 00:03:17
那個,從事性侵的觀點來講,

00:03:18 - 00:03:20
偽證罪啊,什麼樣的情況可以被排除掉?

00:03:20 - 00:03:23
好,比如說那個被告上法庭做了偽證,

00:03:23 - 00:03:26
但是呢,被告講的話實在是非常非常的可笑,

00:03:26 - 00:03:28
比如說這個被告跟法官說,

00:03:28 - 00:03:34
說對，我有看到被告，我有那個證人啊，證人跟法官說對，我有看到被告殺人,

00:03:34 - 00:03:38
但是啊，被告殺人前，突然有一個飛碟降落在被告的旁邊,

00:03:38 - 00:03:44
然後就兩個外星人，拿著那個很奇怪的外星武器抵著被告，逼著被告殺人，這個是我親眼看到的。

00:03:45 - 00:03:49
那這個證人講完之後，法官還一度懷疑說，剛剛叫他具結對不對？

00:03:49 - 00:03:51
就想說這個人是不是精神有問題

00:03:51 - 00:03:56
那這樣的人呢,他依照事性犯的觀點,就可以排除偽證罪的成立

00:03:56 - 00:03:59
因為這樣的偽證呢,完全不足以影響司法權的。

00:04:00 - 00:04:00
必做

00:04:00 - 00:04:01
這個是目前實務的看法。

00:04:02 - 00:04:02
好,

00:04:02 - 00:04:04
所以這個東西我大概簡單講到這,

00:04:04 - 00:04:05
判決我就不再去唸了。

00:04:06 - 00:04:07
接著來第四頁,

00:04:08 - 00:04:11
誤想偶然防衛有沒有過當這個問題。

00:04:12 - 00:04:12
好,

00:04:12 - 00:04:15
這個東西我記得之前有口頭跟同學講過。

00:04:16 - 00:04:18
那這個東西的位置啊,

00:04:19 - 00:04:20
我對照一下,

00:04:20 - 00:04:21
你們沒帶課本沒關係,

00:04:21 - 00:04:22
我跟你們講在哪裡。

00:04:23 - 00:04:26
這個東西的位置在137頁

00:04:26 - 00:04:28
137頁。

00:04:30 - 00:04:32
它在我們行走的137頁。

00:04:33 - 00:04:33
好。

00:04:33 - 00:04:34
在行走的137頁,

00:04:35 - 00:04:40
這邊談的問題是誤想防衛跟偶然防衛會不會有發生過當的問題。

00:04:41 - 00:04:42
我們在課本當中啊,

00:04:42 - 00:04:43
似乎認為是有。

00:04:43 - 00:04:44
那為什麼有人認為說,

00:04:45 - 00:04:46
誤傷會有過當。

00:04:46 - 00:04:47
我們先想誤傷的部分。

00:04:48 - 00:04:50
為什麼有人會認為說誤傷會有過當？

00:04:51 - 00:04:53
因為支持的人會覺得說啦,

00:04:53 - 00:04:55
誤傷防衛過當的人,

00:04:56 - 00:04:57
跟真正防衛過當的人,

00:04:58 - 00:05:00
他心理上的那個不安的感受,

00:05:01 - 00:05:03
他心理上的那種感覺是一樣的,

00:05:03 - 00:05:04
你可以想像吧,

00:05:04 - 00:05:05
到底是真的有人要攻擊我,

00:05:05 - 00:05:06
然後我防衛過當

00:05:07 - 00:05:08
還是我覺得有人要攻擊我

00:05:08 - 00:05:09
然後我防衛過當

00:05:10 - 00:05:11
不管是哪一種過當

00:05:11 - 00:05:12
對行為人來說

00:05:12 - 00:05:15
他那個心裡的不安緊張的情緒其實是一樣的

00:05:15 - 00:05:16
所以有人會認為說呢

00:05:16 - 00:05:18
誤想的過當確實可以避免。

00:05:19 - 00:05:22
可是現在反而比較多數的說法會認為說

00:05:22 - 00:05:23
也不能說多數了

00:05:23 - 00:05:26
現在有另外一派的說法認為，

00:05:26 - 00:05:27
誤想根本沒有過當。

00:05:28 - 00:05:29
另外一派，

00:05:29 - 00:05:31
就認為誤想根本沒有過當，

00:05:31 - 00:05:32
為什麼呢？

00:05:32 - 00:05:35
因為其實以前我大一的時候都聽過這個說法,

00:05:35 - 00:05:38
以前我大一的刑中老師啊,就跟我們講說,

00:05:38 - 00:05:39
誤想沒有過當,

00:05:39 - 00:05:41
如果你看到有學者說那個誤想有過當,

00:05:41 - 00:05:42
那你讀到腦子會壞掉。

00:05:43 - 00:05:44
大一的行中老師講話比較誇張,

00:05:44 - 00:05:47
但我就一直印象深刻嘛,就記到現在。

00:05:47 - 00:05:51
那時候不太懂老師為什麼講說勿想過當唸的腦子會壞掉,

00:05:51 - 00:05:53
後來看這個文章大概懂了啦,

00:05:53 - 00:05:55
因為有另外一派的學者會認為說,

00:05:55 - 00:05:56
防衛有沒有過當,

00:05:56 - 00:05:58
你要從客觀上的角度去認定,

00:05:59 - 00:06:00
也就是我

00:06:00 - 00:06:00
要比較的是防衛手段

00:06:02 - 00:06:05
跟客觀上的那個侵害,兩者去做相比

00:06:05 - 00:06:11
那誤想防衛的話，客觀上根本就沒有侵害存在，你要怎麼去比他有沒有過當？

00:06:11 - 00:06:13
瞭解吧，這個是一個技術面的理由啦。

00:06:13 - 00:06:15
那當然實質面的理由會認為說，

00:06:16 - 00:06:25
因為防衛過當的前面，除了行為人心理的這種負面情緒之外，還有一個更學理的理由是，因為客觀上真的有那個侵害存在。

00:06:26 - 00:06:27
那個才會構成前面的依據。

00:06:27 - 00:06:30
可是誤想的過當客觀上就沒有侵害

00:06:30 - 00:06:31
你跟他講蓋什麼

00:06:31 - 00:06:32
懂這意思嗎

00:06:32 - 00:06:35
所以另外一種說法,會認為說誤想防衛他根本就沒有過當

00:06:35 - 00:06:38
好,那偶然防衛會不會有過當

00:06:38 - 00:06:38
當然不會有

00:06:38 - 00:06:39
為什麼

00:06:39 - 00:06:43
因為我們講防衛過當的前面，必須符合這裡所謂雙重的全面

00:06:44 - 00:06:47
第一個是呢，客觀上真的有阻卻的情狀

00:06:47 - 00:06:50
第二個是行為人他真的面臨這樣的負面情緒

00:06:50 - 00:06:54
而這種案例當中，偶然防衛的過當，很明顯是怎麼樣

00:06:55 - 00:06:59
這個主觀上，他不覺得他有那樣的情緒嘛，對不對

00:06:59 - 00:07:04
主觀上行為人，他不覺得他正當防衛，他根本沒有面臨這種驚恐慌亂的情緒

00:07:05 - 00:07:09
所以這樣的案例當中呢，當然沒辦法適用防衛過當的前面

00:07:09 - 00:07:09
好

00:07:09 - 00:07:11
好，所以這個東西補充給大家

00:07:11 - 00:07:12
再來第五頁呢，第三大點

00:07:13 - 00:07:16
間接正犯當中的支配行為錯誤

00:07:16 - 00:07:19
這個東西也是我前面口頭有講過的

00:07:19 - 00:07:20
那你這邊寫一下

00:07:21 - 00:07:22
這個東西我們放在

00:07:23 - 00:07:24
我看一下這個在哪裡

00:07:27 - 00:07:28
哦

00:07:28 - 00:07:29
這個東西你寫一下，課本296頁

00:07:30 - 00:07:32
行蹤，一樣行蹤，296頁

00:07:34 - 00:07:39
他所對應的是296頁裡面阿拉伯數字4的那種類型

00:07:40 - 00:07:43
誤以為被利用人沒有故意，實際上是有的

00:07:44 - 00:07:45
他對應的是那個類型

00:07:45 - 00:07:47
這個是今年許大老師最新的文章

00:07:49 - 00:07:50
好

00:07:50 - 00:07:54
間接正犯，如果行為人發生利用行為錯誤

00:07:54 - 00:07:55
這個是什麼意思

00:07:56 - 00:08:00
我們第四種類型，我再講一次，它的標題說誤以為被利用人沒有故意

00:08:00 - 00:08:01
一般預計上是有的。

00:08:02 - 00:08:04
這一則案例簡單說就這樣了。

00:08:04 - 00:08:09
行為人他想利用一個無辜的工具人去毒殺被害人。

00:08:10 - 00:08:13
可是行為人的計倆根本就已經被那個工具人看穿了。

00:08:14 - 00:08:16
而工具人看穿行為人的計倆之後，

00:08:16 - 00:08:18
他沒有去識破行為人，

00:08:18 - 00:08:20
因為工具人剛好也想殺那個被害人。

00:08:21 - 00:08:22
所以工具人就決定順水推舟,

00:08:22 - 00:08:24
就乾脆當作自己不知道,

00:08:24 - 00:08:26
繼續去完成那個犯罪計畫。

00:08:27 - 00:08:28
他在講的是這種典型,

00:08:28 - 00:08:28
OK嗎?

00:08:28 - 00:08:30
這個我記得課之前我課本有講

00:08:30 - 00:08:31
課程當中我講過嘛

00:08:32 - 00:08:34
我說這個典型聽起來很像那種本土劇的劇情有沒有

00:08:34 - 00:08:36
好像新玫瑰瞳鈴眼都演過這種東西。

00:08:37 - 00:08:37
這種案例

00:08:38 - 00:08:39
我先講林雄老師的操作。

00:08:40 - 00:08:42
我們之前的黑板上曾經畫過一個圖，

00:08:42 - 00:08:46
說林雄老師認為間接正犯跟教唆犯是一種包含的關係。

00:08:46 - 00:08:48
所以在這種案例當中，

00:08:48 - 00:08:51
客觀上沒有支配的事實。

00:08:51 - 00:08:54
而行為人主觀上有支配的意思,

00:08:54 - 00:08:56
所以這種案情如果照林雄老師的說法,

00:08:56 - 00:09:00
因為間接正犯的支配要件沒有被滿足的關係,

00:09:00 - 00:09:01
所以這個時候可以怎麼樣呢?

00:09:02 - 00:09:04
退而求其次改論教唆犯

00:09:04 - 00:09:05
林雄老師這樣論嘛，

00:09:05 - 00:09:05
對不對？

00:09:05 - 00:09:06
好，

00:09:06 - 00:09:08
那我們來看一下許恆達老師他提出了什麼的說法呢？

00:09:10 - 00:09:11
這裡。

00:09:11 - 00:09:12
這篇文章寫的還蠻細的。

00:09:13 - 00:09:13
括號二，

00:09:13 - 00:09:14
我們來看喔。

00:09:15 - 00:09:17
假交付毒針，並且囑託施打的行為，

00:09:18 - 00:09:21
可不可以成立殺人罪的間接正犯？

00:09:23 - 00:09:25
可不可以論殺人罪的間接正犯？

00:09:25 - 00:09:26
那個講義，

00:09:26 - 00:09:28
剛剛才進來的同學記得去領。

00:09:29 - 00:09:29
三，

00:09:29 - 00:09:31
這個記得去領。

00:09:32 - 00:09:33
那個括號二這邊,

00:09:34 - 00:09:35
來，這種情況可不可以論間接正犯？

00:09:36 - 00:09:38
多數說認為不行的。

00:09:38 - 00:09:39
多數說認為不行，

00:09:39 - 00:09:39
為什麼？

00:09:39 - 00:09:41
因為客觀上沒有支配的事實,

00:09:41 - 00:09:42
瞭解嗎?

00:09:42 - 00:09:43
客觀上並沒有支配的事實。

00:09:44 - 00:09:47
但是這裡有少數說是德國的少數說,

00:09:47 - 00:09:50
德國的少數說認為可以

00:09:50 - 00:09:51
德國少數說認為可以。

00:09:51 - 00:09:53
因為德國的少數說認為，

00:09:53 - 00:09:56
啊有沒有真的支配的事實沒有那麼的重要。

00:09:56 - 00:09:57
有這樣的少數說，

00:09:57 - 00:09:58
但是通說沒有採。

00:09:58 - 00:10:00
因為通說認為

00:10:00 - 00:10:04
認為說,如果你客觀上就沒有支配事實的話,那就會叫間接正犯。

00:10:04 - 00:10:05
通說這樣認定的哈。

00:10:06 - 00:10:15
所以這裡的話呢,括號29頁,照德國通說的看法,這種情況不能成立殺人罪的間接正犯。

00:10:15 - 00:10:15
來。

00:10:15 - 00:10:19
那這裡可不可以改論間接正犯的未遂？

00:10:20 - 00:10:26
因為你們想這種案情喔，客觀上沒有支配的事實，可是主觀上有支配的意思，對吧？

00:10:26 - 00:10:28
客觀上沒有那個事實，主觀上有那個意思。

00:10:29 - 00:10:30
邏輯上來說說未遂。

00:10:30 - 00:10:34
對啊，所以這一種案例確實有機會改論間接正犯的未遂。

00:10:35 - 00:10:37
可是，許恆達老師認為不能這樣論，為什麼？

00:10:38 - 00:10:42
因為許恆達老師對間接正犯的著手，他採的是比較偏客觀說的見解。

00:10:43 - 00:10:44
依照許老師的說法。

00:10:45 - 00:10:47
左手，他不採主客觀說啦。

00:10:48 - 00:10:51
他比較傾向那個實質客觀說，要有法益的危險發生。

00:10:51 - 00:10:57
而在間接正犯裡面，許恆達老師所採的著手理論，也是類似這樣的立場。

00:10:57 - 00:11:00
認為說要真的有法益侵害的發生。

00:11:00 - 00:11:03
法益危險的發生，這時候才能認為有著手。

00:11:03 - 00:11:07
所以這種案例當中，許老師的看法，簡單說他的意思就是。

00:11:08 - 00:11:08
呃

00:11:09 - 00:11:11
行為人固然有一個利用行為存在。

00:11:12 - 00:11:15
可是他的利用行為馬上被工具人識破。

00:11:15 - 00:11:20
後來工具人雖然真的有去做某些不該做的事，可是那是工具人他自己的犯意。

00:11:21 - 00:11:23
行為人原本的利用行為已經斷掉了。

00:11:23 - 00:11:24
知道嗎？已經斷掉了。

00:11:24 - 00:11:29
所以許老師認為根本就沒有間接正犯的著手。

00:11:29 - 00:11:29
好。

00:11:30 - 00:11:32
所以間接正犯不能成立。

00:11:32 - 00:11:33
既遂不能成立嘛。

00:11:33 - 00:11:33
因為客觀上沒有事實嘛。

00:11:34 - 00:11:36
未遂也不能成立，因為他沒有著手。

00:11:36 - 00:11:37
好，那怎麼辦呢？我們翻到第六頁。

00:11:40 - 00:11:40
好。

00:11:40 - 00:11:42
那第六頁這邊，我們接著往下看。

00:11:43 - 00:11:46
那假若上述的行為可不可以改論教唆犯呢？

00:11:47 - 00:11:48
林玉雄老師認為可以。

00:11:49 - 00:11:51
林玉雄老師認為說這種情況要改論殺人罪的教唆犯。

00:11:52 - 00:11:55
但是許恆達老師在文章裡面對這個看法提出了他的不同理解。

00:11:56 - 00:11:58
其實這個問題，我以前也想過。

00:11:58 - 00:11:59
但這時候覺得很怪，就沒有繼續。

00:12:00 - 00:12:01
去往下想。

00:12:01 - 00:12:02
因為你知道嗎？

00:12:02 - 00:12:06
你如果真的要說間接正犯跟教唆犯是一種包含的關係，

00:12:07 - 00:12:09
而間接正犯因為某些要件不能滿足，

00:12:09 - 00:12:11
我們就改論教唆犯的話。

00:12:12 - 00:12:13
其實會遇到一個問題喔,

00:12:13 - 00:12:14
間接正犯跟教唆犯,

00:12:15 - 00:12:16
他們真的有在要件上包含嗎?

00:12:17 - 00:12:18
你們想一下這件事,

00:12:18 - 00:12:21
間接正犯跟教唆犯的要件真的有包含嗎?

00:12:22 - 00:12:23
其實好像沒有欸,

00:12:23 - 00:12:23
為什麼?

00:12:24 - 00:12:24
好,

00:12:24 - 00:12:26
比如說你看教唆犯是不是有個要件叫共犯從屬?

00:12:27 - 00:12:28
間接正犯沒有,

00:12:28 - 00:12:29
對吧？

00:12:29 - 00:12:30
所以他們哪有包含？

00:12:31 - 00:12:31
對不對？

00:12:32 - 00:12:33
他們根本沒有包含啊。

00:12:33 - 00:12:35
你如果要講他們是包含的話，

00:12:36 - 00:12:38
這裡的包含也是非常非常抽象的層次,

00:12:38 - 00:12:40
不法內涵高低的包含。

00:12:41 - 00:12:42
它最多隻是這樣子而已。

00:12:42 - 00:12:43
就具體的要件來說,

00:12:43 - 00:12:44
這兩者沒有包含啊。

00:12:45 - 00:12:45
知道吧？

00:12:45 - 00:12:47
所以這個學老師說，

00:12:48 - 00:12:48
這時候，

00:12:49 - 00:12:51
也不適合論教唆犯。

00:12:51 - 00:12:51
好。

00:12:51 - 00:12:52
那可不可以論幫助犯？

00:12:54 - 00:12:54
對啊，

00:12:54 - 00:12:55
幫助犯。

00:12:55 - 00:12:56
幫助犯一樣會有問題。

00:12:56 - 00:12:57
為什麼？

00:12:57 - 00:13:04
因為行為人主觀上根本就沒有認識到說這個正犯會從事一個不法的行為。

00:13:05 - 00:13:06
反而行為人覺得怎麼樣？

00:13:07 - 00:13:08
工具人沒有故意,

00:13:08 - 00:13:09
對不對？

00:13:09 - 00:13:10
但事實上呢,

00:13:10 - 00:13:11
工具人有故意啊。

00:13:12 - 00:13:13
所以如果你要論幫助犯的話，

00:13:14 - 00:13:15
幫助犯有幫助故意，

00:13:16 - 00:13:18
幫助故意是行為人要認知到那個正犯要實施不法行為。

00:13:19 - 00:13:20
可是這個行為人所認知當中，

00:13:21 - 00:13:22
正犯是怎麼樣？

00:13:22 - 00:13:23
盲目的工具啊，

00:13:23 - 00:13:24
沒有故意啊，

00:13:24 - 00:13:24
對不對？

00:13:24 - 00:13:25
所以幫助犯也不能論。

00:13:25 - 00:13:27
於是最後只能論什麼呢？

00:13:27 - 00:13:28
過失正犯。

00:13:29 - 00:13:29
很特別喔，

00:13:30 - 00:13:31
最後只能論過失正犯。

00:13:32 - 00:13:38
所以你會發現，許老師在這篇文章當中，幾乎等於是窮盡地檢討了各種不同的犯罪類型。

00:13:39 - 00:13:41
這個東西我在今年的集訓班有考過,

00:13:41 - 00:13:43
那很多同學是缺乏這個問題意識,

00:13:44 - 00:13:47
很多同學是直接說行為人成立

00:13:48 - 00:13:50
那個殺人罪的間接正犯,

00:13:51 - 00:13:54
就不對，因為間接正犯它不可能會積累。

00:13:54 - 00:13:56
至少照通說的看法，不可能會積水。

00:13:56 - 00:14:00
然後這個題目當中，我們當然也不可能論直

00:14:00 - 00:14:00
接正犯。

00:14:01 - 00:14:03
因為他中間透過一個工具人嘛，他也不可能論直接正犯，所以你看喔。

00:14:05 - 00:14:07
直接正犯不可能。

00:14:08 - 00:14:09
間接正犯也不可能。

00:14:09 - 00:14:13
共同正犯不用檢討，因為共同不起來，教唆犯要件不符。

00:14:14 - 00:14:15
幫助犯要件也不符，最後剩什麼？剩過失正犯。

00:14:19 - 00:14:21
提醒各位一件事，這個以前我們前面已經有講過哈。

00:14:24 - 00:14:24
過失犯。

00:14:26 - 00:14:28
過失犯，沒有正犯共犯的區分。

00:14:28 - 00:14:28
還記得嗎？

00:14:30 - 00:14:34
過失犯當中，就算是行為人透過別人來實現犯罪。

00:14:34 - 00:14:36
行為人一樣論的是正犯喔。

00:14:37 - 00:14:39
記得喔，過失犯他並沒有正犯共犯的區分。

00:14:39 - 00:14:45
所以這種情況呢,我們最後不得已,只好論行為人過失正犯,好,只能論過失正犯。

00:14:49 - 00:14:50
我們學到這邊了。

00:14:51 - 00:14:54
你不要再跟我講說,他是故意的,他怎麼可以論過失。

00:14:55 - 00:14:56
不要有這種想法,好嗎?

00:14:56 - 00:14:58
故意跟過失是包含的。

00:14:59 - 00:15:01
有故意的人當然一定也會有過失。

00:15:01 - 00:15:02
你不要被條文騙了，好嗎？

00:15:03 - 00:15:04
真的啦。

00:15:04 - 00:15:07
就一定會有人問我說，他是故意的，他怎麼會是過失的。

00:15:07 - 00:15:10
不要這種白爛的想法，有故意的人，他一定有過失，好不好，這兩者是包含的喔。

00:15:13 - 00:15:14
好，再來第七頁這邊。

00:15:16 - 00:15:18
放火燒毀建築物的判斷。

00:15:19 - 00:15:22
這個問題，是去年徐玉安老師的一篇文章。

00:15:23 - 00:15:26
談到那個放火罪到底什麼時候才既遂。

00:15:26 - 00:15:27
因為這問題是這樣子。

00:15:28 - 00:15:30
我們前面在講放火的既遂。

00:15:30 - 00:15:31
通說採的像什麼說法？

00:15:33 - 00:15:34
效用喪失說，對不對？

00:15:35 - 00:15:38
那我是不是跟各位分享過一個以前我處理過的案件。

00:15:38 - 00:15:41
就是行為人去放火去燒被害人的農舍。

00:15:42 - 00:15:45
那個農舍已經被燒得亂七八糟，面目全非。

00:15:45 - 00:15:46
但主結構還在。

00:15:47 - 00:15:49
所以我成功把他辯護成未遂。

00:15:49 - 00:15:50
然後那個刑度被砍了一半以上。

00:15:50 - 00:15:51
我這麼講過這個案例，好像有嘛，對不對？

00:15:53 - 00:15:56
那個案例，就是原本的書見解，它不可理解的地方。

00:15:58 - 00:16:00
因為我以前也跟各位講過。

00:16:00 - 00:16:00
當我們才用效用喪失說來理解放火罪的既遂的話

00:16:04 - 00:16:05
那你要知道啊

00:16:05 - 00:16:09
現在這個年代的建築物九成以上都是鋼筋水泥的建築物

00:16:10 - 00:16:12
鋼筋水泥要怎麼燒到效用喪失

00:16:14 - 00:16:15
嘗試上你要知道

00:16:15 - 00:16:17
鋼筋水泥這種東西是燒不起來的

00:16:18 - 00:16:19
瞭解吧

00:16:19 - 00:16:20
那個東西是燒不起來的啊,真的啦

00:16:21 - 00:16:22
不信啊

00:16:22 - 00:16:25
你等一下下課拿打火機去燒我們的柱子，你看燒得起來燒不起來

00:16:26 - 00:16:29
也不對，你不能這樣做，你這樣做可能會燒到其他可燃物

00:16:29 - 00:16:31
不行，我這樣教說你放火，不可以

00:16:32 - 00:16:36
就你可以想像啦，或者你問AI啦，真的啦，鋼筋水泥是燒不起來的

00:16:36 - 00:16:41
那你說為什麼有的火，有的住宅的火災火還會燒那麼大

00:16:41 - 00:16:43
因為住宅裡面有其他的可燃物

00:16:43 - 00:16:46
那是吧，比如說沙發裝潢傢俱什麼木造的裝潢什麼的

00:16:46 - 00:16:48
燒得起來的是那些東西

00:16:48 - 00:16:56
所以你知道嗎，鋼筋水泥的住宅，它那個鋼筋水泥的結構本體，不可能被燒到壞掉，不可能

00:16:56 - 00:16:59
那鋼筋水泥的住宅要因為

00:17:00 - 00:17:02
火災而結構受損

00:17:02 - 00:17:03
往往是這樣子

00:17:03 - 00:17:05
就是它裡面有可燃物

00:17:05 - 00:17:07
裡面的可燃物它一直燒

00:17:08 - 00:17:10
造成鋼筋水泥的溫度也增加

00:17:10 - 00:17:14
那鋼筋水泥的溫度增加之後,水泥裡面的含水成分被蒸發

00:17:15 - 00:17:16
然後水泥就乾掉就剝落

00:17:17 - 00:17:20
然後鋼筋因為一直在高溫的環境之下,它就變得扭曲變形

00:17:21 - 00:17:22
它都是這樣漸漸造成的

00:17:22 - 00:17:22
知道嗎

00:17:22 - 00:17:24
所以你會發現,貫徹原本的看法的話

00:17:24 - 00:17:27
鋼筋水泥的建築物你要去燒它,真的很難遂啦

00:17:28 - 00:17:29
所以許老師在這裡呢

00:17:30 - 00:17:31
第二點這邊,他提出的一個說法是這樣

00:17:35 - 00:17:36
他認為呢

00:17:36 - 00:17:38
效用喪失，我們從現在的

00:17:39 - 00:17:41
鋼筋水泥為主的建築物來看的話

00:17:41 - 00:17:43
我們應該做一些的放寬

00:17:44 - 00:17:47
所以這邊講，建築物燃燒殆盡或崩塌，對這個是既遂

00:17:47 - 00:17:52
第二點，建築物因燃燒而喪失效用的話，這個也是既遂，沒有錯。

00:17:53 - 00:17:53
然後啊

00:17:55 - 00:17:56
還有一種情況

00:17:56 - 00:17:57
第八頁這邊

00:17:57 - 00:18:00
建築物的重要部分因燃燒

00:18:00 - 00:18:00
導致他的預期效應嚴重減損者。

00:18:04 - 00:18:12
所以如果照許玉安老師這個看法的話，我去年處理，不是去年啦，我前幾年處理的那個案件，計算法會是計稅喔，雖然結構本體還在，但那個裡面的裝潢燒得面目全非，全部變黑色，根本沒辦法住人了，這種案例，如果照許老師的說法，會是計稅，懂嗎，會是計稅。

00:18:24 - 00:18:28
所以還好我辦那案件的時候，許老師還沒有寫這篇文章。

00:18:29 - 00:18:34
如果這個我，我這樣說啦，就是從許理的觀點，許老師的說法可採。

00:18:35 - 00:18:39
對啊，不然就像我說的嘛，現在鋼筋水泥的建築物，你要怎麼給他燒到計稅，超難，對不對。

00:18:40 - 00:18:42
從許理的看法來說，這個說法合理。

00:18:43 - 00:18:51
但是在前面我處理案件，因為我的角色是辯護人，我希望被告可以越輕越好，所以在那個案件當中，我當然不會支持這樣的看法。

00:18:51 - 00:18:53
大概是這樣了，角色的衝突嘛。

00:18:53 - 00:18:53
像好像

00:18:55 - 00:18:58
以前大學的時候，學那個著作權法。

00:18:59 - 00:19:00
著作權法我

00:19:00 - 00:19:01
我知道這個現在還是不是爭議。

00:19:01 - 00:19:06
反正至少在我大學的時候啦，當時有人在探討我說，那A片要不要受到著作權法的保護。

00:19:07 - 00:19:08
然後有人就這樣回答，很有趣。

00:19:09 - 00:19:14
就有人說，這個身為一個法律人，我覺得A片要受著作權法的保護。

00:19:15 - 00:19:17
但身為男人呢,我不贊成。

00:19:17 - 00:19:20
因為如果受權法的保護的話,那以後網路上面沒有免費的一片可以看的。

00:19:21 - 00:19:22
也很合理,對不對,角色的衝突。

00:19:23 - 00:19:25
好,所以接著我們來往下看,第八頁這邊。

00:19:27 - 00:19:28
虐童相關的修法。

00:19:28 - 00:19:30
那個殺人罪照到的話。

00:19:30 - 00:19:32
第一個是272之一。

00:19:32 - 00:19:35
這個，這個沒有什麼特別要說的啦，就莫名其妙的修法。

00:19:37 - 00:19:40
我覺得以現在立法院那種可笑的程度，會不會過幾天他們就突然通過一個法案說什麼，隨機殺人也要判死刑。

00:19:45 - 00:19:46
我覺得不無可能。

00:19:46 - 00:19:47
因為我跟你們講。

00:19:48 - 00:19:53
272之1這種立法，你看喔，他第一項說對未滿七歲的人犯271，加重其刑二分之一。

00:19:54 - 00:19:59
第二項說對未滿七歲的人以凌虐的方式犯271，除死刑或無期徒刑。

00:20:00 - 00:20:00
這種立法吼

00:20:02 - 00:20:03
很久以前

00:20:03 - 00:20:05
馬英九執政的時代

00:20:05 - 00:20:06
那個誰

00:20:06 - 00:20:06
蔡正元

00:20:06 - 00:20:07
你們知道這位立委嗎

00:20:07 - 00:20:09
我超討厭他

00:20:09 - 00:20:09
那個時候我去投罷免他的票

00:20:09 - 00:20:10
但後來罷免沒有過

00:20:11 - 00:20:12
蔡正元

00:20:12 - 00:20:14
以前蔡正元就提過類似的法案

00:20:15 - 00:20:17
可是以前他們那些立委還是有一些底線

00:20:17 - 00:20:19
他們可能也知道說其實這個法案是有問題的

00:20:20 - 00:20:22
所以當初就是有提

00:20:22 - 00:20:25
然後有提之後呢，就片刻停留兩片刻

00:20:25 - 00:20:27
久了之後呢，就沒有下文了

00:20:27 - 00:20:28
沒有真的通過

00:20:28 - 00:20:29
現在立法院是

00:20:30 - 00:20:32
這種荒謬的法案，他們提他們真的要讓他過

00:20:32 - 00:20:33
直接就三讀了

00:20:33 - 00:20:33
對啊

00:20:34 - 00:20:36
這個法案，為什麼說它荒謬

00:20:37 - 00:20:38
你想

00:20:39 - 00:20:42
為什麼殺小孩要判得特別重

00:20:44 - 00:20:45
德國刑法沒有類似的規定

00:20:46 - 00:20:47
德國刑法沒有啊

00:20:48 - 00:20:51
為什麼殺小孩要判得特別重

00:20:52 - 00:20:52
呃

00:20:54 - 00:20:55
那你就想

00:20:55 - 00:20:57
刑法理由當中大概有提到說

00:20:58 - 00:21:00
那行為人跟小孩怎麼會有仇

00:21:00 - 00:21:03
你沒有仇去殺別人，就應該判得比較重

00:21:03 - 00:21:05
可是沒有仇去殺別人,不見得是殺小孩啊

00:21:06 - 00:21:08
沒有仇去殺別人,隨機殺人是不是也算

00:21:09 - 00:21:09
對啊,也是啊

00:21:10 - 00:21:12
那你這個加重就是恣意嘛

00:21:13 - 00:21:13
好,再來

00:21:14 - 00:21:16
還有一種很通俗的說法是覺得說

00:21:17 - 00:21:19
小孩還那麼年輕,你把他殺了

00:21:19 - 00:21:22
等於強制他才剛進入人生,就把他人生登出

00:21:23 - 00:21:24
就有一種這樣的說法嘛

00:21:25 - 00:21:27
所以就覺得小孩的命原本可以活到七八十歲

00:21:27 - 00:21:30
你在他才幾歲,就把他給殺了

00:21:30 - 00:21:31
他的人生就沒了

00:21:32 - 00:21:34
如果你要這樣講很危險

00:21:34 - 00:21:36
因為如果你要這樣講的話

00:21:36 - 00:21:38
那等於是你承認生命是有價值的

00:21:39 - 00:21:43
那如果你要照這個說法，小孩的餘命還那麼長，你就把他給殺了，所以要判得特別重。

00:21:44 - 00:21:45
那殺老人是不是要減輕？

00:21:46 - 00:21:47
反過來講，不就變這個意思嗎？

00:21:48 - 00:21:51
你殺死一個老人，殺死一個末期病患，反正他本來就沒有什麼期待的餘命了。

00:21:52 - 00:21:53
所以是不是反而要減輕？

00:21:53 - 00:21:55
因此為什麼德國刑法沒有類似這樣的規定

00:21:56 - 00:22:00
因為如果你說殺小孩要加重的話，那等於是給生命貼標價

00:22:00 - 00:22:00
會有這樣的危險，知道嗎？所以德國刑法真的沒有類似的規定，這個規定吼，

00:22:05 - 00:22:06
就真的很莫名，然後我提醒你們注意一件事，

00:22:08 - 00:22:10
272之一，你對照272，他有一個不同的地方。

00:22:14 - 00:22:18
你們看法條，272之一跟272，他有一個不同的地方。

00:22:35 - 00:22:37
來，272是怎麼加重？

00:22:37 - 00:22:38
你看條文。

00:22:39 - 00:22:44
加重其刑至二分之一，有沒有看到這個「至」字？對，沒錯，加重其刑至二分之一。

00:22:45 - 00:22:47
可是272之一的第一項，它是什麼？

00:22:48 - 00:22:50
加重其刑二分之一，有沒有「至」字差很多。

00:22:53 - 00:22:58
加重其刑「至」二分之一的意思是，你一定要加重。

00:22:59 - 00:23:03
最多加重到二分之一，他那個「至」是至多的意思，知道嗎？

00:23:04 - 00:23:07
一定要加重，加重的上限是二分之一。

00:23:07 - 00:23:13
所以各位，殺直系親屬的人，法院判他十年一個月合不合法？

00:23:13 - 00:23:15
合法，因為有加了。

00:23:15 - 00:23:18
知道嗎？因為殺害尊親屬是加重其刑至二分之一。

00:23:18 - 00:23:21
有至的意思就是一定要加。

00:23:21 - 00:23:22
加多少不管。

00:23:23 - 00:23:24
上限二分之一，知道嗎？

00:23:24 - 00:23:25
這是這個意思,所以殺尊親屬的人法院判他十年又一個月,可以哦,這是合法的哦。

00:23:30 - 00:23:32
可是272之一吼,

00:23:32 - 00:23:34
他說加重其刑二分之一,他沒有至字。

00:23:35 - 00:23:38
所以代表這一條罪的刑度是多少起跳?

00:23:39 - 00:23:41
就是15年起跳。

00:23:41 - 00:23:43
因為10的二分之一是五嘛。

00:23:44 - 00:23:45
所以加二分之一就15嘛。

00:23:46 - 00:23:47
這一條罪是15年起跳，知道嗎？

00:23:48 - 00:23:50
所以有沒有『至』字差很多，原本我們刑法幾乎都是用加重其刑至二分之一。

00:23:54 - 00:23:59
可是立法者就他們就是，怎麼說啊，蓄意。

00:24:00 - 00:24:01
他們就是覺得重刑化才爽

00:24:01 - 00:24:02
他們就這樣想

00:24:03 - 00:24:03
他們就覺得寫制

00:24:04 - 00:24:04
法官都不加重

00:24:05 - 00:24:05
太可惡了

00:24:05 - 00:24:06
所以就要把「致」拿掉

00:24:06 - 00:24:07
那加重其刑二分之一

00:24:08 - 00:24:08
他們才滿足

00:24:08 - 00:24:09
大概是這樣子。

00:24:10 - 00:24:10
好

00:24:10 - 00:24:11
然後傷害罪章的話,

00:24:12 - 00:24:14
那個虐童的部分也是啦,

00:24:14 - 00:24:17
就是刑度統一的都往上拉,

00:24:17 - 00:24:17
大概是這樣子。

00:24:18 - 00:24:18
好。

00:24:18 - 00:24:20
那這一份補充講義我就講到這邊,

00:24:20 - 00:24:22
這個以後你也不用特別去帶了,

00:24:22 - 00:24:23
反正該講的,

00:24:23 - 00:24:24
我大概都說了。

00:24:24 - 00:24:25
接著來,

00:24:25 - 00:24:26
我們接著上個禮拜的進度。

00:26:00 - 00:26:01
主觀構成要件，對不對？這個所謂主觀構成要件。

00:26:01 - 00:26:07
所以比如說嘛，我以前講過啊，男女朋友，他們相約玩性虐待的遊戲。

00:26:07 - 00:26:09
那女生是完全同意的。

00:26:09 - 00:26:12
但女生配合演出，演得好像一副被強姦的樣子。

00:26:12 - 00:26:14
那男生女生後來覺得都好爽。

00:26:14 - 00:26:16
這樣子的話，男生會不會該當221？

00:26:17 - 00:26:17
我會啊，為什麼？

00:26:18 - 00:26:19
啊沒有違反他意願嘛，對不對？

00:26:19 - 00:26:29
所以我們講啊，性行為，如果有經過被害人的同意的話，這時候因為他已經不違反意願了，所以這個時候呢，性犯罪就不會成立，這個是必然的。

00:26:30 - 00:26:30
好。

00:26:31 - 00:26:35
那麼接下來的問題是，這個同意要怎麼樣才可以正確構成要件。

00:26:36 - 00:26:41
因為同意不可能完全沒有限制嘛，你不可能說只要有一個同意的外觀就夠了，不可能嘛。

00:26:42 - 00:26:44
如果有人拿著刀逼著你，

00:26:44 - 00:26:44
然後你同意。

00:26:44 - 00:26:46
你不會說這個叫同意啊，對不對？

00:26:46 - 00:26:50
所以我們這裡會談，怎樣的同意才算是一個有效的同意呢。

00:26:50 - 00:26:54
這裡我們主要會把問題放在詐術之下的同意。

00:26:56 - 00:26:58
詐術或者是意思表示錯誤都有可能。

00:26:58 - 00:26:58
我們來看一下詐。

00:27:00 - 00:27:03
術下的同意，會不會是一個有效的同意呢？

00:27:03 - 00:27:07
這裡多數說，採的叫做法益關聯性理論。

00:27:07 - 00:27:11
這個法益關聯性理論，他會這樣子做區分。

00:27:13 - 00:27:14
他會這樣子做區分。

00:27:14 - 00:27:14
我們來看到325到326頁這邊。

00:27:19 - 00:27:24
這裡說，跟法義相關的欺騙，承諾是無效的。

00:27:24 - 00:27:29
反過來說，如果是跟法義無關的欺騙，這個承諾是有效的。

00:27:30 - 00:27:33
所以我們這裡，要來跟各位講一下，什麼叫做法義相關的欺騙。

00:27:33 - 00:27:36
什麼叫做法義無關的欺騙。

00:27:36 - 00:27:40
這個東西是很多同學學到後面根本就沒有搞懂的東西。

00:27:40 - 00:27:44
所以我到底跟各位講，什麼叫法益相關，什麼叫做法益無關。

00:27:46 - 00:27:46
我們這樣說。

00:27:47 - 00:27:49
我們從日常生活的觀點來講。

00:27:49 - 00:27:51
當你被騙去做一件事情的時候。

00:27:52 - 00:27:54
其實會有兩種不同的情況。

00:27:55 - 00:27:57
第一種情況是，你連做了什麼事都被騙。

00:27:58 - 00:27:59
這是第一種。

00:28:00 - 00:28:07
第二種情況是，你做的事情本身沒有被騙，你被騙的是做了這件事之後可以得到什麼東西，那個部分被騙。

00:28:08 - 00:28:09
有感覺嗎？

00:28:09 - 00:28:12
第一個，是事情本身喔，你連自己在做什麼都被騙。

00:28:14 - 00:28:21
第二種情況是,你在做什麼沒有被騙,但是你被騙的是呢,做了之後可以得到什麼東西。

00:28:23 - 00:28:26
我這邊找一個影片,給同學看一下。

00:28:41 - 00:28:43
來來,我給你們看一個影片哦。

00:28:44 - 00:28:46
嗯,騙狗吃蔬菜。

00:28:46 - 00:28:47
這樣你們應該看得到。

00:28:48 - 00:28:51
或者是你們自己去搜尋應該會有。

00:28:53 - 00:28:54
我們看一下。

00:28:59 - 00:28:59
看到了。

00:29:00 - 00:29:01
還看得到啊。

00:29:02 - 00:29:03
騙誰啊。

00:29:04 - 00:29:04
這個。

00:29:06 - 00:29:11
我覺得我當初看到這個影片的時候，想說這個非常適合作為上課的教材。

00:29:13 - 00:29:14
這就是法益相關的欺騙。

00:29:15 - 00:29:16
沒錯，這個就法益相關的欺騙。

00:29:17 - 00:29:17
這樣你懂了吧。

00:29:18 - 00:29:21
這一隻狗，牠聞的是雞腿。

00:29:21 - 00:29:22
眼睛被蒙起來。

00:29:22 - 00:29:24
然後主人一直塞蔬菜跟胡蘿蔔給牠吃。

00:29:25 - 00:29:27
牠是不是連自己在吃什麼都被騙。

00:29:27 - 00:29:28
對，沒有錯。

00:29:28 - 00:29:29
所以這種行為，行為人聲稱是A。

00:29:32 - 00:29:33
被害人也同意A，可是行為人實際上做的，卻是一個跟A無關的B。

00:29:39 - 00:29:42
這就叫做法益相關的欺騙。

00:29:42 - 00:29:44
你腦中只有這個畫面，知道嗎？

00:29:44 - 00:29:46
你去上網搜尋，騙狗吃東西，就是這樣的案例。

00:29:47 - 00:29:49
這樣的案例叫做法律相關的欺騙。

00:29:49 - 00:29:50
被害人的同意無效。

00:29:51 - 00:29:52
知道嗎？被害人同意無效。

00:29:53 - 00:29:53
好。

00:29:55 - 00:29:57
那怎麼樣的情況是法律無關的欺騙？

00:29:59 - 00:30:00
就是我剛講的另外一種。

00:30:00 - 00:30:01
情形。

00:30:01 - 00:30:04
行為人騙被害人做了某些事。

00:30:05 - 00:30:06
事情本身沒有被騙哦。

00:30:07 - 00:30:11
被害人搞錯的是他做了這件事情之後可以得到什麼東西。

00:30:12 - 00:30:13
所以剛剛那個影片喔。

00:30:14 - 00:30:16
如果主人

00:30:17 - 00:30:18
是騙那隻狗說

00:30:19 - 00:30:23
你好好吃紅蘿蔔，吃完我就帶你去散步。

00:30:24 - 00:30:25
然後假設那隻狗很聰明喔，聽得懂喔。

00:30:26 - 00:30:28
他就乖乖地把胡蘿蔔吃掉了。

00:30:28 - 00:30:30
然後他現在說叫主人去帶他散步。

00:30:30 - 00:30:32
結果主人就裝死，然後說不散步，不知道我剛剛沒講，你自己記錯了。

00:30:34 - 00:30:37
這時候就是第二種欺騙，法義無關的欺騙。

00:30:37 - 00:30:40
所以我們再想一次，法義相關的欺騙是不是怎麼樣？

00:30:41 - 00:30:42
信行為本身的欺騙。

00:30:43 - 00:30:52
被害人他對於這個信行為本身，被害人所同意做的，跟行為人所實際做的，根本就是兩件不同的事。

00:30:52 - 00:30:53
這個叫做法益相關，懂嗎？

00:30:54 - 00:30:59
相對的法益無關，通常就是指什麼呢？信行為的對價目的的欺騙。

00:30:59 - 00:30:59
好。

00:31:00 - 00:31:03
各位腦中有這個狗吃胡蘿蔔的影片之後，有這個印象之後啊。

00:31:03 - 00:31:04
我們再來看一下具體的類型喔。

00:31:06 - 00:31:09
我們這裡來看看到第一個喔，信行為本身的欺騙。

00:31:10 - 00:31:13
也就是我們講說A而做B。

00:31:13 - 00:31:16
這個是最典型，一定是無效的同意。

00:31:16 - 00:31:16
以前

00:31:16 - 00:31:18
曾經有過哈，女生去婦產科做內診。

00:31:21 - 00:31:23
那原本做內診的話應該是婦產科醫師把

00:31:23 - 00:31:26
婦產科的器具放到女生的陰道當中。

00:31:27 - 00:31:29
結果這個婦產科醫師啊，竟然是把

00:31:30 - 00:31:32
自己的陰莖放到女生的陰道。

00:31:32 - 00:31:36
因為內診的話，就是中間好像有一塊布簾隔起來。

00:31:36 - 00:31:37
避免四目相交很尷尬嘛。

00:31:37 - 00:31:40
那醫生就想說有布簾啊，這女生不會發現啊，醫生竟然就把自己的陰莖放到那個女生的陰道。

00:31:43 - 00:31:44
以為不會被發現，啊女生就覺得怪，想說

00:31:47 - 00:31:49
為什麼放進去的東西感覺不像是婦產科的器具。

00:31:50 - 00:31:52
一拉開,發現醫生在跟自己性交。

00:31:53 - 00:31:54
大概是這樣的案例。

00:31:54 - 00:31:56
這一種案例當中,同意是無效的,為什麼?

00:31:57 - 00:31:59
被害人同意的是什麼?

00:32:00 - 00:32:01
副產品科技放進去。

00:32:02 - 00:32:03
而醫師做的是什麼呢？

00:32:04 - 00:32:05
陰莖放進去。

00:32:05 - 00:32:07
根本是兩件完全無關的事,對不對？

00:32:07 - 00:32:10
所以這種情況呢,同意一定是無效的,OK吧,這個沒有疑問吼。

00:32:11 - 00:32:11
好。

00:32:13 - 00:32:13
再來第二個吼。

00:32:14 - 00:32:16
性行為方式的欺騙。

00:32:17 - 00:32:20
來，性行為方式的欺騙，同意是有效還無效？

00:32:21 - 00:32:22
其實這種，不可一概而論。

00:32:23 - 00:32:24
回到我剛說的。

00:32:24 - 00:32:27
同意有效、同意無效的關鍵在哪裡？

00:32:28 - 00:32:30
行為人聲稱要做的

00:32:30 - 00:32:33
跟行為人實際上做的，算不算同一件事？

00:32:34 - 00:32:35
關鍵在這邊，瞭解嗎？

00:32:36 - 00:32:42
行為人所聲稱他要做的，跟他所實際上做的，這兩者

00:32:43 - 00:32:45
能不能算是同一件事。

00:32:46 - 00:32:48
所以我們舉個例子喔，326頁這邊。

00:32:51 - 00:32:52
男女合意性交。

00:32:52 - 00:32:55
女生說要帶那個螺旋顆粒的保險套。

00:32:55 - 00:32:57
男生說好，沒問題，我早就準備好了。

00:32:57 - 00:33:00
但其實男生根本帶的只是一般的

00:33:00 - 00:33:00
保險套。

00:33:00 - 00:33:02
後來女生發現了覺得生氣。

00:33:03 - 00:33:06
這種案例，你覺得算不算說A而做B？

00:33:07 - 00:33:08
我認為不算。

00:33:08 - 00:33:08
為什麼？

00:33:08 - 00:33:11
因為都是有帶保險套的安全性行為。

00:33:11 - 00:33:14
至於那個保險套是A牌或B牌。

00:33:14 - 00:33:16
那還不算是兩件不同的事。

00:33:17 - 00:33:17
大概懂這意思嗎？

00:33:18 - 00:33:19
這還不算兩件不同的事。

00:33:19 - 00:33:20
因為這都是有帶嘛。

00:33:21 - 00:33:22
那只是一個細節性的偏差而已。

00:33:23 - 00:33:26
所以這個東西呢,並不算是我們講說A而做B。

00:33:26 - 00:33:29
所以這個時候呢,被害人的同意是有效的。

00:33:30 - 00:33:30
好。

00:33:32 - 00:33:33
再來

00:33:33 - 00:33:33
第二種情況。

00:33:33 - 00:33:34
第二種情況。

00:33:35 - 00:33:37
第二種情況的話呢。

00:33:39 - 00:33:40
我們來看括號這邊。

00:33:41 - 00:33:43
那個偷拔套，這個我在D上還蠻常看到的。

00:33:45 - 00:33:47
這種案例會有問題喔，偷拔套。

00:33:49 - 00:33:52
性交前，女生跟男生說你要戴保險套。

00:33:53 - 00:33:54
男生有帶。

00:33:54 - 00:33:57
結果最後在變換姿勢的時候，男生偷偷拔套。

00:33:58 - 00:33:59
這種案例喔，各位您

00:34:00 - 00:34:02
要知道這個不是隻有道德層面的問題而已，這個會有法律上的問題喔。

00:34:04 - 00:34:04
你們想一件事。

00:34:05 - 00:34:07
女生跟男生說你要戴套。

00:34:09 - 00:34:12
男生一定會怎麼抗辯：我前面有戴啊，我只後面拔掉。

00:34:13 - 00:34:13
這個叫幹話，好吧。

00:34:14 - 00:34:17
當女生說你要戴套的時候，

00:34:17 - 00:34:19
你覺得女生的意思是什麼？

00:34:19 - 00:34:20
廢話要全程嘛。

00:34:21 - 00:34:25
不然如果只有前半段有帶，後半段沒帶，那不是跟沒帶是一樣的嗎？

00:34:25 - 00:34:26
對嗎？

00:34:26 - 00:34:29
所以女生說要帶套一定要全程，那個才有意義，好嗎？

00:34:29 - 00:34:30
所以這樣

00:34:30 - 00:34:30
的案例當中。

00:34:31 - 00:34:32
很明顯啊。

00:34:34 - 00:34:37
這個被害人說這個女生。

00:34:37 - 00:34:41
女生同意的是全程有保險套的性行為。

00:34:42 - 00:34:47
可是男生實際上做的卻是什麼呢？沒有全程戴保險套。

00:34:48 - 00:34:49
那你要想啊。

00:34:49 - 00:34:54
有全程戴跟沒有全程戴，從一般的社會觀點來講，算是同一件事嗎？

00:34:55 - 00:34:56
至少我認為不算。

00:34:57 - 00:35:00
因為有戴叫安全性行為，沒有戴那個叫危險性行為。

00:35:00 - 00:35:03
這兩件事從社會的觀點來講，不會認為是同一件事。

00:35:04 - 00:35:05
所以這個時候同意有沒有效？

00:35:05 - 00:35:06
沒有效喔。

00:35:06 - 00:35:07
我再想一次為什麼？

00:35:08 - 00:35:10
因為女生只同意做安全性行為。

00:35:11 - 00:35:14
可是男生實際上做的卻是一個不安全的性行為。

00:35:15 - 00:35:16
那是兩件不同的事，知道嗎？

00:35:16 - 00:35:17
那是兩件不同的事。

00:35:18 - 00:35:18
好。

00:35:19 - 00:35:21
然後我還想到另外一個案例。

00:35:22 - 00:35:24
這個案例啊，你們也可以思考一下這個同意有沒有效。

00:35:25 - 00:35:27
男生去嫖妓。

00:35:27 - 00:35:29
男生去嫖妓的時候呢。

00:35:30 - 00:35:30
嗯。

00:35:30 - 00:35:35
這個應召女啊，就跟他講說，那個不可以剛繳。

00:35:35 - 00:35:37
這女生講的明確，不可以剛繳。

00:35:38 - 00:35:41
結果男生還是跟這個女生。

00:35:41 - 00:35:44
男生有怪癖，就跟那個女生剛交往，女生很痛，滿身是傷。

00:35:45 - 00:35:51
然後女生講了一句話，說天堂有路，你不走，地獄無門，你偏要闖。

00:35:51 - 00:35:52
女生講這句話。

00:35:53 - 00:35:56
然後男生反應很快，男生講了一句話，說我不入地獄，誰入地獄。

00:35:56 - 00:35:58
這是以前我看過的一個笑話。

00:35:59 - 00:35:59
這個案例當中。

00:36:00 - 00:36:01
被害人同意，

00:36:01 - 00:36:02
有沒有效？

00:36:03 - 00:36:04
被害人同意有沒有效？

00:36:04 - 00:36:04
當然沒有啊。

00:36:05 - 00:36:07
雖然女生同意跟那個男生性交沒有錯，

00:36:07 - 00:36:09
可是女生就說好說不可以硬上，

00:36:09 - 00:36:11
結果男生卻做了硬上的行為，

00:36:12 - 00:36:13
這個是不是說一種作弊？

00:36:13 - 00:36:14
是嗎，對不對？

00:36:14 - 00:36:15
這種案例也是說一種作弊，

00:36:15 - 00:36:18
所以這種案例呢，同意依然是無效的喔。

00:36:19 - 00:36:19
好，

00:36:20 - 00:36:22
接著我們來看到光號三這個出題式的案例。

00:36:24 - 00:36:24
好,

00:36:24 - 00:36:26
這個是薛玉偉老師去年的文章。

00:36:27 - 00:36:29
他說甲男乙女是同居情侶,

00:36:30 - 00:36:32
甲男啊,原本要用保險套跟乙女性交,

00:36:32 - 00:36:35
乙女卻聲稱自己在安全期,希望甲無套性交。

00:36:36 - 00:36:39
甲答應並且完成性交，而且射精在乙女的體內。

00:36:39 - 00:36:41
但其實當時乙女是排卵期，

00:36:41 - 00:36:45
乙女希望自己能懷上甲的小孩，藉此來逼甲登記結婚。

00:36:46 - 00:36:47
恐怖情人。

00:36:47 - 00:36:50
跟那個呂秋遠的那個律師一樣。

00:36:51 - 00:36:52
你不覺得，我不知道你們怎麼看的，

00:36:53 - 00:36:55
至少我覺得那個就是典型的恐怖情人，

00:36:55 - 00:36:56
就是

00:36:57 - 00:36:58
我總覺得，

00:36:58 - 00:37:02
如果女生意外懷了男生的的小孩，

00:37:03 - 00:37:06
那假設女生她也不想墮胎,她真的想要那個小孩的話,

00:37:07 - 00:37:08
她跟男生要一筆錢不就好了嗎?

00:37:09 - 00:37:10
為什麼會想要男生的命呢?

00:37:11 - 00:37:12
我不太懂這個心態,

00:37:12 - 00:37:12
就是

00:37:14 - 00:37:21
難道真的有女生相信，只要一直對渣男情緒勒索，渣男有一天就會變暖男，然後從此再也不渣？

00:37:22 - 00:37:22
你覺得會有這種事嗎？

00:37:22 - 00:37:23
應該不可能吧。

00:37:24 - 00:37:26
就都已經發現他是渣男了，

00:37:26 - 00:37:27
不就應該趕快遠離他嗎？

00:37:28 - 00:37:30
能做的就是跟他要一筆錢,

00:37:30 - 00:37:31
這應該比較理智吧,

00:37:31 - 00:37:33
我不太懂為什麼有人會有這種想法。

00:37:33 - 00:37:37
所以總而言之啊,在這一種案例當中,括號三這邊,

00:37:37 - 00:37:42
這個案例,算不算是女生侵害男生的性自主?

00:37:44 - 00:37:44
因為

00:37:46 - 00:37:47
女生聲稱自己在安全期不會懷孕啊,

00:37:47 - 00:37:48
但事實上不是啊,

00:37:48 - 00:37:54
這一種案例當中,可不可以認為是女生侵害了男生的性自主呢?

00:37:55 - 00:37:56
所以我們來看一下這邊,

00:37:56 - 00:37:58
你看薛老師的說明,

00:37:59 - 00:37:59
這裡他說,

00:38:00 - 00:38:00
第一個,從未教知識來說,

00:38:03 - 00:38:04
就沒有真正安全期啦。

00:38:05 - 00:38:07
只有排卵期跟非排卵期啦,所以第一個,

00:38:07 - 00:38:09
並沒有真正安全期可言,所以對這個東西,

00:38:11 - 00:38:13
如果假如有正確的認知的話,

00:38:14 - 00:38:16
我們很難說這裡有人作弊的情況。

00:38:17 - 00:38:19
這跟有沒有太不一樣喔。

00:38:19 - 00:38:22
因為保險套它確實可以有效地防範性病跟懷孕。

00:38:22 - 00:38:24
可是到底是不是安全期,

00:38:24 - 00:38:26
就算不是安全期,

00:38:27 - 00:38:28
它也是有一定懷孕的機率啊。

00:38:29 - 00:38:30
所以在這個案例當中,

00:38:30 - 00:38:36
你說被害人所同意的跟行為人所做的,真的能稱為是兩件不同的事嗎?

00:38:37 - 00:38:40
恐怕不算,對不對,因為他其實都是不怎麼完全的性行為啊。

00:38:41 - 00:38:45
而且後面,雙方是穩定的同志伴侶,

00:38:45 - 00:38:51
有沒有帶保險套,這個應該無外乎加以雙方對傳染性病的風險的評估,

00:38:51 - 00:38:52
因為老師這樣認為,

00:38:53 - 00:38:54
所以進而，這裡說，

00:38:55 - 00:38:58
行為人就是這個女生，雖然騙了男生，

00:38:59 - 00:39:00
對女生雖然騙

00:39:00 - 00:39:01
了男生沒有錯，

00:39:01 - 00:39:04
但是這個欺騙還沒有到A跟B之間的差異。

00:39:05 - 00:39:08
這個欺騙，他可能只是某些動機上的欺騙。

00:39:08 - 00:39:12
行為人所同意的，跟被害人所同意的，跟行為人所做的，

00:39:13 - 00:39:16
語意上來說，應該依然可以認為是相同的兩件事，所以會認為說呢，

00:39:17 - 00:39:19
這裡並不是一個

00:39:21 - 00:39:22
重要的欺騙。

00:39:22 - 00:39:27
所以認為說呢，這裡的同意還是有效的，所以構成要件是不該當。

00:39:29 - 00:39:30
好，再來第三點。

00:39:31 - 00:39:34
那如果是性行為對價或目的的欺騙呢？

00:39:34 - 00:39:35
這種比較不會有疑問，

00:39:36 - 00:39:37
就是一般常講的騙砲。

00:39:38 - 00:39:40
男生說打了砲就會變成男女朋友。

00:39:41 - 00:39:42
男生說打的砲就會結婚。

00:39:43 - 00:39:45
可是事實上，男生根本沒有這個想法，

00:39:45 - 00:39:47
打完砲就把女生給甩了，這一種，

00:39:47 - 00:39:49
或者是白嫖的，說好會給錢，

00:39:49 - 00:39:52
但實際上根本就沒有給錢，這一種案例的話。

00:39:54 - 00:39:56
行為人我們會怎麼論罪？

00:39:57 - 00:39:59
當然我們說嘛，被害人同意的跟

00:40:00 - 00:40:00
一個人做的一不一樣？

00:40:00 - 00:40:00
一樣對不對？

00:40:00 - 00:40:00
都是同一個性行為嘛。

00:40:00 - 00:40:00
只是騙的是做完之後可以得到什麼東西

00:40:00 - 00:40:00
所以這一種案例呢,被害人的同意是有效的喔,知道是有效的

00:40:00 - 00:40:00
好,那麼接下來的問題是在328頁這邊

00:40:00 - 00:40:00
這次的問題在後面

00:40:00 - 00:40:00
那無效的同意,可以認為違反被害人的意願嗎

00:40:00 - 00:40:00
這個東西是目前我覺得討論上最分歧的地方

00:40:00 - 00:40:00
那我過幾個禮拜在那個蔡學偉老師的課堂上，我也想寫一篇關於這個問題的報告

00:40:00 - 00:40:00
這個到時候有什麼想法，看有沒有機會再跟各位分享

00:40:00 - 00:40:00
反正啦，像蔡老師，他很明確的會認為說，未獲有效同意，跟違反意願，這個是兩件不同的事

00:40:00 - 00:40:00
因為蔡老師在文章裡面一直強調什麼叫違反意願

00:40:00 - 00:40:00
違反意願一定是

00:40:00 - 00:40:00
被害人他真的有表意

00:40:00 - 00:40:00
這個表意當然不見得要明示，默示也可以

00:40:00 - 00:40:00
但是違反意願的前提一定是被害人他真的有表意，然後行為人做了一件跟被害人表意相對的事，那個才叫違反意願

00:40:00 - 00:40:00
所以如果照蔡學偉老師的看法，前面那些無效同意的案例，對同意無效沒有錯，可是你不能說那個叫違反意願啊

00:40:00 - 00:40:00
被害人他事實上就是沒有弄表意啊

00:40:00 - 00:40:00
對不對，他就是沒有表達這個意思啊

00:40:00 - 00:40:00
所以一派的看法是認為說這種案例根本不能認為有違反被害的意願

00:40:00 - 00:40:00
像我們叫拔套那個案例

00:40:00 - 00:40:00
你說拔套的案例有沒有違反被害的意願

00:40:00 - 00:40:00
假設是被害人已經發現男生拔套了

00:40:00 - 00:40:00
而這個女生跟男生說：「你沒有戴，你給我拔出來，你不要再繼續跟我做。」

00:40:00 - 00:40:00
男生不理她還繼續

00:40:00 - 00:40:00
這個叫違反意願，知道嗎？

00:40:00 - 00:40:00
可是前面拔套的案例是可能變換姿勢的時候，女生就沒有發現男生有拔，最後是男生射精之後女生才發現這件事。

00:40:00 - 00:40:00
那蔡老師會說這個怎麼會違反意願

00:40:00 - 00:40:00
這邊你如果

00:42:00 - 00:42:01
真的要說違反，

00:42:01 - 00:42:04
因為它充其量只是違反被害人可推知的意願。

00:42:04 - 00:42:05
充其量只是這樣子而已。

00:42:06 - 00:42:08
可是違反可推知的意願，

00:42:08 - 00:42:10
我們可以說它叫做221的違反意願嗎？

00:42:11 - 00:42:13
這裡學理上會有蠻分歧的看法啦。

00:42:14 - 00:42:15
因為像蔡老師的看法會認為說，

00:42:15 - 00:42:21
如果你把違反可推知的意願也認為是221的違反意願的話，

00:42:21 - 00:42:23
那會造成221不當的擴張,

00:42:24 - 00:42:26
甚至可能會有架空其他條文的疑慮。

00:42:27 - 00:42:28
像比如說趁機性交,

00:42:29 - 00:42:31
趁機性交像潛規則那一種,

00:42:31 - 00:42:35
那種條文非常典型就叫做違反被害人的可推知意願。

00:42:36 - 00:42:36
但你要想喔,

00:42:37 - 00:42:43
如果221的違反意願可以包括這種違反可推知意願的話,

00:42:44 - 00:42:46
那趁機性交我們還要它幹什麼?

00:42:47 - 00:42:48
是不是就沒有意義了?

00:42:48 - 00:42:51
如果違反可推知意願也可以認為是221的違反意願的話,

00:42:51 - 00:42:52
那225就不需要啦。

00:42:53 - 00:42:53
會有這個疑問，

00:42:53 - 00:42:54
知道吧？

00:42:54 - 00:42:56
所以學理上有一派的看法認為說，

00:42:56 - 00:42:57
所謂的違反意願。

00:42:57 - 00:43:01
當然不包括這種違反可推知的意願在內,

00:43:02 - 00:43:03
所以前面這些同意無效案例呢,

00:43:04 - 00:43:05
就是同意無效而已,

00:43:05 - 00:43:06
它不能認為是違反意願。

00:43:07 - 00:43:09
當然也有相對另外一派的看法認為說可以。

00:43:10 - 00:43:10
說違反意願,

00:43:11 - 00:43:12
說這個同意無效的情況,

00:43:13 - 00:43:15
確實我們可以把它等同於違反意願。

00:43:15 - 00:43:16
那我就跟你們說,

00:43:17 - 00:43:20
認為同意無效可以等同於違反意願的說法,

00:43:21 - 00:43:22
他們基本上應該就可以承認,

00:43:23 - 00:43:25
他們基本上應該就會承認,

00:43:25 - 00:43:26
所謂的違反意願,

00:43:26 - 00:43:29
包括的違反可推知的意願在內。

00:43:29 - 00:43:30
所以其實這裡是,

00:43:30 - 00:43:32
這個爭議最核心的問題，

00:43:32 - 00:43:33
你可以寫一下。

00:43:33 - 00:43:35
它這裡最核心的問題就是，

00:43:35 - 00:43:36
違反意願，

00:43:36 - 00:43:40
那個意願有沒有包括可推知的意願？

00:43:41 - 00:43:41
瞭解吧？

00:43:41 - 00:43:43
有沒有包括可推知的意願？

00:43:44 - 00:43:46
像你想婦產科案就這樣。

00:43:47 - 00:43:48
那個婦產科案當中，

00:43:49 - 00:43:50
做內診的女生，

00:43:51 - 00:43:53
他一定不可能跟醫生講說,

00:43:53 - 00:43:55
你等一下只能放婦產科進來喔,

00:43:56 - 00:43:58
你不可以偷偷把你的陰莖放進來喔。

00:43:58 - 00:43:59
做內診的女生,

00:44:00 - 00:44:00
不會這樣講嘛。

00:44:00 - 00:44:02
他事實上也沒有想到吧，對不對？

00:44:03 - 00:44:06
可是對於這個做內診的女生來說，

00:44:07 - 00:44:10
後來他發現醫師把陰莖放進來，

00:44:10 - 00:44:11
那女生一定會說，

00:44:12 - 00:44:14
我怎麼可能同意他把陰莖放進來。

00:44:15 - 00:44:15
瞭解這意思吧？

00:44:16 - 00:44:18
所以這個叫什麼？

00:44:18 - 00:44:19
違反

00:44:19 - 00:44:19
可推知的意願。

00:44:19 - 00:44:21
就事實上被害人當然沒有說不行。

00:44:22 - 00:44:25
可是想也知道被害人一定不會答應嘛。

00:44:25 - 00:44:26
這個叫可推測的意願，知道嗎？

00:44:27 - 00:44:29
所以這裡其實就這幾年比較核心的問題啦。

00:44:30 - 00:44:35
所謂的違反意願，除了這種被害人已經有明示或默示表達出來的意願之外，

00:44:35 - 00:44:38
這一種純粹可推知的意願。

00:44:38 - 00:44:40
可以算是我們這個條文所說的違反意願嗎？

00:44:40 - 00:44:42
所以這個就爭執的核心。

00:44:42 - 00:44:43
好。

00:44:44 - 00:44:46
那接著329頁，我們來往下看。

00:44:47 - 00:44:47
性交行為。

00:44:48 - 00:44:49
性交什麼時候既遂,括號五這邊。

00:44:51 - 00:44:54
只要有進入或精合就既遂了。

00:44:55 - 00:44:56
然後這邊再幫同學複習一件事。

00:44:58 - 00:44:58
不見

00:44:58 - 00:44:59
得要全部進入。

00:45:00 - 00:45:00
不見

00:45:00 - 00:45:01
得。

00:45:01 - 00:45:02
一步就算。

00:45:03 - 00:45:07
而且進入的對象也沒有限於陰道的本身。

00:45:08 - 00:45:08
不見

00:45:08 - 00:45:08
得。

00:45:09 - 00:45:13
所以有些案例你們要想喔，這個其實在食物上認定都是既遂喔。

00:45:13 - 00:45:14
比如說，

00:45:15 - 00:45:19
男生用他勃起的陰莖要進入女生的陰道。

00:45:20 - 00:45:20
但可能

00:45:20 - 00:45:22
女生之前沒有性經驗的關係,

00:45:23 - 00:45:25
所以可能男生的龜頭就卡在女生的陰道口,

00:45:26 - 00:45:27
沒有順利地進入,

00:45:27 - 00:45:30
只有龜頭在陰道口的位置,

00:45:30 - 00:45:30
這樣的

00:45:30 - 00:45:32
案例，照實務見解，這個是既遂喔。

00:45:33 - 00:45:35
你說你不是沒有完全進去，對，沒有完全進去沒有錯，

00:45:36 - 00:45:37
可是你想喔，男生的龜頭卡在女生的陰道口，

00:45:39 - 00:45:42
那是不是已經進入女生的性器了。

00:45:42 - 00:45:44
因為女生的性器不見得是陰道本身啊。

00:45:45 - 00:45:45
食物就說了,

00:45:46 - 00:45:48
如果是陰唇的那個部分是不是性器的部分,

00:45:48 - 00:45:49
是啊,

00:45:49 - 00:45:51
所以龜頭在陰道口,這裡已經既遂了哦。

00:45:51 - 00:45:52
知道嗎？

00:45:52 - 00:45:52
這已經既遂了喔。

00:45:53 - 00:45:58
還有以前我跟同學講過的一個案例，男生違反女生的意願去舔女生的下體。

00:45:59 - 00:45:59
這個食物

00:46:00 - 00:46:02
也經常認為是強制性交罪。

00:46:02 - 00:46:03
因為舌頭是身體部位。

00:46:04 - 00:46:08
那如果他舔女生的陰道是已經有舔到小陰唇的部分的話，

00:46:08 - 00:46:11
那是不是也是用身體進入女生的性器？

00:46:11 - 00:46:13
對，沒錯，所以這也是既遂喔，

00:46:13 - 00:46:13
知道嗎？

00:46:13 - 00:46:14
所以這個提醒各位。

00:46:15 - 00:46:18
接著，括號六，本罪跟其他犯罪的競合。

00:46:19 - 00:46:24
這裡我們就講，因為強制性交罪它本身經常帶有暴力的性質存在，

00:46:25 - 00:46:30
所以如果行為人他為了要壓制被害人所做的一些傷害啊、毀損等等的行為呢，

00:46:31 - 00:46:34
傷害、毀損那些罪都會被吸收掉。

00:46:34 - 00:46:37
然後，性交的過程有猥褻，這個是很常見的。

00:46:37 - 00:46:43
所以成立性交的犯罪的同時，猥褻的犯罪，我們當然也不需要去論哦。

00:46:43 - 00:46:45
好，然後第二點這邊。

00:46:46 - 00:46:51
強制性交強制猥褻的犯罪，它絕對不是集合犯。

00:46:52 - 00:46:56
有些人會反覆犯這種強制性交、強制猥褻的犯罪，

00:46:56 - 00:46:58
某某之狼那一種的。

00:46:58 - 00:47:01
比如說什麼寶城之狼路博言之類的。

00:47:02 - 00:47:04
有些人他可能會反覆犯這種犯罪,

00:47:04 - 00:47:05
那是他的人格有偏差。

00:47:06 - 00:47:10
我們不能說所以強制性交罪它是一個集合犯,不能這樣說。

00:47:10 - 00:47:14
好,接下來,括號七,相對告訴乃論的規定。

00:47:16 - 00:47:17
我們現行法229之一說啊,

00:47:18 - 00:47:22
對配偶犯221、224的犯罪，需為告訴乃論。

00:47:22 - 00:47:23
看清楚喔,

00:47:23 - 00:47:29
只有對配偶犯221、224這兩種才是告訴乃論喔。

00:47:30 - 00:47:33
所以如果是對配偶犯別條，比如說222，

00:47:34 - 00:47:36
帶著兇器去性侵配偶,

00:47:36 - 00:47:39
那個會變加重，那個是非告訴乃論。

00:47:40 - 00:47:42
然後我跟你們說，這個條文有一個漏洞。

00:47:42 - 00:47:44
對配偶犯225的。

00:47:46 - 00:47:47
照理說，225叫趁機嘛。

00:47:48 - 00:47:50
照理說是強制驗傷還是趁機驗傷？

00:47:51 - 00:47:52
廢話，強制，對不對？

00:47:52 - 00:47:54
那對配偶強制都告訴乃論了，

00:47:54 - 00:47:55
趁機呢？

00:47:56 - 00:47:57
條文沒有把趁機列進來喔。

00:47:58 - 00:48:00
所以對配偶犯趁機

00:48:00 - 00:48:00
性交罪，反而是非告訴乃論。

00:48:03 - 00:48:04
這真的很奇怪。

00:48:05 - 00:48:06
或許立法者沒有想到，我以前真的遇過。

00:48:09 - 00:48:13
這一切，我是幫這個男生處理後面離婚的事。

00:48:13 - 00:48:17
我覺得很可惜啦，前面那個妨害性自主那一段我沒有處理到。

00:48:17 - 00:48:19
不然的話我可以幫男生做一個更有效的辯護。

00:48:20 - 00:48:20
這個事情很簡單。

00:48:21 - 00:48:28
這個男生有一次趁他太太熟睡的時候，用手指去性侵他太太的屁眼。

00:48:28 - 00:48:30
那太太被痛到醒過來。

00:48:30 - 00:48:32
然後很憤怒，所以太太就告他先生，就這樣一個案例。

00:48:32 - 00:48:34
你們覺得很荒唐對不對？

00:48:34 - 00:48:35
對啊，就真的是這樣子啊。

00:48:35 - 00:48:38
男生在太太熟睡的時候用手指去捅他太太的屁眼。

00:48:38 - 00:48:40
太太痛到醒過來，然後去警局報案，大概是這樣一個案例。

00:48:43 - 00:48:46
那後來這一切，雙方有和解。

00:48:46 - 00:48:47
對，雙方有和解。

00:48:48 - 00:48:54
但問題就在於，男生在太太熟睡的時候用手指去捅他太太的屁眼，這個叫什麼？

00:48:55 - 00:48:56
趁機性交。

00:48:57 - 00:48:59
那夫妻之間犯趁機性交，有沒有是告訴乃論的範圍？

00:49:00 - 00:49:00
沒有。

00:49:01 - 00:49:02
它是非告訴乃論。

00:49:03 - 00:49:04
和解後就不能撤告。

00:49:05 - 00:49:06
對，所以最後法院怎麼做呢？

00:49:07 - 00:49:08
最後法院就用59去減。

00:49:08 - 00:49:09
減完之後給他緩刑。

00:49:10 - 00:49:11
最後就這麼做。

00:49:11 - 00:49:14
所以我後來在幫這個男生處理離婚案件的時候，我當時就在想。

00:49:15 - 00:49:22
如果啦，如果我早一點認識這個男生，我有幫他處理到前面的性犯罪的話。

00:49:23 - 00:49:24
我反而會建議男生。

00:49:25 - 00:49:26
你要承認你有強制性交。

00:49:27 - 00:49:30
你要說沒有，不是熟睡，當時太太已經起來了。

00:49:30 - 00:49:32
我還繼續捅他屁眼。

00:49:32 - 00:49:33
要這樣講。

00:49:33 - 00:49:33
為什麼？

00:49:34 - 00:49:37
因為這樣變強制性交，強制性交才有和解撤告的空間。

00:49:38 - 00:49:39
你聽起來是不是很詭異？

00:49:39 - 00:49:43
哪有辯護人叫被告去認那個重罪，而且還是沒有做過的重罪。

00:49:43 - 00:49:44
聽起來很詭異對不對？

00:49:44 - 00:49:45
可是現行法就這樣子啊。

00:49:46 - 00:49:47
那你說怎麼辦？

00:49:47 - 00:49:49
所以這個案例分享給各位，真的是食物上發生過的。

00:49:49 - 00:49:51
對配偶犯25，非告訴乃論喔。

00:49:55 - 00:49:56
好，接下來，我們來看到330頁。

00:49:58 - 00:49:59
來看到這個題目。

00:50:44 - 00:50:45
好，下面這一題喔。

00:50:46 - 00:50:49
這一題當中我們區分第一次跟第二次的性交。

00:50:49 - 00:50:51
行為人第一次的性交呢，很明顯。

00:50:52 - 00:50:55
他並沒有使用任何的強勢力，題目裡面說嘛。

00:50:57 - 00:50:59
這個沒有出手或出言恐嚇。

00:51:00 - 00:51:02
但態度卻越來越兇惡，有沒有看到？

00:51:03 - 00:51:06
他並沒有使用任何的強暴手段等等。

00:51:06 - 00:51:08
但被害人他的確不願意。

00:51:08 - 00:51:09
所以這裡你要寫的是什麼呢？

00:51:09 - 00:51:13
關於其他違反意願的方法，要怎麼去認定的問題。

00:51:13 - 00:51:16
我們上次下課解說講到的高度強制手段說。

00:51:16 - 00:51:18
第一度強制手段說，有效同意說。

00:51:19 - 00:51:22
還有呢，利用既存強制手段來說，大概是幾說。

00:51:23 - 00:51:27
這一說呢，我覺得應該是支持第一度強制手段說的老師出的。

00:51:27 - 00:51:32
因為這一題的案例，正好是第一度強制手段說所要請求的那一種狀況。

00:51:33 - 00:51:37
也就是雖然沒有使用暴力，但行為人製造出一個讓被害人難以求助的處境。

00:51:38 - 00:51:39
所以前段的話呢，

00:51:40 - 00:51:40
除非你採高度強制手段說。

00:51:43 - 00:51:45
否則照另外幾種說法，都可以認為是其他的違反意願。

00:51:48 - 00:51:49
前段比較沒有問題。

00:51:50 - 00:51:52
後段的話是大家理解上比較分歧的地方。

00:51:53 - 00:51:54
我跟你們講我後段的思考。

00:51:55 - 00:51:59
後段有些解答，有些解題書會解說，那是一種脅迫或恐嚇。

00:51:59 - 00:52:00
但

00:52:00 - 00:52:01
但我認為不行。

00:52:01 - 00:52:02
你看後段怎麼說?

00:52:04 - 00:52:07
他說他覺得A並**不**慎重，被靈體產生**影響**,

00:52:07 - 00:52:09
需要再次性交才可以把陽氣傳入,

00:52:09 - 00:52:11
驅除靈體。

00:52:13 - 00:52:13
這種案例,

00:52:14 - 00:52:15
可以認為是脅迫或恐嚇嗎？

00:52:16 - 00:52:17
我上次跟各位講過了喔，

00:52:18 - 00:52:19
脅迫或恐嚇的意思是，

00:52:20 - 00:52:23
被害人如果不接受行為人的條件，

00:52:23 - 00:52:27
行為人會讓被害人處於一個比現狀更糟糕的狀態。

00:52:28 - 00:52:29
這個叫脅迫恐嚇。

00:52:30 - 00:52:32
所以如果神棍跟女性徒弟說,

00:52:32 - 00:52:34
你不跟我陰陽雙修的話,

00:52:35 - 00:52:37
我就放小鬼讓你家破人亡,

00:52:37 - 00:52:38
是不是脅迫恐嚇?

00:52:39 - 00:52:39
是,

00:52:39 - 00:52:39
對不對?

00:52:40 - 00:52:41
可是這一題是顛倒過來。

00:52:42 - 00:52:42
這一題是,

00:52:43 - 00:52:44
我跟你性交的話,

00:52:44 - 00:52:45
我把陽氣傳入，

00:52:46 - 00:52:47
可以把你的靈體趕走。

00:52:48 - 00:52:50
也就是如果你跟我性交，

00:52:50 - 00:52:51
我會讓你的身體變好。

00:52:52 - 00:52:53
這個哪叫恐嚇？

00:52:53 - 00:52:54
這叫利誘吧。

00:52:55 - 00:52:55
完全反過來，

00:52:55 - 00:52:56
對不對？

00:52:56 - 00:52:57
我是不是講過了，

00:52:57 - 00:52:59
脅迫恐嚇一定是怎麼樣？

00:52:59 - 00:53:01
被害人如果不接受行為人的條件,

00:53:01 - 00:53:05
行為人會讓被害人陷入一個比現狀更糟糕的狀態。

00:53:05 - 00:53:07
可是這一題是反過來喔。

00:53:07 - 00:53:09
被害人如果接受行為人的條件的話,

00:53:10 - 00:53:12
行為人會讓被害人變得更好。

00:53:12 - 00:53:13
這個不是啦,

00:53:13 - 00:53:14
這個叫利誘啦。

00:53:14 - 00:53:16
利誘別人發生性關係,

00:53:16 - 00:53:17
原則上又不成立犯罪,

00:53:17 - 00:53:17
對不對?

00:53:17 - 00:53:19
所以後半段的部分，

00:54:00 - 00:54:00
你想喔，在我們刑法分則個人法益的犯罪當中

00:54:04 - 00:54:06
以人數作為加重，其實沒有那麼多

00:54:07 - 00:54:10
對啊，為什麼殺人罪沒有說你兩個人一起殺要加重

00:54:11 - 00:54:13
傷害罪也沒有說你兩個人一起毆打被害要加重

00:54:14 - 00:54:18
可是為什麼強聚性交罪這邊卻說,兩個人一起性侵要加重

00:54:20 - 00:54:21
所以你覺得理由是什麼

00:54:22 - 00:54:24
當然不是說人多犯罪比較容易實現,當然不是嘛

00:54:25 - 00:54:27
因為如果你想人多犯罪更容易實現的話

00:54:28 - 00:54:30
那這個到底在所有個人法益的犯罪

00:54:30 - 00:54:30
中

00:54:30 - 00:54:30
是

00:54:30 - 00:54:31
否

00:54:31 - 00:54:31
都

00:54:31 - 00:54:31
是

00:54:31 - 00:54:31
如此

00:54:31 - 00:54:31
對不對

00:54:31 - 00:54:33
所以這裡，為什麼人數說加重

00:54:33 - 00:54:36
這裡考量到的是性的隱私性

00:54:38 - 00:54:41
也就是說，被性侵本身已經夠痛苦了

00:54:41 - 00:54:47
如果被性侵的時候，又是被多數人性侵的話，那個心理的痛苦是加成的

00:54:48 - 00:54:49
所以他才有這個加重，瞭解嗎？

00:54:49 - 00:54:50
他考量的是這個

00:54:51 - 00:54:55
多數人的性侵，對被害人來說會有更強烈的心理痛苦

00:54:55 - 00:54:57
所以才會有設置加重的規定

00:54:57 - 00:54:59
好，那麼二人怎麼解釋？

00:55:00 - 00:55:03
我們這邊講說食物上的委託它是一種結夥犯罪。

00:55:03 - 00:55:05
所以無責任的人呢，我們把它排除掉。

00:55:06 - 00:55:08
好，然後，要不要全體都性交？

00:55:09 - 00:55:10
不用喔。

00:55:10 - 00:55:12
這裡只說二人以上共同犯事喔

00:55:13 - 00:55:15
因為你知道嗎,以前20幾年前的舊條文

00:55:15 - 00:55:18
原本舊的條文是說輪姦啊

00:55:18 - 00:55:19
好

00:55:19 - 00:55:20
原本是說輪姦

00:55:20 - 00:55:20
但後來改了

00:55:22 - 00:55:24
後來改說二人以上共同犯事

00:55:25 - 00:55:29
所以這個條文現在來講，不需要是輪姦

00:55:29 - 00:55:29
不用

00:55:30 - 00:55:30
哦

00:55:30 - 00:55:34
只要兩個人以上，有共同實行構成要件行為

00:55:34 - 00:55:36
不需要全體都性交喔

00:55:36 - 00:55:38
這樣子的犯罪就可以成立了

00:55:39 - 00:55:42
所以來，我們這邊講一件事，這個同學你腦袋要轉一下

00:55:44 - 00:55:47
222條的第一項第一款，二人以上共同犯事

00:55:48 - 00:55:50
它的本質也是一種共同正犯，對吧？

00:55:50 - 00:55:51
一定是嘛，對。

00:55:51 - 00:55:53
他一定是共同正犯。

00:55:53 - 00:55:54
所以喔，各位，這一條什麼時候會未遂？

00:55:57 - 00:55:58
這一款什麼時候會未遂？

00:56:00 - 00:56:01
我再講一次喔,

00:56:01 - 00:56:04
這一款它本質上具有共同正犯的性質。

00:56:04 - 00:56:07
所以這一款本質上是共同正犯的話,

00:56:07 - 00:56:09
是不是會一人計遂,

00:56:09 - 00:56:09
全體計遂?

00:56:10 - 00:56:10
對,

00:56:10 - 00:56:11
沒有錯。

00:56:11 - 00:56:13
所以這一款是由,

00:56:13 - 00:56:16
只要全體當中有任何一個人有性交,

00:56:17 - 00:56:19
那全體就計遂了喔。

00:56:19 - 00:56:20
知道嗎？

00:56:20 - 00:56:20
舉個例子喔。

00:56:21 - 00:56:21
假設那個，

00:56:22 - 00:56:23
那個誰啊？

00:56:24 - 00:56:25
陸博言跟一谷，

00:56:26 - 00:56:27
兩個人要輪姦我。

00:56:28 - 00:56:29
那一個先痛打我一頓,

00:56:29 - 00:56:31
正在對我進行性交行為的時候,

00:56:33 - 00:56:35
那個陸博言在旁邊打手槍,

00:56:35 - 00:56:36
等一下要換他上。

00:56:37 - 00:56:37
結果這時候呢,

00:56:38 - 00:56:39
突然聽到腳步聲,

00:56:39 - 00:56:40
警察過來了,

00:56:40 - 00:56:41
他們兩個趕快把褲子穿一穿跑了。

00:56:42 - 00:56:43
這樣的話,

00:56:43 - 00:56:44
他們兩個人計遂還未遂？

00:56:45 - 00:56:45
計遂喔,

00:56:46 - 00:56:47
因為他們是共同正犯,

00:56:47 - 00:56:47
一人計遂,

00:56:47 - 00:56:49
全體就計遂了。

00:56:49 - 00:56:49
知道吧？

00:56:50 - 00:56:50
所以這一款，

00:56:50 - 00:56:52
什麼時候才會未遂？

00:56:53 - 00:56:54
全體都還沒性交的時候，

00:56:55 - 00:56:55
知道嗎？

00:56:55 - 00:56:58
這一款因為它本質上是共同正犯,

00:56:58 - 00:56:59
它一定會有交互規則的關係,

00:56:59 - 00:57:00
所以我們講結論,

00:57:01 - 00:57:04
這一款只有在全體都還沒性交的時候,

00:57:04 - 00:57:05
才會是未遂。

00:57:06 - 00:57:09
否則全體當中有任何一個人性交的話呢,

00:57:09 - 00:57:10
那必然會因為一人計遂,

00:57:10 - 00:57:11
全體計遂的關係,

00:57:12 - 00:57:14
全體都會是既遂喔。

00:57:56 - 00:57:57
好,

00:57:58 - 00:57:59
那麼接下來，

00:57:59 - 00:58:00
二人以上共同

00:58:00 - 00:58:00
一定要什麼呢？

00:58:00 - 00:58:03
在場的共同正犯，那個才算。

00:58:04 - 00:58:04
好，那你接著看喔。

00:58:05 - 00:58:08
在場的共同正犯來。

00:58:09 - 00:58:09
第一個喔。

00:58:10 - 00:58:11
單純在場。

00:58:12 - 00:58:15
而沒有參與強制或性交的算不算？

00:58:16 - 00:58:17
這種狀況是這樣的。

00:58:18 - 00:58:19
假男，性情壓抑。

00:58:20 - 00:58:24
那壓抑呢，完全是假男壓制的。

00:58:24 - 00:58:29
而假男正在跟女性性交的時候，假男的另外一個朋友，全程都在旁邊看。

00:58:30 - 00:58:32
然後那個朋友也想說等下要性交。

00:58:33 - 00:58:37
但後來沒有性交到，可能旁邊就有第三個人來了，所以就沒辦法繼續了。

00:58:38 - 00:58:43
這一種，單純在場，既沒有做強制，也沒有做性交的人。

00:58:43 - 00:58:45
可以算入這一款的人數嗎？

00:58:46 - 00:58:47
通說認為沒有啦。

00:58:47 - 00:58:49
但李聖情老師認為可以。

00:58:49 - 00:58:53
因為李聖情老師認為說，既然這一款考量到的是性的私密性的話。

00:58:54 - 00:58:55
那。

00:58:55 - 00:58:59
單純在場，就算沒有做強制，就算沒有做性交的人，

00:58:59 - 00:59:00
也

00:59:00 - 00:59:01
應該算入人數。

00:59:01 - 00:59:02
李老師有這樣的說法。

00:59:03 - 00:59:03
好。

00:59:03 - 00:59:08
那如果是在場有參與強制，甚至有參與到性交的話呢？

00:59:09 - 00:59:10
那當然一定可以算，這個沒有疑問。

00:59:11 - 00:59:12
所以我們這邊做一個小結。

00:59:13 - 00:59:16
要論222條第一項的第二款。

00:59:17 - 00:59:18
最低限度是什麼？

00:59:19 - 00:59:20
至少

00:59:20 - 00:59:20
至少

00:59:20 - 00:59:23
要是一個在場的共同正犯，

00:59:24 - 00:59:25
才算人數，知道嗎？

00:59:26 - 00:59:28
在場的共同正犯，才算入人數喔。

00:59:29 - 00:59:34
所以那一種共謀共同正犯，或教唆犯、幫助犯，不管他在不在場。

00:59:35 - 00:59:36
通通都不算人數。

00:59:37 - 00:59:41
要算入這一款人數呢，最低限度，在場的共同正犯才算喔。

00:59:44 - 00:59:44
好。

00:59:45 - 00:59:49
這個是第一款，再來第二款是對未滿14歲的男女犯去的。

00:59:50 - 00:59:52
第二款這邊在講的是說啊。

00:59:52 - 00:59:55
你性侵未滿14歲的人啊。

00:59:55 - 00:59:57
性侵未滿14歲的人。

00:59:57 - 00:59:59
所以這一款你要會跟227做區分喔。

01:00:00 - 01:00:00
來比如說,同樣是跟13歲的國中女生性交。

01:00:04 - 01:00:07
如果是路博言去約炮,約了一個13歲的國中女生。

01:00:08 - 01:00:09
路博也會不會論這一款？

01:00:10 - 01:00:12
我會喔,那合意的那是論227喔,知道嗎?

01:00:12 - 01:00:17
會論這一款是比如說,路博言違反一個國中女生的意願去性侵她,這才會論第二款。

01:00:19 - 01:00:21
第二款的前提是什麼？是221，所以構成這一款呢，必須是行為人他有違反被害人的意願。

01:00:26 - 01:00:32
好，那麼第三款，對精神、身體障礙或其他心智缺陷的人犯之。

01:00:33 - 01:00:36
這個就是說行為人去性侵有身心障礙的人啊，這個是第三款。

01:00:37 - 01:00:39
那一樣，要違反他的意願。

01:00:40 - 01:00:47
所以如果只是單純利用智能障礙者的無知，而去跟他發生性關係的話，那個是225。

01:00:49 - 01:00:50
那個不會變，知道嗎?

01:00:51 - 01:00:53
會變一定怎麼樣?違反他的意願。

01:00:53 - 01:00:57
智能障礙者說他不要，行為人還硬上，這個時候呢，才會變。

01:00:58 - 01:00:58
好。

01:00:59 - 01:01:02
那接著第四款，要計犯之，下藥迷昏被害人這一種，這個不用多說。

01:01:05 - 01:01:08
第五款呢,對被害人施以凌虐,各位。

01:01:08 - 01:01:11
第五款這邊所說的凌虐,不包括行為人為了壓制被害人所做的必要手段。

01:01:16 - 01:01:16
不包括喔。

01:01:17 - 01:01:19
因為是這樣,221,他具有暴力的性質存在。

01:01:22 - 01:01:27
如果行為人他只是為了要讓被害人屈服,而對被害人有一些毆打的行為,那個不叫凌虐,知道嗎?

01:01:29 - 01:01:37
會論到第六款一定是說，行為人做的這些凌虐，很明顯已經不是為了使被害人屈服而必要的行為。

01:01:38 - 01:01:43
比如說被害人已經屈服了，行為人卻基於怪癖，對被害人做出一些SM的行為，那種才是第六款。

01:01:45 - 01:01:46
這種才是第五款。

01:01:48 - 01:01:48
好。

01:01:48 - 01:01:54
接著第六款，利用駕駛，供公眾或不特定人運輸的交通工具的機會而犯之。

01:01:56 - 01:01:59
這一款俗稱叫做計程車之狼條款。

01:01:59 - 01:01:59
我不知道你

01:02:00 - 01:02:00
同學你們知不知道啊。

01:02:01 - 01:02:06
在30年前，當時很多女生是晚上不敢一個人搭計程車的。

01:02:07 - 01:02:11
因為在那個時候80、90年代，臺灣社會的治安很差。

01:02:11 - 01:02:16
當時很多計程車司機會性侵或性騷擾女乘客。

01:02:17 - 01:02:18
當時確實有這種狀況。

01:02:18 - 01:02:22
比如說30幾年前那個井口真理子命案。

01:02:22 - 01:02:24
有沒有同學聽過井口真理子？

01:02:24 - 01:02:25
不知道的話你們上YouTube搜尋。

01:02:26 - 01:02:27
臺灣啟示錄我記得有報導過。

01:02:28 - 01:02:29
當時是一個日本女學生。

01:02:30 - 01:02:36
叫井口真理子，她一個人在臺灣來臺灣玩，結果被計程車司機性侵而殺害。

01:02:36 - 01:02:38
後來好像還分屍還是怎麼樣吧。

01:02:38 - 01:02:39
我記得這個事情喔。

01:02:39 - 01:02:41
還有像1996年的彭婉如命案。

01:02:41 - 01:02:44
當時啦，臺灣的計程車真的是惡名昭彰。

01:02:45 - 01:02:54
就是有很多這個不能說很多啦，但確實有一些計程車司機，他會利用開計程車的機會去性侵或性騷擾女乘客。

01:02:54 - 01:02:58
所以為什麼後來道交條例會規定說你有性侵的前科就不可以再開計程車。

01:02:59 - 01:03:00
跟那個社會背景有關。

01:03:00 - 01:03:00
知道嗎？

01:03:00 - 01:03:03
所以現在可能同學很難想像了。

01:03:03 - 01:03:04
說計程車這麼危險喔？

01:03:04 - 01:03:05
對，以前真的是這樣子喔。

01:03:05 - 01:03:07
所以當時呢，確實有這樣的一個規定。

01:03:10 - 01:03:11
好，所以第六款的話呢。

01:03:11 - 01:03:12
這邊講了哈。

01:03:13 - 01:03:14
要利用這個機會喔。

01:03:14 - 01:03:20
所以必須是行為人跟這個被害人之間有交易上的關係。

01:03:20 - 01:03:22
確實是乘客跟司機的關係。

01:03:22 - 01:03:24
雙方有這個交易的關係。

01:03:24 - 01:03:25
這個才算。

01:03:26 - 01:03:28
如果只是說，單純利用這個機會。

01:03:29 - 01:03:33
比如說計程車司機他故意把路人撞倒，製造假車禍。

01:03:33 - 01:03:35
然後再去性侵那個路人，這一種不算。

01:03:36 - 01:03:36
或者比如說哈。

01:03:37 - 01:03:38
計程車司機在交友軟體上面。

01:03:40 - 01:03:41
認識一個女生。

01:03:42 - 01:03:46
然後認識的時候計程車司機就用他的計程車載這個女生出去玩。

01:03:46 - 01:03:47
然後再去性侵。

01:03:47 - 01:03:48
這種也不算，知道嗎。

01:03:48 - 01:03:53
所以第六款，我們要記得它就是我們班所俗稱的計程車智障條款。

01:03:55 - 01:03:56
好，第六款我們先看到這邊哈。

01:03:56 - 01:03:59
我們先休息一下，等一下我們再來看後面的幾款。

01:04:06 - 01:04:08
好，我們繼續著來看到第七款這邊，侵入住宅或有人居住的建築物而犯之，這個第七款。

01:04:14 - 01:04:16
好，第七款的話，這一條我們說解釋上跟306一樣，來說什麼叫侵入。

01:04:20 - 01:04:24
沒有經過住居權人的同意而進入，這個就叫侵入，知道嗎？

01:04:24 - 01:04:27
未經住居權人同意而進入，這個叫做侵入。

01:04:27 - 01:04:29
所以這一款的侵入是這樣子喔。

01:04:30 - 01:04:37
這一款的侵入，這一款的侵入呢，我們不以他是不是屋主為必要。

01:04:37 - 01:04:39
食物上我發生過這樣的案例。

01:04:39 - 01:04:45
那個先生跟太太結婚之後，住在登記為先生的房產之下。

01:04:46 - 01:04:47
就那個房子是登記先生的。

01:04:47 - 01:04:50
那夫妻結婚之後就住在那個先生的房子之下。

01:04:50 - 01:04:52
後來呢，夫妻吵架。

01:04:52 - 01:04:58
那先生就跟太太說好，那不然我搬回我老家居住，我們先分居一下，這個房子就先給你住。

01:04:58 - 01:05:00
他們就達成這樣分居的協議。

01:05:00 - 01:05:03
有一天下午，先生來按太太的門鈴，說我們來談談複合好不好。

01:05:05 - 01:05:07
太太說不要，我不讓你進來。

01:05:07 - 01:05:12
結果，當天晚上，這個先生破窗進到他家，然後性侵他太太。

01:05:13 - 01:05:15
後來被判第七款，侵入住宅。

01:05:16 - 01:05:19
先生當然會抗辯說，我就屋主啊，我不能進去嗎？

01:05:20 - 01:05:22
可是問題是，當時那個房子是給他太太用的。

01:05:23 - 01:05:25
他們當時夫妻處於一個分居的狀態。

01:05:25 - 01:05:26
所以這個時候。

01:05:27 - 01:05:29
所以這個時候，可不可以認為說

01:05:31 - 01:05:32
先生有侵入，有喔，知道嗎？

01:05:32 - 01:05:34
雖然他是屋主，那個就好像房東跟房客嘛。

01:05:36 - 01:05:40
房東把房子租給房客的期間，難道房東可以隨便進去嗎？

01:05:40 - 01:05:41
當然不行啊，就一樣的意思，知道嗎？

01:05:41 - 01:05:44
所以後來那個先生被判了第七款，這個監獄應該還蠻可恥的吧。

01:05:47 - 01:05:50
因為性侵犯在監獄本來就會被人家瞧不起。

01:05:50 - 01:05:52
別人會說你性侵誰，性侵我太太。

01:05:53 - 01:05:55
我應該可以想像那監獄裡面過得多慘，所以這是以前發生過的。

01:05:57 - 01:06:00
好，再來第八款，期待兇器而來。

01:06:01 - 01:06:03
第八款的兇器呢，實務說，

01:06:03 - 01:06:06
有客觀上的危險性就夠了，

01:06:06 - 01:06:09
而且不需要行為人主觀上有行兇的意思，

01:06:09 - 01:06:12
甚至當場撿到的也算。

01:06:12 - 01:06:13
所以我們講，

01:06:13 - 01:06:18
這一款的兇器百分之百完全比照加重竊盜罪

01:06:18 - 01:06:19
完全一樣。

01:06:19 - 01:06:21
所以以前發生過一個案例，

01:06:21 - 01:06:24
就是有個男生開車在路上，看到一個女生在等公車，

01:06:24 - 01:06:27
男生就去搭訕那個女生，說你要去市區嘛對不對？

01:06:27 - 01:06:29
你上我的車，我載你去。

01:06:29 - 01:06:32
結果男生把那個女生載去汽車旅館，

01:06:32 - 01:06:35
拉女生下車，就要跟那個女生發生性關係，

01:06:35 - 01:06:37
女生說不要，啊男生硬上，

01:06:37 - 01:06:39
而男生硬上之前呢，

01:06:39 - 01:06:41
男生有個怪癖，他不喜歡女生有陰毛。

01:06:41 - 01:06:46
所以男生就去旅館的廁所裡面拿了刮鬍刀，把女生的陰毛剃掉。

01:06:46 - 01:06:49
而男生把女生的陰毛剃掉之後啊，

01:06:49 - 01:06:51
男生可能過度緊張之類的，他無法勃起。

01:06:52 - 01:06:54
最後就作罷，就離開了。

01:06:54 - 01:06:56
後來女生去告那個男生嘛,

01:06:56 - 01:06:59
男生被判加重強制性交未遂。

01:06:59 - 01:07:20
為什麼

01:07:20 - 01:07:40
加重？

01:07:40 - 01:07:42
因為判決說,

01:07:42 - 01:07:44
男生拿那個刮鬍刀去剃女生的陰毛。

01:07:44 - 01:07:47
刮鬍刀有兩片鋒利的刀片外露,

01:07:47 - 01:07:50
如果拿去攻擊人的身體,確實可以把人家割到流血,

01:07:50 - 01:07:53
所以實務說呢,那個刮鬍刀是兇器。

01:07:54 - 01:07:56
你說可是當場拿的算攜帶嗎?

01:07:56 - 01:07:56
實務說算啊,

01:07:56 - 01:07:58
說當場撿到也是攜帶啊,

01:07:58 - 01:08:00
所以男生就因為他那種無毛的怪癖,

01:08:00 - 01:08:01
農具小間

01:08:01 - 01:08:03
你們應該可以想像吧，就農田旁邊那種鐵皮屋，

01:08:04 - 01:08:05
放農具的那種儲藏室。

01:08:06 - 01:08:08
他就拿鐵鎚把那個農具間的門鎖敲壞

01:08:09 - 01:08:11
好，敲壞之後呢，他就把鐵鎚丟在門口

01:08:11 - 01:08:13
他人呢就進到那個農具間裡面

01:08:13 - 01:08:14
好，去做什麼事呢？

01:08:15 - 01:08:19
他進到農具間之後，他把衣服脫光，躲在農具間裡面打手槍。

01:08:20 - 01:08:21
是不是很荒謬？

01:08:21 - 01:08:22
所以就真的發生這種事，

01:08:22 - 01:08:23
那個人好像有吸毒吧。

01:08:24 - 01:08:25
天啊我不懂這樣哪裡爽。

01:08:25 - 01:08:30
拿鐵鎚去敲人家農具間的門鎖，敲壞之後他人進到那個農具間，把衣服脫光在裡面打手槍。

01:08:31 - 01:08:35
打到一半，有一個五六十歲的農夫要進來拿農具。

01:08:36 - 01:08:38
那他打手槍打到一半，看到一個農夫要來拿農具，

01:08:39 - 01:08:40
他就想跟那個農夫發生性關係。

01:08:41 - 01:08:43
農夫當然不想嘛，就發生了一些拉扯，

01:08:43 - 01:08:45
後來農夫成功脫逃了。

01:08:46 - 01:08:48
那這個男生怎麼論罪?

01:08:50 - 01:08:53
這裡,可不可以算第八款,攜帶兇器而犯之。

01:08:53 - 01:08:55
鐵鎚是不是兇器?對,鐵鎚是兇器。

01:08:55 - 01:09:01
但是他當時呢,我們講,他當時是用鐵鎚敲壞門鎖之後,鐵鎚就放在門口。

01:09:02 - 01:09:08
也就是他要性侵這個農婦的時候,鐵鎚並不是在一個隨手可以取得的狀態。

01:09:08 - 01:09:10
所以那個沒有算攜帶喔,

01:09:10 - 01:09:10
知道嗎?

01:09:10 - 01:09:11
我們講攜帶必須怎麼樣?

01:09:12 - 01:09:16
這個東西在行為當下處於一個隨手可得的狀態,這個才算攜帶。

01:09:17 - 01:09:22
而這題當中,鐵鎚因為離行為人很遠,所以呢,它不算是攜帶。

01:09:24 - 01:09:25
好，這個第八款。

01:09:26 - 01:09:27
再來，我們來看到第九款。

01:09:30 - 01:09:36
好，第九款的話呢，這邊說對被害人為照相、錄音、錄影或散佈該影像聲音電子紀錄。

01:09:37 - 01:09:39
第九款的話是這樣，

01:09:39 - 01:09:40
我們要注意一件事。

01:09:40 - 01:09:42
第九款你要分前面跟後面

01:09:43 - 01:09:43
你看喔

01:09:44 - 01:09:49
第九款的前面說，對被害人為照相、錄音、錄影。

01:09:51 - 01:09:52
前半段的照相錄音錄影

01:09:52 - 01:09:55
沒錯，它就是條文所說的那個意思，那個沒有問題。

01:09:56 - 01:09:57
可是接著後段說，

01:09:58 - 01:10:00
散佈播送該聲音、

01:10:00 - 01:10:01
影像、電子記錄，各位啊！

01:10:01 - 01:10:02
後段說的散佈播送該聲音影像電子記錄，他指的並不是說事後把那個影音流出去，不是喔！

01:10:10 - 01:10:15
因為你要想，222的各款一定是在什麼時候？行為當時，好嗎？

01:10:15 - 01:10:16
因為此行為當時

01:10:16 - 01:10:23
所以後面他說散佈播送該聲音影像電子記錄，他指的不是事後的流出啦

01:10:24 - 01:10:31
他指的是那種行為當下的直播，或者是類似直播的行為，瞭解嗎

01:10:31 - 01:10:32
他這個條文

01:10:34 - 01:10:35
後半段，我講的是後半段喔

01:10:36 - 01:10:39
散佈播送該影像聲音電子記錄

01:10:39 - 01:10:46
後半段指的是行為當下的直播，或者是類似直播的行為

01:10:46 - 01:10:47
他指的是這個東西

01:10:48 - 01:10:52
因為這個條文原本被提出的時候，最早的草案就是寫直播

01:10:54 - 01:10:55
最早就是寫直播

01:10:55 - 01:10:58
後來呢,他寫直播被改掉

01:10:58 - 01:10:58
為什麼

01:10:58 - 01:11:00
因為立法者是擔心說

01:11:00 - 01:11:02
那寫直播會不會掛一漏萬

01:11:02 - 01:11:02
比如說你想

01:11:03 - 01:11:11
假設在性侵的時候，這個性侵犯，他用LINE的視訊，轉播這場性侵給他朋友看。

01:11:11 - 01:11:12
LINE的視訊

01:11:12 - 01:11:14
那LINE的視訊是一對一嘛

01:11:14 - 01:11:16
那個好像不是我們一般所說的直播嘛

01:11:16 - 01:11:19
因為我們一般講的直播可能是多數人都可以同時觀看的，可是LINE的話那個是一對一啊

01:11:19 - 01:11:22
所以立法者就想說你寫直播，可能會有掛一漏萬的問題

01:11:22 - 01:11:26
所以才這樣來寫，懂嗎？所以記得，後段不是指事後流出

01:11:27 - 01:11:30
不是喔，後段是指直播，或者是類似直播的行為

01:11:30 - 01:11:31
後段是這個意思

01:11:37 - 01:11:39
好，再來336位的關號

01:11:40 - 01:11:42
百罪的左手判斷

01:11:42 - 01:11:44
我們永遠記得一件事，很簡單

01:11:46 - 01:11:48
這種加重要件的左手

01:11:48 - 01:11:50
我們一定是怎麼判斷

01:11:50 - 01:11:53
回歸基本構成要件判斷

01:11:53 - 01:11:55
好嗎？加重要件的左手

01:11:55 - 01:11:58
一定是回歸基本構成要件判斷

01:11:59 - 01:12:00
所以意思就是

01:12:00 - 01:12:00
是說啊，假設杜伯也想，這個我性侵未遂。

01:12:00 - 01:12:00
他從我家頂樓平臺垂降到我家陽臺，想潛入我家的臥室，性侵熟睡當中的我。

01:12:00 - 01:12:00
結果他垂降到陽臺之後，發現我陽臺的門有鎖，他根本不得其門而入，卡在陽臺那邊進退不得。

01:12:00 - 01:12:00
這樣的話，他可以對222的未遂嗎？

01:12:00 - 01:12:00
不行哦，因為他根本還沒有開始做性侵的行為，根本就還沒有。

01:12:00 - 01:12:00
所以這裡的話呢，他只能對一般的侵入住宅罪哦。

01:12:00 - 01:12:00
好，然後啊，提醒各位。

01:12:00 - 01:12:00
食物都說啊，通說應該也都承認。

01:12:00 - 01:12:00
第四款，用藥及犯意。

01:12:00 - 01:12:00
當行為人開始對被害人下藥的時候，就可以認為是222條的著手。

01:12:00 - 01:12:00
這個東西，你不要把它當例外。

01:12:00 - 01:12:00
而是這個道理很簡單。

01:12:00 - 01:12:00
為什麼我們講說222的著手，你要回歸221去判斷。

01:12:00 - 01:12:00
你不能用222的個案認定著手，對這個我們都承認，但為什麼第四款是例外？

01:12:00 - 01:12:00
為什麼當行為人開始對被害人使用藥劑，就可以說是著手？

01:12:00 - 01:12:00
我說的這個其實不是例外啦。

01:12:00 - 01:12:00
而是你知道為什麼嗎？

01:12:00 - 01:12:00
因為施用藥劑就是一種強暴。

01:12:00 - 01:12:00
就是這樣子，好嗎？

01:12:00 - 01:12:00
施用藥劑本身，它就是一種強暴。

01:12:00 - 01:12:00
所以當行為人開始對被害人下藥的時候，其實他已經在做221的強暴行為了，因此就是著手，就這麼簡單，知道嗎？

01:12:00 - 01:12:00
所以那個嚴格來說，它不算是一種例外喔。

01:12:00 - 01:12:00
好，接著來，強制猥褻。

01:12:00 - 01:12:00
那個強制猥褻，224。

01:12:00 - 01:12:00
我們來看一下337頁這邊。

01:12:00 - 01:12:00
那個強制猥褻罪啊。

01:12:00 - 01:12:00
它的結構跟強制性交都一樣。

01:12:00 - 01:12:00
所以強制性交那邊有的問題呢。

01:12:00 - 01:12:00
強制猥褻這邊，當然也都會發生。

01:12:00 - 01:12:00
所以我們前面講過的什麼利用既存小狀態啊，什麼強制手段啊什麼的。

01:12:00 - 01:12:00
這些東西在24都會有喔。

01:12:00 - 01:12:00
我就不再去細講了。

01:12:00 - 01:12:00
好,然後括號,這一條的猥褻我們怎麼認定?

01:12:00 - 01:12:00
上次我是不是有跟同學

01:14:00 - 01:14:00
所以講過

01:14:00 - 01:14:02
性犯罪的猥褻怎麼認定

01:14:02 - 01:14:03
很簡單哈

01:14:03 - 01:14:08
一切客觀上跟性有關的行為就是猥褻

01:14:08 - 01:14:11
瞭解吧

01:14:11 - 01:14:12
一切客觀上跟性有關的行為就是猥褻

01:14:12 - 01:14:15
所以像比如說,強吻別人是不是強是猥褻

01:14:16 - 01:14:18
親吻算不算跟性有關

01:14:18 - 01:14:22
我們講跟性有關不是說這種會懷孕才是喔，不是喔

01:14:22 - 01:14:24
社會意下跟性有關的行為

01:14:25 - 01:14:26
這就是猥褻喔

01:14:26 - 01:14:28
知道吧，社會意下跟性有關的行為就是猥褻

01:14:28 - 01:14:30
所以親吻別人

01:14:30 - 01:14:32
算不算跟性有關

01:14:32 - 01:14:33
算吧

01:14:33 - 01:14:34
當然當然算啊

01:14:34 - 01:14:38
如果等一下中場休息的時候，坐你旁邊的同學來拍拍你說，我們來舌吻好不好

01:14:39 - 01:14:40
你你會說好嗎

01:14:41 - 01:14:42
應該不會吧

01:14:43 - 01:14:43
我看應該不會吧

01:14:44 - 01:14:47
如果會的話，嗯，好了，我也沒意見啦

01:14:47 - 01:14:48
但應該是不會啦

01:14:48 - 01:14:53
所以親吻這件事，確實是一個社會意象跟性有關的行為，所以強吻別人

01:14:54 - 01:14:56
可以論強制猥褻

01:14:57 - 01:15:00
然後猥褻要不要有身體上的接觸

01:15:00 - 01:15:00
啊

01:15:01 - 01:15:02
現在是說不用啦

01:15:03 - 01:15:03
什麼現在說不用

01:15:04 - 01:15:06
所以逼別人看自己打手槍，是不是強姦或猥褻？

01:15:07 - 01:15:08
是喔。

01:15:08 - 01:15:11
就算不是逼別人幫自己打手槍，

01:15:11 - 01:15:13
逼別人幫自己打手槍，那一定是強姦或猥褻。

01:15:13 - 01:15:15
那逼別人看自己打手槍呢？

01:15:16 - 01:15:17
那也是

01:15:18 - 01:15:19
強是猥褻喔

01:15:19 - 01:15:23
所以猥褻行為只要跟性有關就可以,不需要有身體上面的接觸

01:15:24 - 01:15:27
好,接著下面這個老問題,偷襲式的觸摸跟本罪

01:15:30 - 01:15:35
十幾年前在雲林

01:15:35 - 01:15:40
發生一個案件,

01:15:40 - 01:15:45
叫做摸胸十秒案

01:15:45 - 01:15:47
這個摸胸事件是這樣子

01:15:48 - 01:15:51
當時在一個大賣場舉辦的好像是一場什麼內衣特賣會吧

01:15:51 - 01:15:54
當時現場有很多女性蜂擁而至

01:15:54 - 01:15:56
這時候有個男生路過了

01:15:56 - 01:15:59
男生看到有個女生的身材好像還不錯

01:15:59 - 01:16:00
男生就伸手去揉捏那個女生的胸部

01:16:00 - 01:16:01
倒不知道該怎麼反應，

01:16:01 - 01:16:04
所以這個女生並沒有任何反抗或者是拒絕的動作，

01:16:04 - 01:16:06
就是完全被嚇到無法動彈，

01:16:07 - 01:16:08
所以就任由那個男生去摸。

01:16:08 - 01:16:10
後來這個舉動啊被路人看到,

01:16:10 - 01:16:11
所以男生被扭送法辦。

01:16:11 - 01:16:14
問說這個男生犯什麼罪。

01:16:15 - 01:16:17
現在來說比較沒有什麼疑問,

01:16:17 - 01:16:21
趁別人來不及防備，偷偷去偷襲別人。

01:16:21 - 01:16:26
來，這個東西，我們來看一下那個338頁。

01:16:26 - 01:16:29
這個叫性騷擾防治法第25條。

01:16:29 - 01:16:30
好，你看喔，

01:16:30 - 01:16:39
性騷擾防治法第25條說，意圖性騷擾，趁人不及抗拒而為親吻、擁抱、觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處的行為，

01:16:39 - 01:16:40
這個叫做……

01:16:40 - 01:16:41
這個犯罪,我跟你們講,

01:16:42 - 01:16:44
這一條罪我們叫它強制觸摸罪。

01:16:45 - 01:16:47
但為什麼叫強制其實很奇怪,

01:16:47 - 01:16:49
它沒有強制的成分啊,

01:16:49 - 01:16:53
所以這一條罪,我們學者一般是叫它性騷擾罪

01:16:53 - 01:16:55
或者叫他偷襲觸摸罪。

01:16:56 - 01:16:57
知道吧,俗話叫他強制觸摸啦,

01:16:58 - 01:16:59
可是他真的沒有強制的成分。

01:17:00 - 01:17:05
所以學者一般會叫他,比如說叫他性騷擾罪,或者叫他偷襲式,叫他偷襲觸摸罪。

01:17:06 - 01:17:08
好,現在來說的話,行為人一定是論這一條罪嘛,

01:17:08 - 01:17:09
對不對?

01:17:09 - 01:17:10
這個沒有疑問。

01:17:11 - 01:17:13
好，那你知道嗎？在以前，

01:17:15 - 01:17:17
那個摸胸始末案發生的時候，

01:17:18 - 01:17:21
當時性騷擾防治法第25條還沒有公佈施行。

01:17:22 - 01:17:23
對,當時還沒有這個法律。

01:17:23 - 01:17:25
所以你說當時怎麼辦?

01:17:25 - 01:17:29
對啊你想,在還沒有偷襲觸摸罪的時候,

01:17:30 - 01:17:34
這種趁別人不備而去摸別人胸部的行為,怎麼論罪?

01:17:35 - 01:17:36
你可不可以論強制?

01:17:36 - 01:17:39
好，說強制猥褻，違反被害人的意願。

01:17:39 - 01:17:41
可是被害人就沒有表意啊。

01:17:42 - 01:17:44
當然啦，有些人會說被害人一定不想被摸，

01:17:44 - 01:17:46
對，我同意，被害人他確實不想被摸，

01:17:46 - 01:17:50
可是你說被害人一定不想被摸，那個叫可推知的意願。

01:17:50 - 01:17:54
通說不認為這種可推知的意願的違反，可以算是24。

01:17:54 - 01:17:55
瞭解嗎？

01:17:55 - 01:17:57
所以這一種案例，以前你論強制很難法論。

01:17:58 - 01:18:00
那你說可不可以論趁機，25。

01:18:01 - 01:18:08
可是趁機條文講說要趁人精神身體障礙、其智缺陷，或其它類似的情形，不能或不知抗拒。

01:18:08 - 01:18:11
趁機要是被害人處於一個身心有問題的狀態喔。

01:18:12 - 01:18:13
單純偷襲是不算的喔。

01:18:13 - 01:18:17
所以這一種案例過去會落入一個無法可論的窘境。

01:18:17 - 01:18:23
所以當時，一審法院對這個摸胸十秒案的被告，法院是判他無罪。

01:18:24 - 01:18:25
法院判無罪。

01:18:25 - 01:18:26
判無罪很合理。

01:18:27 - 01:18:28
不是說摸胸是對的，而是很簡單嘛，法律。

01:18:30 - 01:18:31
摸胸及起網咖。

01:18:32 - 01:18:35
行為時，性騷擾防治法第25條還沒有施行啊。

01:18:36 - 01:18:40
那刑法既有的條文也沒辦法處罰這種案例，要判無罪不是合理嗎？

01:18:40 - 01:18:43
結果當時這個判決出來之後啊，很多人對這個判決誤會了。

01:18:44 - 01:18:47
甚至啊，還有婦女團體也出面行動。

01:18:47 - 01:18:49
說，那還不簡單。

01:18:50 - 01:18:52
說摸不到十秒就無罪。

01:18:52 - 01:18:58
那我以後是不是一邊摸胸一邊按碼錶，12345678，快死的時候趕快收手，這樣就無罪了。

01:18:58 - 01:19:00
沒有啦，跟秒數沒有關係啦。

01:19:00 - 01:19:02
重點就是被害人他沒有反抗。

01:19:02 - 01:19:06
被害人沒有反抗，沒有表意的話，就很難認為是違反意願啊，這就條文的規定啊，對不對？

01:19:09 - 01:19:12
所以，這件原本就應該無罪。

01:19:13 - 01:19:17
結果呢，後來法院判無罪之後啊，社會輿論群起反彈嘛。

01:19:18 - 01:19:20
那你們也知道我們的最高法院是很軟的。

01:19:20 - 01:19:23
我們的最高法院就很喜歡跟民意妥協。

01:19:24 - 01:19:24
我就常覺得啊,

01:19:25 - 01:19:27
為什麼我們的最高法院不能對自己有點信心？

01:19:27 - 01:19:32
當自己的判決違反國民的反感情緒的時候，為什麼不硬起來跟國民的反感情緒對幹？

01:19:33 - 01:19:35
說是你們沒禮貌又硬拗，又不是我們的問題。

01:19:35 - 01:19:36
對，為什麼最高法院不敢，我不太懂啊，就

01:19:37 - 01:19:39
那麼喜歡跟民意妥協。

01:19:39 - 01:19:43
好，所以後來呢，最高法院做成一個決議，97年第五次決議。

01:19:44 - 01:19:47
這個975的決議啊，我必須跟各位這樣說。

01:19:48 - 01:19:50
975這個決議就字面來說,

01:19:50 - 01:19:52
我不會說它有什麼問題。

01:19:53 - 01:19:54
你看975的決議說什麼呢?

01:19:55 - 01:20:00
他說其他違反意願的方法，是指強暴脅迫恐嚇。

01:20:00 - 01:20:00
這美術以外,一切違反別人意願的方法可言。

01:20:03 - 01:20:10
不以類似強暴脅迫等等的強制方法，足以壓制性自主權為必要，始符合立法的本質。

01:20:11 - 01:20:12
那我跟各位說啊。

01:20:13 - 01:20:16
975的決議，你從他的字面來說。

01:20:17 - 01:20:18
他還沒有什麼錯。

01:20:19 - 01:20:23
因為975的字面就是跟你說他不採高度強制手段說。

01:20:24 - 01:20:26
那不採高度強制手段說的話。

01:20:27 - 01:20:30
也合理啊，因為高度強制手段來說，他本來就是有問題的說法。

01:20:30 - 01:20:30
啊。

01:20:30 - 01:20:35
我上次是不是講過，高度強制手段說會有架空概括條款的疑慮。

01:20:36 - 01:20:37
有印象吧，我上次講過吧。

01:20:37 - 01:20:43
對，所以975的決議說他不採高度強制手段，OK，到這邊還沒有什麼問題。

01:20:43 - 01:20:51
可是你知道嗎，975的決議當初做成的背景，是要讓這種偷襲別人胸部的人可以成立強制猥褻罪。

01:20:52 - 01:20:53
這就有問題了。

01:20:54 - 01:20:54
好吧，這個就有問題了。

01:20:55 - 01:21:00
因為你要想喔，這種偷襲別人胸部的人，如果可以論強制猥褻罪的話。

01:21:00 - 01:21:02
那第一個照這種說法。

01:21:02 - 01:21:05
那是不是單純違反可推知意願也算違反意願。

01:21:05 - 01:21:10
那違反可推知意願，也算是221224的違反意願的話。

01:21:11 - 01:21:13
這樣下去會造成很大的問題啦。

01:21:14 - 01:21:17
這樣子的話等於是根本顛覆了我們性犯罪既有的結構。

01:21:17 - 01:21:19
甚至也會有罪刑法定的問題存在。

01:21:21 - 01:21:21
這是第一個。

01:21:22 - 01:21:22
還有喔。

01:21:23 - 01:21:30
如果違反別人可推知的意願，也可以論224，這種摸胸10秒也可以論24的話。

01:21:30 - 01:21:32
那性騷擾防治法什麼時候用？

01:21:33 - 01:21:34
那個條文是不是被架空了。

01:21:35 - 01:21:35
對啊，沒有錯啊。

01:21:35 - 01:21:38
所以這個決議做成之後，學者都一直罵。

01:21:38 - 01:21:41
說你這樣搞，性騷擾防治法根本沒有適用的空間。

01:21:42 - 01:21:44
罵到後來政府大概有這樣的意識。

01:21:45 - 01:21:47
所以後來食物過了幾年呢？

01:21:48 - 01:21:48
又。

01:21:48 - 01:21:49
又做出了醫者的判決。

01:21:50 - 01:21:50
我。

01:21:50 - 01:21:50
看一下喔。

01:21:54 - 01:21:56
後來的話呢,在93巷這邊。

01:21:57 - 01:21:59
住93巷這邊呢,後來食物經過了

01:22:00 - 01:22:00
的十幾年,終於發現他們當初的說法是錯的,所以現在食物的做法比較能回歸一般的正軌。

01:22:07 - 01:22:11
我們再講一次,強制猥褻跟性騷擾怎麼區分?

01:22:11 - 01:22:15
性騷擾叫做偷襲,叫做被害人來不及表意。

01:22:16 - 01:22:21
所以那一種偷襲的，被害人來不及表意的，我們論性騷擾。

01:22:21 - 01:22:27
那如果是被害人已經有明確的反對的，那個我們才能論強制猥褻。

01:22:27 - 01:22:28
就這麼簡單，好嗎？

01:22:28 - 01:22:29
就這麼簡單喔。

01:22:30 - 01:22:30
所以

01:22:31 - 01:22:32
我舉例喔。

01:22:32 - 01:22:39
假設我轉身寫黑板的時候，杜伯言突然衝進教室，摸我的鳥，摸兩秒他人就跑了。

01:22:39 - 01:22:40
這時候是什麼？

01:22:41 - 01:22:42
性騷擾，知道嗎？

01:22:42 - 01:22:42
這時候性騷擾。

01:22:43 - 01:22:49
那如果是杜伯進到教室之後，他不是摸兩秒喔，他是伸手一直抓我的鳥。

01:22:49 - 01:22:54
我這時候說混蛋啊，不要再抓了，我想要把他的手掰開，但怎麼掰都掰不開，他就一直抓著。

01:22:54 - 01:22:55
這時候是什麼？

01:22:55 - 01:22:56
強制猥褻。

01:22:57 - 01:22:57
很有畫面吧，對不對？

01:22:57 - 01:22:59
那光頭長那麼猥褻，感覺他會做這種事吧。

01:23:00 - 01:23:03
所以這種案例呢，才會變成是強制猥褻。

01:23:04 - 01:23:04
好，所以這個是

01:23:06 - 01:23:07
某胸十秒案。

01:23:07 - 01:23:08
目前訴的做法。

01:23:09 - 01:23:12
所以目前的食物這繞了那麼多年，現在終於正確了。

01:23:12 - 01:23:13
最後來第四點，加重強制猥褻。

01:23:17 - 01:23:19
這一條的加重強制猥褻啊，

01:23:20 - 01:23:23
可能其實上會有一個疑問是這樣子啦。

01:23:24 - 01:23:24
因為

01:23:24 - 01:23:25
你不能說疑問啦,應該說這個條文,它很沒有存在感。

01:23:27 - 01:23:30
所以同學很容易會忘記它,加重強制猥褻。

01:23:32 - 01:23:35
也就是行為人強制猥褻被害人的時候,

01:23:35 - 01:23:37
如果他同時有222各款的情形,

01:23:40 - 01:23:45
這時候就會升級,變成加重強制猥褻罪。

01:23:46 - 01:23:47
這個很容易會忘記喔。

01:23:49 - 01:23:52
所以我這邊講一個老笑話，幫助同學記得這個案例。

01:23:53 - 01:23:54
這個笑話是這麼說的，就是呢有一天，金庫銀行發生了搶案。

01:23:57 - 01:23:59
金庫銀行發生搶案，來

01:24:00 - 01:24:04
某面持槍闖入了金庫銀行。

01:24:04 - 01:24:09
女行員看到歹徒之後，女行員就跟那個歹徒講，說先生啊，你搞錯了。

01:24:11 - 01:24:13
我們這邊是金子銀行，沒有錢的。

01:24:14 - 01:24:16
歹徒說沒有沒有，我沒有搞錯。

01:24:16 - 01:24:19
接著歹徒就拿著槍逼著女行員，你拿出一罐金子。

01:24:21 - 01:24:23
女行員覺得莫名其妙，這是什麼搶案喔。

01:24:23 - 01:24:24
歹徒有槍嗎。

01:24:25 - 01:24:26
女行員只好配合，拿出一罐。

01:24:27 - 01:24:30
歹徒就逼著那個女行員，拿出金子來。

01:24:30 - 01:24:31
喝下去。

01:24:31 - 01:24:34
女行員就更莫名其妙的，這是什麼搶案嘛。

01:24:34 - 01:24:36
但沒辦法，只好配合嘛，喝了一罐。

01:24:36 - 01:24:41
喝了一罐之後，歹徒又逼著女行員，你再拿一罐，再喝一罐。

01:24:42 - 01:24:44
女行員照做啊，又喝第二罐。

01:24:45 - 01:24:51
好，女行員喝下第二罐之後，某面的歹徒脫下面罩，行員嚇傻了。

01:24:51 - 01:24:53
竟然是她老公。

01:24:54 - 01:24:56
這時候啊，歹徒講了一句話。

01:24:56 - 01:24:57
說：「親愛的老婆啊，」

01:24:58 - 01:25:00
「喝金子這件事沒有那麼難。

01:25:00 - 01:25:03
難嘛，你看妳做到了啦，那為什麼我平常叫妳做，妳就是做不到呢？」

01:25:04 - 01:25:05
好，這個笑話到這邊為止。

01:25:06 - 01:25:08
這個案例當中，歹徒論什麼罪？

01:25:10 - 01:25:11
好，歹徒論什麼罪？

01:25:12 - 01:25:13
來逼別人喝金子？

01:25:14 - 01:25:15
這是不是強制猥褻？

01:25:16 - 01:25:16
是喔。

01:25:17 - 01:25:20
你逼別人吃韭菜水餃，這是一般的強制。

01:25:21 - 01:25:23
但你逼別人吃精液，那個是猥褻喔。

01:25:24 - 01:25:25
應該沒有疑問吧，這猥褻喔。

01:25:26 - 01:25:27
所以這裡的話是強制猥褻。

01:25:28 - 01:25:31
而且這裡會升級變加重，為什麼？

01:25:31 - 01:25:33
因為期待兇器。

01:25:33 - 01:25:34
好吧，因為期待兇器。

01:25:35 - 01:25:37
那他逼被害人喝兩罐是論一罪還是兩罪？

01:25:38 - 01:25:39
論一罪。

01:25:39 - 01:25:39
為什麼？

01:25:39 - 01:25:40
因為繼續犯。

01:25:40 - 01:25:40
好吧。

01:25:41 - 01:25:42
所以後啊，告訴乃論還是非告訴乃論？

01:25:45 - 01:25:46
非告訴乃論，為什麼？

01:25:47 - 01:25:49
因為夫妻間犯什麼才是告訴乃論，221跟224。

01:25:51 - 01:25:53
但這一題升級變224之一，所以這一題是非告訴乃論。

01:25:56 - 01:25:58
所以這個笑話超多刑法爭點在裡面的。

01:25:59 - 01:26:00
我當初看到的時候笑死了。

01:26:00 - 01:26:02
這個笑話是不是法律系教授想出來的？

01:26:02 - 01:26:03
根本一堆刑法爭點。

01:26:03 - 01:26:04
記得這個笑話喔,

01:26:04 - 01:26:05
不要忘記24之一喔。

01:26:06 - 01:26:06
好。

01:26:08 - 01:26:10
接下來我們來看到228。

01:26:10 - 01:26:12
228，利用權勢。

01:27:16 - 01:27:16
好,

01:27:17 - 01:27:18
接著來339頁這邊,

01:27:18 - 01:27:20
我們來看一下喔。

01:27:20 - 01:27:23
228條這個條文叫做利用權勢,

01:27:23 - 01:27:24
性交猥褻罪。

01:27:24 - 01:27:27
這一條罪最常見的兩大樣態,

01:27:27 - 01:27:28
第一個是利用,

01:27:28 - 01:27:29
第二個是詐欺,

01:27:29 - 01:27:31
這兩類是相對常見的。

01:27:31 - 01:27:34
至於權勢關係下的脅迫可不只這條罪,

01:27:34 - 01:27:35
這個我們等一下再說。

01:27:35 - 01:27:38
我們先想一下二二八條最典型的案例是這樣子。

01:27:38 - 01:27:39
好,

01:27:39 - 01:27:39
比如說有一個,

01:27:40 - 01:27:40
好,

01:27:40 - 01:27:42
比如說有一個女大生啊,

01:27:42 - 01:27:44
她的必修課快要被當了。

01:27:44 - 01:27:46
而這個必修課被當,

01:27:46 - 01:27:48
會延續著影響到她大二大三的必修課,

01:27:48 - 01:27:50
因為那是一個重要的必修會擋修。

01:27:51 - 01:27:51
所以呢,

01:27:52 - 01:27:53
這個女大生,

01:27:54 - 01:27:54
她就想說怎麼辦,

01:27:54 - 01:27:55
怎麼辦。

01:27:55 - 01:27:57
於是教授跟那個女大生講,

01:27:57 - 01:27:58
說你一修課被當了喔。

01:27:59 - 01:28:00
啊如果,

01:28:00 - 01:28:04
你不想被當吼,沒關係,你晚上來陪我睡,你晚上來陪我睡吼,我保證讓你高分過關。

01:28:06 - 01:28:14
那這個女大生就心裡很猶豫,他就想說這個教授又肥又禿,真的不想跟他怎麼樣,可是因為如果被當的話很麻煩。

01:28:14 - 01:28:16
後面都會擋修,甚至會延畢,算了。

01:28:16 - 01:28:19
免為其難就跟這個教授睡一下好了。

01:28:19 - 01:28:23
這時候教授犯的就是二二八的罪行。

01:28:23 - 01:28:24
所以二二八是這樣喔。

01:28:25 - 01:28:27
行為人處於優勢的社會地位。

01:28:28 - 01:28:32
這一個處於優勢社會地位的行為人。

01:28:33 - 01:28:41
他濫用他的優勢社會地位，而讓這個處於劣勢社會地位的行為人發生性關係。

01:28:41 - 01:28:44
這是228他所要處罰的對象。

01:28:44 - 01:28:47
好，那我們來看到339頁這邊吼。

01:28:49 - 01:28:51
這一條它不是純粹優勢跟劣勢而已喔。

01:28:52 - 01:28:55
而是他條文列了九種權勢關係。

01:28:55 - 01:28:55
來，你看他說吼。

01:28:56 - 01:29:00
親屬、監護、教養、教育訓練、

01:29:00 - 01:29:04
救濟、醫療、僱傭或其它相類

01:29:04 - 01:29:06
而受自己怎麼樣呢？

01:29:07 - 01:29:10
監督、扶助或照顧之人。

01:29:10 - 01:29:12
所以我們看清楚吼。

01:29:12 - 01:29:12
要論。

01:29:12 - 01:29:20
228的話，除了雙方的社會地位不對等之外，這個不對等的地位要是怎麼樣？

01:29:20 - 01:29:23
監督、扶助或照顧。

01:29:23 - 01:29:23
所以房東跟房客有沒有算？

01:29:23 - 01:29:23
欸，沒有喔。

01:29:23 - 01:29:23
房東跟房客不算喔。

01:29:23 - 01:29:24
年輕女房客付不出房租。

01:29:24 - 01:29:24
房東就說你來陪我睡。

01:29:24 - 01:29:24
睡兩晚就可以抵房租。

01:29:24 - 01:29:25
女房客可能覺得說那個房東好噁。

01:29:25 - 01:29:25
就真的不想，可是沒錢了嘛，怎麼辦，只好照做。

01:29:25 - 01:29:25
這種情況的話，房東不會有事喔。

01:29:25 - 01:29:26
租賃關係的雙方確實社會地位不對等，沒有錯。

01:29:26 - 01:29:26
但租賃關係並沒有這種監督扶助或照顧，沒有。

01:29:26 - 01:29:26
所以這個不算。

01:29:26 - 01:29:26
好。

01:29:26 - 01:29:27
再來第二個案例吼，我們也強調。

01:29:27 - 01:29:27
權勢關係必須在行為時存在。

01:29:27 - 01:29:27
過去存在過的或將來有機會開啟的，那個也都不算喔。

01:30:00 - 01:30:00
所以比如說，大學畢業生

01:30:03 - 01:30:06
畢業好幾年啊，突然想考原本學校的研究所。

01:30:07 - 01:30:13
他就約以前的老師，問說老師啊，我想回來考研究所啊，那我該怎麼準備呢？

01:30:13 - 01:30:20
而以前的老師啊，卻跟這個女大生說，你想考啊，那晚上來陪我睡，我就跟你講考題。

01:30:21 - 01:30:25
女大生原本不想，但後來她就真的很想念研究所，所以免為其難跟教授睡了。

01:30:26 - 01:30:28
這時候教授會成立二二八嗎？

01:30:28 - 01:30:29
不會喔，為什麼？

01:30:29 - 01:30:30
因為

01:30:30 - 01:30:30
第一個

01:30:31 - 01:30:34
過去的師生關係結束啦,那女生早就畢業啦,對不對？

01:30:35 - 01:30:36
那你說將來的呢？

01:30:36 - 01:30:38
將來的又不一定會開啟。

01:30:38 - 01:30:42
你想啊，教授洩題，女大生又不見得考得上。

01:30:42 - 01:30:44
你又不是隻有一個教授出題，對不對？

01:30:44 - 01:30:48
考上之後，這個女大生也不見得會去找這個教授當指導啊。

01:30:49 - 01:30:50
也不見得會修他的課啊，這很難講，對不對？

01:30:51 - 01:30:54
所以這種情況的話呢，當然二二八就不會成立喔。

01:30:54 - 01:30:55
好

01:30:55 - 01:30:56
接著我們翻過來。

01:30:57 - 01:30:58
340頁。

01:30:59 - 01:30:59
好

01:31:00 - 01:31:01
這一條罪的行為，我們講

01:31:02 - 01:31:05
濫用權勢而為性交或猥褻。

01:31:06 - 01:31:08
這一條啊,不是純粹的利用喔。

01:31:09 - 01:31:10
這一條的重點叫做濫用。

01:31:11 - 01:31:13
單純的利用不算。

01:31:13 - 01:31:17
因為我們要講啊,如果只是單純的利用,刑法介入幹什麼？

01:31:18 - 01:31:20
比如說有一個醫師。

01:31:20 - 01:31:25
他剛好遇到一個車禍受傷住院的年輕女傷患。

01:31:25 - 01:31:27
那雙方在病房看對眼啦。

01:31:28 - 01:31:30
看對眼之後，兩個人就在病房

01:31:30 - 01:31:30
打了一炮啦。

01:31:31 - 01:31:32
你罰這個幹什麼？

01:31:32 - 01:31:34
對啊，這個這沒什麼好罰的啊。

01:31:34 - 01:31:36
所以很明顯啊，這一條所處罰的對象

01:31:36 - 01:31:39
不是單純的利用，而是涉及到濫用。

01:31:41 - 01:31:44
濫用的話，通常就是上面這幾種情況。

01:31:45 - 01:31:46
第一個是利用。

01:31:47 - 01:31:48
第二個是詐欺。

01:31:48 - 01:31:50
這兩種是濫用最常見的。

01:31:50 - 01:31:50
好。

01:31:50 - 01:31:51
那接下來，問題。

01:31:53 - 01:31:54
怎麼樣的情況

01:31:54 - 01:31:56
我們可以認為有濫用呢？

01:31:57 - 01:32:00
通常我們會說，因為條文他列的窮

01:32:00 - 01:32:01
有九種不同的權勢關係。

01:32:02 - 01:32:03
所以啊，

01:32:03 - 01:32:06
當行為人跟被害人之間，

01:32:06 - 01:32:08
他們的連結越緊密，

01:32:09 - 01:32:11
行為人對被害人的監督越緊密，

01:32:12 - 01:32:13
越不可分的時候，

01:32:14 - 01:32:14
這時候呢，

01:32:15 - 01:32:17
我們就越容易認定濫用。

01:32:17 - 01:32:18
反之，

01:32:18 - 01:32:21
當行為人跟被害人之間的關係越鬆散的時候，

01:32:21 - 01:32:22
這時候呢，

01:32:22 - 01:32:27
往往就必須其行為跟具體事物之間有產生連接。

01:32:27 - 01:32:28
我們才會認為說,

01:32:28 - 01:32:31
這是一種權勢關係的濫用。

01:32:32 - 01:32:32
好,

01:32:32 - 01:32:33
我這樣舉例,

01:32:33 - 01:32:34
什麼叫具體事物的連結？

01:32:36 - 01:32:37
來比如說那個,

01:32:37 - 01:32:38
在研究所當中,

01:32:39 - 01:32:41
指導教授跟女學生,

01:32:41 - 01:32:42
好,

01:32:42 - 01:32:44
比如說男指導教授跟女研究生之間呢,

01:32:44 - 01:32:45
有曖昧關係。

01:32:46 - 01:32:50
後來教授跟女學生在研究室打了一砲。

01:32:51 - 01:32:53
那女學生其實

01:32:53 - 01:32:55
也沒有說真的多喜歡這個教授。

01:32:55 - 01:32:58
女學生她只是心中暗暗想著說

01:32:58 - 01:33:00
那跟教授有了性關係之後，

01:33:00 - 01:33:03
自己的論文應該比較容易過關吧？

01:33:03 - 01:33:04
女研究生是這樣想的，

01:33:05 - 01:33:06
但她並沒有跟教授提出這樣的要求，

01:33:07 - 01:33:08
教授也沒有說。

01:33:08 - 01:33:10
雙方就是在氣氛最佳的情況[redacted] 下,

01:33:10 - 01:33:11
在研究室打了一炮。

01:33:12 - 01:33:12
這樣的情況之下,

01:33:13 - 01:33:14
你會說教授犯了二二八嗎?

01:33:15 - 01:33:15
不會,

01:33:16 - 01:33:16
為什麼？

01:33:16 - 01:33:17
因為第一個，

01:33:18 - 01:33:19
教授跟女研究生之間，

01:33:20 - 01:33:21
確實啦，

01:33:21 - 01:33:23
他們是一種教育關係的不對等地位。

01:33:23 - 01:33:24
沒有錯。

01:33:24 - 01:33:25
可是你要想喔,

01:33:26 - 01:33:28
研究所的指導教授跟女研究生,

01:33:29 - 01:33:32
他們會有很強的這種日常生活的連結或照護的關係嗎?

01:33:33 - 01:33:33
不會嘛,

01:33:34 - 01:33:38
因為研究所的教授跟學生之間有點像是那種放牛吃草的關係。

01:33:38 - 01:33:40
就如果你讀過研究所就知道，

01:33:40 - 01:33:41
研究所當中啊，

01:33:42 - 01:33:44
教授不會像爸爸媽媽一樣每天盯著你說，

01:33:44 - 01:33:46
同學論文寫到第幾頁啦。

01:33:46 - 01:33:46
不會啦。

01:33:47 - 01:33:48
你不寫教授也不會管你啦,

01:33:48 - 01:33:49
因為教授會想說,

01:33:49 - 01:33:51
你要不要這個學位你自己拉倒吧,

01:33:51 - 01:33:52
教授一定是這樣啦,

01:33:52 - 01:33:53
一定的啦。

01:33:54 - 01:33:54
所以，

01:33:55 - 01:33:56
在研究所的師生關係當中，

01:33:57 - 01:33:58
老師跟學生的關聯性，

01:33:58 - 01:34:00
沒有到這麼的緊密。

01:34:00 - 01:34:06
所以如果這個時候性行為沒有跟一個具體事物產生連接的話，我們就不會說這個叫濫用，知道嗎？

01:34:07 - 01:34:10
所以在同樣這種研究所的師生關係當中，

01:34:10 - 01:34:13
如果是指導教授跟女研究生說，

01:34:13 - 01:34:14
你那個論文寫那麼爛，

01:34:14 - 01:34:15
沒有看外文，

01:34:15 - 01:34:17
你是畢不了業啦，

01:34:17 - 01:34:19
如果你想要拿到學位，沒關係，

01:34:19 - 01:34:20
你跟我說一下，

01:34:20 - 01:34:21
我就讓你拿到學位。

01:34:22 - 01:34:23
就會有28。

01:34:23 - 01:34:28
這個會有，這就叫做性行為跟具體事物要連接，懂這意思，這個就要有連接。

01:34:30 - 01:34:32
好，那麼相對來說。

01:34:34 - 01:34:37
有些情況當中。

01:34:37 - 01:34:42
因為行為人跟被害人之間，他們的關聯性很親密。

01:34:42 - 01:34:46
行為人對被害人幾乎是一種有點像那種保母的關係。

01:34:47 - 01:34:48
他們的生活關係是非常親密的。

01:34:49 - 01:34:56
那麼在行為人跟被害人之間的關係是很親密的情況之下，那往往會是什麼樣的，會是隻要有這個關係存在。

01:34:57 - 01:34:58
而性關係發生。

01:34:59 - 01:35:00
這樣28。

01:35:00 - 01:35:01
就會成立。

01:35:01 - 01:35:04
不再要求性行為跟具體事物之間有所連接。

01:35:05 - 01:35:06
比如說。

01:35:06 - 01:35:09
監護人跟被監護的未成年人之間。

01:35:12 - 01:35:13
舉個例子來說。

01:35:13 - 01:35:15
如果有個高中少女。

01:35:15 - 01:35:17
她滿16歲的，但她父母雙亡。

01:35:18 - 01:35:26
所以這個高中少女呢，被他的被誰啊，比如說被他的伯父好了，伯父當他的監護人。

01:35:26 - 01:35:28
那這個高中少女呢。

01:35:29 - 01:35:32
他就當他伯父的被監護人嘛,等於伯父當他監護人。

01:35:32 - 01:35:35
那伯父就提議跟那個高中少女性交。

01:35:36 - 01:35:39
這樣的話這個伯父會不會有228的犯罪。

01:35:40 - 01:35:41
會有。

01:35:41 - 01:35:45
因為監護人跟被監護人之間，那個幾乎是一種家長的關係嘛。

01:35:46 - 01:35:48
那個日常生活的連結是很親密的。

01:35:48 - 01:35:51
所以在雙方當事人的關係是如此親密的情況之下。

01:35:52 - 01:35:54
我們就很容易認為這個是濫用。

01:35:54 - 01:35:57
而不再需要性行為跟具體事物有連結。

01:35:57 - 01:35:58
懂意思吧？

01:35:58 - 01:36:00
所以這個就是我們具體的判準。

01:36:00 - 01:36:01
所以下面就說了，

01:36:03 - 01:36:04
第二點的後面，

01:36:04 - 01:36:06
原則上有沒有，你看到倒數這樣這邊，

01:36:06 - 01:36:10
原則上優勢地位者的掌握支配力越弱,

01:36:11 - 01:36:12
當事人的關係就越鬆散,

01:36:12 - 01:36:17
性行為就越需要跟具體事物有連結，才能認為是濫用,

01:36:17 - 01:36:18
反過來就不用,

01:36:18 - 01:36:19
大概是這個道理

01:36:19 - 01:36:20
知道嗎？

01:36:22 - 01:36:25
好，所以這個是我們這邊講具體事物的連接。

01:36:26 - 01:36:29
那同樣是教育關係，

01:36:29 - 01:36:30
通常，

01:36:31 - 01:36:36
這個教育的，你要講教育的水準嘛，反正就是越高等的教育。

01:36:36 - 01:36:39
老師跟學生之間的關係，通常就是越...

01:36:40 - 01:36:43
怎麼講，你要說越淡嗎？就是越鬆散啦。

01:36:43 - 01:36:45
你想嘛，同樣是老師跟學生，

01:36:46 - 01:36:48
指導教授跟他的碩博士生，

01:36:49 - 01:36:52
跟那個國小的老師跟學生，關係一定不一樣嘛。

01:36:52 - 01:36:56
因為國小老師跟學生有點像是那種家長跟小孩的關係。

01:36:56 - 01:36:58
但到了高等教育，一定不是嘛。

01:36:58 - 01:37:00
這個道理同學應該可以理解。

01:37:00 - 01:37:02
好，那前幾年有個問題，

01:37:02 - 01:37:06
那補習班的老師跟學生有這樣的權勢關係嗎？

01:37:07 - 01:37:08
補習班你要看喔,

01:37:08 - 01:37:10
安親班那一種是有的喔。

01:37:11 - 01:37:14
因為安親班如果學生考不好的話,可能老師會跟家長告狀,

01:37:15 - 01:37:18
或者老師可能會一定程度的去懲罰那個學生,

01:37:18 - 01:37:20
逼他罰寫啊,留下來啊或什麼的,

01:37:20 - 01:37:24
所以安親班的老師跟學生之間，有喔，他是有權勢關係的喔。

01:37:24 - 01:37:27
那我們這種補習班的老師跟學生呢？

01:37:27 - 01:37:29
我跟你們有沒有性別權勢的關係？

01:37:30 - 01:37:32
不要講我，我不會對你們做這種事。

01:37:32 - 01:37:35
杜博言啊，杜博言跟你們有沒有這種關係？

01:37:36 - 01:37:36
當然沒有。

01:37:37 - 01:37:38
因為我們這種補習班，

01:37:39 - 01:37:41
你沒有負擔任何的義務啊。

01:37:42 - 01:37:42
對不對？

01:37:43 - 01:37:47
在這種補習班當中，你繳的錢，你是取得來上課的權利。

01:37:47 - 01:37:49
你並沒有負擔任何的義務，

01:37:49 - 01:37:52
如果你繳了錢之後，你從此再也不來上課了，

01:37:52 - 01:37:54
我也不可能對你怎麼樣嘛。

01:37:54 - 01:37:56
甚至是你們叫什麼名字，我也不知道嘛，

01:37:56 - 01:37:57
對啊，我能對你怎麼樣？

01:37:57 - 01:38:00
所以在我們這種補習班當中，當然沒有。

01:38:00 - 01:38:02
這種權序關係的存在。

01:38:02 - 01:38:05
我對你們沒有任何考核監督的權限。

01:38:05 - 01:38:07
完全沒有，零，完全沒有。

01:38:08 - 01:38:09
你說啊集訓班的一種呢？

01:38:10 - 01:38:12
集訓班我確實可以對同學打分數沒有錯。

01:38:12 - 01:38:15
可是同學一起都考不好,我一直教法律不是胡亂。

01:38:16 - 01:38:17
那我實在對同學怎麼樣？

01:38:17 - 01:38:20
又不是說考得太爛叫退訓或什麼的,沒有嘛,對不對？

01:38:21 - 01:38:23
所以在我們這種補習班呢,沒有二八的關係,知道嗎？

01:38:23 - 01:38:24
我們補習班沒有啦。

01:38:26 - 01:38:28
甚至我有的時候都開玩笑的說啦。

01:38:29 - 01:38:32
我對你們沒有考核監督的關係，但你們對我有。

01:38:33 - 01:38:34
你們不是寫過課堂反應問卷？

01:38:35 - 01:38:35
沒有嗎？

01:38:36 - 01:38:36
現在還沒有。

01:38:37 - 01:38:40
我記得補習班每年都會有這個東西啊，課堂反應問卷。

01:38:40 - 01:38:40
你們知道嗎？

01:38:41 - 01:38:46
如果你們在課堂反應問卷當中，對我的評價都選最爛的那一邊。

01:38:47 - 01:38:49
上課態度散漫，那個講一堆廢話，口條又差，然後教材又沒有更新，選最爛那一邊。

01:38:54 - 01:38:55
明年可能看不到我的。

01:38:56 - 01:38:59
真的啊,所以我對你們沒有考核的權限,但你們對我有,所以在這種補習班當中呢,我們並沒有二八的關係喔。

01:39:02 - 01:39:02
好。

01:39:03 - 01:39:05
請至341頁，本罪的具體類型。

01:39:07 - 01:39:07
第一個。

01:39:08 - 01:39:09
本罪最常見的叫做利用，這個沒有疑問哈，利用。

01:39:11 - 01:39:15
也就是請人為他去，用這個利益交換，這個叫利用，像我們剛剛講的，這個老師對學生哈。

01:39:19 - 01:39:20
接著來下面欺騙。

01:39:22 - 01:39:23
欺騙這個是有可能的哦。

01:39:25 - 01:39:26
你說這個是什麼樣的情況？

01:39:27 - 01:39:31
這種欺騙,比較容易發生在醫療關係當中。

01:39:32 - 01:39:33
也就是啊,醫師濫用他的地位,讓病患去配合作成,原本根本不需要的性接觸。

01:39:42 - 01:39:44
這是以前發生過的喔,我們翻到342頁。

01:39:48 - 01:39:49
就是右下角這一題。

01:39:51 - 01:39:52
就是右下角這一題。

01:39:53 - 01:39:55
這一題我簡單講的事實啦，我簡單講的事實。

01:39:56 - 01:39:59
就是有個女生他去醫院做健康檢查。

01:39:59 - 01:40:00
那你

01:40:00 - 01:40:05
去醫院做健康檢查的時候啊，其實這個健康檢查根本就沒有乳房跟婦科的項目。

01:40:06 - 01:40:12
可是醫生卻跟這個女生謊稱說，我要幫你檢查婦科，看你的陰道跟子宮頸有沒有問題。

01:40:13 - 01:40:15
就謊稱要幫女生做這個檢查。

01:40:15 - 01:40:16
那女生不知道嘛，就配合。

01:40:17 - 01:40:21
結果後來才知道，原來這個健康檢查真的沒有婦科的項目，而且醫生當初用手伸到她的陰道。

01:40:25 - 01:40:28
這也只是滿足醫生自己的性慾而已。

01:40:28 - 01:40:30
根本沒有任何醫學上檢查的意義。

01:40:31 - 01:40:33
所以這時候呢,醫生可以論什麼罪?

01:40:34 - 01:40:35
知道嗎?

01:40:35 - 01:40:40
所以醫生利用他的優勢地位,欺騙病患,讓病患做成原本不需要的性接觸。

01:40:43 - 01:40:45
這也是一種濫用喔,知道嗎?

01:40:45 - 01:40:47
這也是一種濫用,因為你想嘛。

01:40:48 - 01:40:53
我們一般人會找醫生，這是因為我們對醫學對身體健康的知識有限。

01:40:53 - 01:40:57
所以當你去找醫生的時候，醫生說我要幫你做什麼檢查，請你配合。

01:40:57 - 01:40:59
你通常不會去質疑他嘛。

01:40:59 - 01:41:00
他叫你做你就做嘛。

01:41:00 - 01:41:03
所以這種情況呢，也是一種權勢關係的濫用，所以這個可以論述28。

01:41:05 - 01:41:06
至於啊，關號三，那脅迫呢？

01:41:08 - 01:41:12
如果是權勢關係之中的脅迫，可以論228嗎？

01:41:13 - 01:41:15
這個你要跟利用分開喔。

01:41:15 - 01:41:18
利用跟脅迫你不會分的話，你到這邊就會學不好。

01:41:18 - 01:41:20
我一直強調，什麼叫利用？

01:41:21 - 01:41:21
被害人

01:41:22 - 01:41:26
如果接受行為人的條件，行為人會讓他更好，那個叫利用。

01:41:28 - 01:41:29
脅迫是反過來喔。

01:41:30 - 01:41:35
脅迫是說被害人如果不接受行為人的條件，行為人會讓他過得更糟糕，那個叫做脅迫。

01:41:36 - 01:41:37
所以各位啊，

01:41:37 - 01:41:39
更棘手的案例是這樣子。

01:41:40 - 01:41:40
如果

01:41:41 - 01:41:43
有個女研究生，她準備要接受論文口試了。

01:41:45 - 01:41:46
結果啊，

01:41:48 - 01:41:48
這個

01:41:48 - 01:41:49
教授就跟他說啊,

01:41:49 - 01:41:50
你的論文寫得很棒。

01:41:51 - 01:41:51
可是呢,

01:41:52 - 01:41:54
你要畢業，還要經過我這一關。

01:41:55 - 01:41:56
那你想畢業的話,

01:41:56 - 01:41:57
晚上就來陪我睡。

01:41:58 - 01:41:59
你晚上不來陪我睡的話,

01:42:00 - 01:42:01
你論文考試不用想過。

01:42:01 - 01:42:03
你不用想拿到這個學位。

01:42:04 - 01:42:06
這樣的情況這個教授要不要論二八？

01:42:07 - 01:42:09
其實這裡的問題是這樣的。

01:42:09 - 01:42:12
這個教授會不會另外成立221？

01:42:13 - 01:42:14
懂這意思吧？

01:42:14 - 01:42:17
因為如果這個教授會另外成立221的話。

01:42:17 - 01:42:19
那228成不成立就不重要了嘛。

01:42:20 - 01:42:23
因為同時有21跟28的話，我們就論21了嘛，對不對？

01:42:23 - 01:42:25
所以其實下面這個問題。

01:42:27 - 01:42:29
228有沒有包括脅迫？

01:42:29 - 01:42:32
其實這個問題真正在談的不是28本身。

01:42:32 - 01:42:37
而是呢，這種案例會不會同時成立221。

01:42:37 - 01:42:38
所以這個算複習喔。

01:42:38 - 01:42:39
我們想一下喔。

01:42:40 - 01:42:42
221不是有脅迫而違反意願嗎？

01:42:43 - 01:42:51
那教授跟研究生說，你論文寫得很棒沒有錯，但如果你不來陪我睡，我永遠不會讓你拿到這個學位。

01:42:51 - 01:42:52
他是不是脅迫？

01:42:52 - 01:42:54
不用懷疑，對，他當然是脅迫。

01:42:54 - 01:42:56
但他算違反意願嗎？

01:42:57 - 01:42:59
還記不記得我們上次講違反意願有兩種不同認定方式。

01:43:00 - 01:43:09
有一種方式認為說，你只要讓被害人的意思形成過程受到了幹擾，受到了有點影響的狀態。

01:43:09 - 01:43:10
那個就算違反意願。

01:43:10 - 01:43:10
有沒有？

01:43:10 - 01:43:10
這一種寬鬆的說法。

01:43:11 - 01:43:13
那還有另外一種說法認為說呢，要達到完全的扭曲。

01:43:14 - 01:43:17
也就是要被害人生命身體的現實惡害，這個才算。

01:43:17 - 01:43:19
有印象吧，兩種不同的說法。

01:43:20 - 01:43:21
所以這裡的話。

01:43:23 - 01:43:25
就是那兩種不同說法的角力。

01:43:26 - 01:43:27
有人說。

01:43:27 - 01:43:32
因為我們的221並沒有對違反意願設下程度上的限制。

01:43:33 - 01:43:38
所以教授用能不能拿到學位，或者老闆用能不能繼續工作。

01:43:39 - 01:43:41
作為惡害的內容的話。

01:43:42 - 01:43:44
這個對當事人來說已經是很嚴重的事了。

01:43:45 - 01:43:48
所以這樣的情況可以算是違反意願。

01:43:48 - 01:43:49
這是一種說法。

01:43:49 - 01:43:50
好像張庭老師就持這樣說法。

01:43:51 - 01:43:53
所以照這樣的說法的話。

01:43:54 - 01:43:58
權勢關係下的脅迫直接論221就好了。

01:43:59 - 01:44:00
就不用再來論了。

01:44:00 - 01:44:00
228的，知道嗎？這是一種說法。

01:44:02 - 01:44:04
但相對的，如果照蔡聖偉老師的說法，他會認為說，脅迫而違反意願，那個違反意願要怎麼樣才算？

01:44:09 - 01:44:11
生命身體法益的現實惡害。

01:44:11 - 01:44:16
所以如果照那種說法的話，這樣的案例沒辦法論221，所以進而只能論什麼呢？

01:44:18 - 01:44:20
228，知道嗎？進而只能論228。

01:44:20 - 01:44:21
所以我這邊再講一次哈。

01:44:22 - 01:44:25
權勢關係下的脅迫，可不可以論228？

01:44:26 - 01:44:28
其實說真的，這不是二二八本身的問題。

01:44:29 - 01:44:34
這個問題是二二一的脅迫而違反意願，怎麼認定？

01:44:34 - 01:44:35
瞭解吧，其實就是這個問題。

01:44:36 - 01:44:40
所以如果你認為說二二一的脅迫而違反意願，那個違反意願是寬鬆的，那這種案例論二二一就好了，就不用論二二八啦。

01:44:43 - 01:44:47
反之你蔡聖偉老師或許澤老師那種嚴格的見解，沒辦法論二二一的話，我們才有必要，在這邊再去論二二八，是這樣子。

01:44:53 - 01:44:56
好，那傳統的食物見解有講一個東西，342頁的黑色圈圈一這邊。

01:45:01 - 01:45:04
這個標準可能同學或多或少都聽過。

01:45:04 - 01:45:05
傳統食物說啊。

01:45:06 - 01:45:10
如果相對人的意願已經被違反了，這時候要論221。

01:45:13 - 01:45:17
那如果相對人只是處於一個隱忍屈從的狀態，那我判斷的是228。

01:45:19 - 01:45:22
以前在學校學過刑分的話，應該聽過這個關鍵，聽過這個說法，對不對？

01:45:23 - 01:45:25
如果已經違反意願的話，這是221。

01:45:25 - 01:45:27
如果是隱忍屈從的話，那就是228。

01:45:29 - 01:45:33
其實這個方向跟我們通說的看法是類似的。

01:45:33 - 01:45:35
也就是如果說，這個惡害，它已經達到一定的強度。

01:45:41 - 01:45:43
被害人很難自由決定了，那就論221嘛。

01:45:44 - 01:45:48
相對來說，如果還沒有達到這個程度，被害人他還可以選擇，只是有點心不甘情不願，算了算了沒關係啦，好了。

01:45:52 - 01:45:53
這個時候呢，228，知道嗎？

01:45:53 - 01:45:55
食物大概是這樣操作的。

01:45:55 - 01:45:59
這個說法呢，也跟我們通說的看法是有點類似，所以我才會說。

01:46:00 - 01:46:00
癥結在這邊

01:46:01 - 01:46:04
性行為到底要不要論228

01:46:04 - 01:46:06
其實這個就不是228本身的問題了

01:46:07 - 01:46:10
這個會說228的違反意願,你要怎麼去認定

01:46:11 - 01:46:14
你把228的違反意願認定的越寬鬆的話

01:46:14 - 01:46:17
那228在這種案例成立的空間就越小，反之就是這樣子

01:46:19 - 01:46:19
好

01:46:21 - 01:46:23
那麼接著，剛剛我講的那個題目

01:46:24 - 01:46:26
333到334

01:46:27 - 01:46:30
343啊，343到344

01:46:30 - 01:46:31
這個題目

01:46:31 - 01:46:39
醫師欺騙來做體檢的女病患，去配合做成一個原本根本就不需要的

01:46:40 - 01:46:42
這個體檢

01:46:43 - 01:46:45
也不能算體檢啊，因為那根本不是檢查

01:46:46 - 01:46:53
醫師假借體檢之名啊，要女病患去配合，許者這件事呢，是滿足醫師自己的性慾

01:46:54 - 01:46:56
這個案例一定可以論228

01:46:56 - 01:46:56
OK,這個沒有疑問

01:46:57 - 01:46:58
欺騙,對不對,一定可以論228

01:47:00 - 01:47:02
這一種案例,來同學動腦喔

01:47:02 - 01:47:03
這一種案例可不可以論221

01:47:05 - 01:47:07
我們早上開始上課講的啊

01:47:07 - 01:47:09
這一種案例可不可以論221

01:47:09 - 01:47:09
來各位

01:47:10 - 01:47:13
這一種案例當中

01:47:13 - 01:47:14
它是哪一種欺騙

01:47:14 - 01:47:16
法益相關或法益無關

01:47:18 - 01:47:19
對啊，相關還無關

01:47:20 - 01:47:22
這個我前幾年在警訊班考過，一堆同學都寫錯

01:47:23 - 01:47:25
一堆同學跟我說這個叫法益相關

01:47:25 - 01:47:29
因為同學總覺得這個醫師好壞，要讓他成立強制性交

01:47:29 - 01:47:30
不是啦，這個不是

01:47:30 - 01:47:30
叫法益相關啦

01:47:31 - 01:47:33
我們說法益相關跟法益無關怎麼判斷

01:47:34 - 01:47:34
我們看什麼

01:47:35 - 01:47:37
被害人所同意做的那些事

01:47:38 - 01:47:41
跟行為人所真正做的那件事，兩者一樣還不一樣？

01:47:42 - 01:47:43
關鍵在這邊嘛，對不對？

01:47:44 - 01:47:46
所以在這個案例當中

01:47:46 - 01:47:46
被害人同意什麼呢？

01:47:47 - 01:47:49
醫師用手指伸進他的陰道

01:47:50 - 01:47:51
醫師做的是不同一件事

01:47:52 - 01:47:53
對，要是同一件事啊

01:47:53 - 01:47:54
只是欺騙的是什麼

01:47:55 - 01:47:56
做這件事的目的嘛

01:47:57 - 01:47:57
對不對

01:47:58 - 01:47:59
被害人醫師是

01:48:00 - 01:48:02
宣稱做這件事情，是做婦科的檢查。

01:48:03 - 01:48:06
可是實際上做這件事情的目的，他只是純粹滿足醫師自己的性慾，所以這個叫什麼？欺騙？

01:48:10 - 01:48:12
法律無關的欺騙，瞭解嗎？

01:48:12 - 01:48:14
這就是一種法律無關的欺騙喔。

01:48:16 - 01:48:18
這就跟一般講的那種騙砲不是很像嗎？

01:48:19 - 01:48:22
男生聲稱打了砲之後，我就會當你的女朋友。

01:48:22 - 01:48:25
但後來男生打了砲之後，就把那個女生給甩了。

01:48:25 - 01:48:26
不是類似的情況嗎，對不對？

01:48:26 - 01:48:29
他只是一個純粹性行為目的的欺騙喔。

01:48:30 - 01:48:30
好。

01:48:31 - 01:48:33
所以這一題我們看到這。

01:48:33 - 01:48:37
接下來344頁的最下面，詐術性交罪。

01:48:39 - 01:48:39
好。

01:48:39 - 01:48:43
下面這邊我們講到那個詐術性交，229條。

01:48:44 - 01:48:45
這一條罪啊,

01:48:45 - 01:48:46
我們講喔,

01:48:47 - 01:48:51
必須行為人要積極的施用詐術才算喔。

01:48:51 - 01:48:55
如果行為人只是利用被害人既有的錯誤，不算喔。

01:48:56 - 01:48:58
嚴格喔，要積極的施詐喔。

01:48:58 - 01:49:01
利用被害人既有的錯誤。

01:49:02 - 01:49:02
不算喔。

01:49:03 - 01:49:05
以前發生過這麼一則很荒唐的案例。

01:49:06 - 01:49:06
就是

01:49:07 - 01:49:09
有個小偷半夜去民宅行竊。

01:49:10 - 01:49:11
偷到主臥室的時候啊,

01:49:11 - 01:49:13
女屋主醒了。

01:49:14 - 01:49:16
那女屋主當時睡眼惺忪,

01:49:17 - 01:49:19
就意識沒有很清楚,

01:49:19 - 01:49:22
再加上那個女屋主有很高度的近視，1000多度。

01:49:22 - 01:49:26
女屋主在睡眼惺忪又沒有戴眼鏡的情況之下,

01:49:26 - 01:49:29
她誤以為那個小偷是她老公,

01:49:29 - 01:49:30
她以為老公

01:49:30 - 01:49:30
回來了。

01:49:31 - 01:49:33
於是那個女屋主呢,就以為小偷是老公嘛,

01:49:33 - 01:49:36
就把小偷的褲子脫了，去幫小偷口交。

01:49:36 - 01:49:39
小偷覺得好爽喔，怎麼偷東西還有這種豔遇？

01:49:39 - 01:49:41
小偷就想說不做白不做嘛，

01:49:41 - 01:49:43
就任由那個女屋主對他口交。

01:49:44 - 01:49:46
結果女屋主口交到一半，

01:49:46 - 01:49:48
發現不對勁，帶上樓已經嚇死了，根本不是老公是小偷。

01:49:50 - 01:49:51
你說女屋主怎麼發現的？

01:49:52 - 01:49:53
是說size不對還是氣味不對嗎？

01:49:53 - 01:49:54
不知道了。

01:49:54 - 01:49:56
反正就後來女屋主才發現根本搞錯人了。

01:49:57 - 01:49:58
所以這個小偷論什麼罪？

01:49:59 - 01:50:00
性

01:50:00 - 01:50:00
小偷可判論229。

01:50:00 - 01:50:00
那個詐術性交。

01:50:04 - 01:50:04
不可以，為什麼？

01:50:05 - 01:50:06
因為，我說的。

01:50:07 - 01:50:08
他要積極使詐才算。

01:50:09 - 01:50:11
小偷沒有積極使詐啊。

01:50:11 - 01:50:16
我們講積極使詐是說，比如說小偷穿著他老公的衣服，噴他老公的香水這種，這個才算。

01:50:17 - 01:50:18
這一題當中沒有啊。

01:50:18 - 01:50:20
這一題當中

01:50:21 - 01:50:24
這個小偷，他充其量只是利用被害人既有的錯誤嘛。

01:50:25 - 01:50:27
所以沒辦法去論

01:50:27 - 01:50:29
229，沒辦法哈。

01:50:30 - 01:50:32
但這個小偷不會是無罪。

01:50:32 - 01:50:33
小偷論什麼罪?

01:50:34 - 01:50:35
225，趁機。

01:50:36 - 01:50:37
這一題論趁機，為什麼?

01:50:38 - 01:50:42
因為被害人當時睡眼惺忪，精神沒有很清楚。

01:50:43 - 01:50:47
然後又高度近視，沒有帶眼鏡，看不清楚那個人是誰。

01:50:47 - 01:50:51
那是不是25條所說的精神障礙、心智缺陷或身體的障礙？

01:50:51 - 01:50:52
沒有錯，對不對？沒有錯哈。

01:50:53 - 01:50:56
所以那個小偷呢，論的是225條喔。

01:50:56 - 01:50:58
好，這個25條本像我們會看到哈。

01:50:59 - 01:51:00
好，那一樣我們先休息。

01:51:00 - 01:51:02
一下，等一下的話呢，我們再來看225的犯罪。

01:51:11 - 01:51:11
好

01:51:11 - 01:51:15
我們接著來看到345頁這邊第四點，性自主權的擬制形態。

01:51:15 - 01:51:19
這邊我們來看到225條趁機性交猥褻罪。

01:51:19 - 01:51:21
這一條罪啊是這樣子。

01:51:21 - 01:51:24
它並不是泛指所有偷襲被害的行為，不是喔。

01:51:25 - 01:51:27
這一條罪，它除了要被害人無從表意之外，條文還講，被害人要處於這樣的狀態。

01:51:29 - 01:51:34
精神障礙、身體障礙、心智缺陷或其他相類似的情形。

01:51:35 - 01:51:36
所以像比如說，第一個精神障礙。

01:51:38 - 01:51:43
比如說有男生跟一個有嚴重思覺失調症的女生

01:51:44 - 01:51:45
發生性關係。

01:51:45 - 01:51:48
這個女生當時很明顯心智狀態是有問題的。

01:51:48 - 01:51:50
經常做出一些異於常人的舉動。

01:51:50 - 01:51:53
而男生利用這個狀態呢，跟這個女生發生性關係。

01:51:53 - 01:51:54
這個叫做精神障礙。

01:51:55 - 01:51:57
還有像身體的障礙。

01:51:57 - 01:52:00
比如說趁別人昏迷，或者是跟植物人

01:52:00 - 01:52:03
發生性關係，這時候的話呢，叫做身體障礙。

01:52:04 - 01:52:06
第三個叫做心智缺陷，比如說跟智能有障礙的人發生性關係，那心智缺陷的話是這樣子。

01:52:11 - 01:52:16
並不是說跟所有智能障礙的人發生性關係都會論225哦，當然不是哦。

01:52:18 - 01:52:19
因為智能障礙要分。

01:52:20 - 01:52:27
如果是一個輕度的智能障礙，也就是這個人他具有基本的性行為意識，他是有辨別事理的能力的。

01:52:28 - 01:52:32
跟這樣的智能障礙者發生性關係，當然不會成立犯罪。

01:52:32 - 01:52:32
因為如果你說

01:52:32 - 01:52:34
跟所有的智能障礙者

01:52:34 - 01:52:35
發生性關係的話，

01:52:35 - 01:52:35
那不是就，

01:52:35 - 01:52:36
如果跟所有的智障

01:52:36 - 01:52:38
發生性關係都會成225的話，

01:52:38 - 01:52:40
那不是反面而言的意思就是

01:52:40 - 01:52:42
智能障礙者沒有性的自由，

01:52:42 - 01:52:43
不可能嘛，對不對？

01:52:44 - 01:52:46
智能障礙者他有性行為的權利，所以喔。

01:52:48 - 01:52:55
這裡的心智缺陷指的是說跟那種沒有辨別事理能力的智能障礙者發生性關係，這裡才會論這一條罪。

01:52:57 - 01:53:03
好，然後再來呢，其他類似的情形，比如說熟睡或者是酒醉那一種。

01:53:03 - 01:53:09
總之啊，被害人要處於這樣的狀態，行為人跟他發生性關係呢，才會論225條的犯罪。

01:53:10 - 01:53:15
那第二點這邊我們看，本罪跟強制性交猥褻的關係。

01:53:17 - 01:53:20
當然傳統上會把它們理解成是互斥的關係。

01:53:20 - 01:53:22
所以傳統見解會覺得，如果要成立趁機性交未遂的話。

01:53:22 - 01:53:27
我們來看到346，要符合這兩個要件。

01:53:30 - 01:53:33
第一個呢，被害人不能抗拒的原因。

01:53:33 - 01:53:36
非行為人基於性行為意思所造成的。

01:53:36 - 01:53:40
而且被害人呢，自始至終都沒有表達反對的意思。

01:53:40 - 01:53:44
傳統上認為呢，要符合這兩個才可以成立。

01:53:46 - 01:53:46
25。

01:53:46 - 01:53:49
否則的話呢，就是221的犯罪。

01:53:49 - 01:53:53
所以我這邊舉一個例子喔，再幫同學複習一下這些關係喔。

01:53:54 - 01:53:56
我以前大學的時候啊。

01:53:56 - 01:53:59
我記得大事，大事剛開學的時候，當時

01:54:00 - 01:54:00
我看到我的同學，不算同學，算一個學長，跟他還不錯。

01:54:00 - 01:54:00
我看到一個學長呢，在一堂選修課的時候坐在我的前面。

01:54:08 - 01:54:09
我坐中間，他坐我前面兩三排。

01:54:11 - 01:54:15
那我發現那個學長，他的脖子上啊，被種滿了草莓。

01:54:15 - 01:54:19
然後啊，我下課就問那個學長說，你那個脖子是怎麼回事啊？

01:54:19 - 01:54:21
你是不是又去夜店風流了？

01:54:21 - 01:54:22
我就跟學長這樣說。

01:54:22 - 01:54:24
學長說沒有，他沒去夜店。

01:54:24 - 01:54:26
我就問他說，不然呢，那個脖子是怎樣？

01:54:26 - 01:54:30
我就開玩笑的問那個學長說，啊你是被男生種的，還是被女生種的？

01:54:30 - 01:54:32
學長說他是被男生種的，我聽到嚇一跳。

01:54:32 - 01:54:36
我想說奇怪，印象中學長是異性戀，怎麼被男生種草莓呢？

01:54:37 - 01:54:39
學長跟我說，回去我再跟你說。

01:54:39 - 01:54:42
就回去上線，再跟他說，再跟我說。

01:54:42 - 01:54:46
後來回去，我大學的時候那時候還在用MSN哦，聽起來好古老。

01:54:47 - 01:54:51
後來回去，家裡之後我看到他上線嘛，我就問那個學長說到底發生什麼事？

01:54:51 - 01:54:55
學長跟我說呢，前幾天他去學弟家喝酒。

01:54:55 - 01:54:59
當時除了A學弟之外，好像還有B跟C吧，反正當時幾個人，在裡面喝酒。

01:55:00 - 01:55:03
這幾個學弟就一直灌學長酒。

01:55:03 - 01:55:07
等學長被灌醉，有點意識模糊，無法動彈的時候。

01:55:08 - 01:55:10
學弟們呢，就開始。

01:55:11 - 01:55:12
其中這個主謀啊。

01:55:12 - 01:55:14
就開始對學長舌吻。

01:55:15 - 01:55:16
舔遍他的全身。

01:55:17 - 01:55:18
脫他的褲子幫他吹喇叭。

01:55:18 - 01:55:20
還在他的脖子上種草莓，學弟就這樣做。

01:55:21 - 01:55:23
我就問學長說，怎麼沒有反抗？

01:55:23 - 01:55:27
學長說因為當時醉到沒有什麼力氣，意識是很模糊的。

01:55:27 - 01:55:29
所以只能任由他們擺布。

01:55:30 - 01:55:32
那接著我就問學長說，那你有沒有被肛？

01:55:32 - 01:55:34
學長說沒有，說菊花有守住，沒有被肛。

01:55:35 - 01:55:35
學長是跟我這樣說的。

01:55:36 - 01:55:37
但我聽起來覺得很矛盾。

01:55:37 - 01:55:39
那時候他要怎麼守住他的菊花？

01:55:39 - 01:55:39
我覺得怪怪的哈。

01:55:40 - 01:55:44
那我就跟學長說，那你去提告啊，我們學校旁邊就是和平醫院啊。

01:55:44 - 01:55:48
你趕快去驗傷啊，就趁著疤痕還在，趁著可能還有唾液，趕快去提告啊。

01:55:50 - 01:55:51
學長說要告什麼？

01:55:51 - 01:55:52
要告性侵嗎？

01:55:53 - 01:55:55
我說不是啦，這個不是趁機啦。

01:55:55 - 01:55:55
這個叫強迫。

01:55:56 - 01:55:57
為什麼？

01:55:57 - 01:56:00
你想啊，當時學弟一直去灌你

01:56:00 - 01:56:00
學長酒。

01:56:00 - 01:56:01
目的是為了什麼？

01:56:02 - 01:56:04
難道是要學長體會那個威士忌的鄉村美好嗎？

01:56:05 - 01:56:05
一定不是嘛，

01:56:06 - 01:56:07
當時學弟灌學長酒，

01:56:07 - 01:56:08
一定是要把學長弄醉。

01:56:08 - 01:56:09
然後跟他發生性關係嘛。

01:56:09 - 01:56:10
所以這個照通說的說法，

01:56:10 - 01:56:11
這個怎麼會是趁機？

01:56:12 - 01:56:13
這個就是強制的啊，

01:56:13 - 01:56:14
對不對，我就跟學長說你要告你就去告強制。

01:56:15 - 01:56:16
而且當時是兩個人以上在場,

01:56:16 - 01:56:17
這個會變加重刑責,

01:56:17 - 01:56:18
七年以上,

01:56:18 - 01:56:19
我跟學長這樣說。

01:56:19 - 01:56:20
學長後來是沒有去告啦,

01:56:20 - 01:56:21
想說算了都認識的人

01:56:21 - 01:56:21
沒有去告。

01:56:21 - 01:56:22
但他後來有點後悔

01:56:22 - 01:56:23
因為學弟一直煩他

01:56:23 - 01:56:24
反正之前有過這樣的事。

01:56:25 - 01:56:26
然後那個時候,

01:56:26 - 01:56:28
我當然就很好奇說學長真的沒有被__嗎?

01:56:29 - 01:56:30
就我覺得應該有,

01:56:30 - 01:56:31
我覺得應該有。

01:56:31 - 01:56:32
因為幾個月後,

01:56:32 - 01:56:34
我跟這個學長還有他的朋友一起去吃麥當勞。

01:56:34 - 01:56:35
然後，

01:56:35 - 01:56:37
那個時候我記得，

01:56:37 - 01:56:39
學長就跟他朋友講到這個，這幾個人。

01:56:40 - 01:56:41
啊他的朋友就一下問說，啊你說誰啊？

01:56:42 - 01:56:43
學長就不經意脫口而出一句話,

01:56:43 - 01:56:57
說前幾個月

01:56:57 - 01:57:15
肛我的那個人。

01:57:15 - 01:57:17
我說奇怪，你不是沒被肛嗎？

01:57:17 - 01:57:18
當然我沒有說啦，我心中這樣想。

01:57:18 - 01:57:18
我後來才知道，

01:57:19 - 01:57:20
學長的屁眼應該是失守了,

01:57:20 - 01:57:21
我覺得應該，他應該有被肛。

01:57:22 - 01:57:23
反正啦，藉由這個案例提醒同學，

01:57:24 - 01:57:25
這個案例當中的學弟們，

01:57:25 - 01:57:26
他們是強制喔。

01:57:27 - 01:57:28
他們不是一般的檢屍喔,

01:57:28 - 01:57:29
因為被害人處於那個狀態,

01:57:29 - 01:57:31
就是行為人基於性侵的意思所造成的喔,

01:57:31 - 01:57:31
知道吧?

01:57:31 - 01:57:32
所以我就說了,

01:57:32 - 01:57:33
346頁這邊講的，

01:57:33 - 01:57:34
照傳統的見解，

01:57:34 - 01:57:35
要論225的話呢，

01:57:36 - 01:57:37
必須符合兩個要件，

01:57:37 - 01:57:37
第一個，

01:57:37 - 01:57:39
被害人不知不能抗拒,

01:57:39 - 01:57:41
非因行為人基於性行為意思所造成的,

01:57:41 - 01:57:43
而且啊,被害人要自始至終沒有反對,

01:57:43 - 01:57:45
就是對照到右邊的這個表格。

01:57:46 - 01:57:48
好,所以如果這兩個要件有任何一個欠缺的話呢,

01:57:48 - 01:57:49
論的都是強制。

01:57:49 - 01:57:51
當然啦，新進的話是蔡聖偉老師的看法。

01:57:51 - 01:57:54
蔡老師一向是反對把構成要件解釋成互斥嘛。

01:57:54 - 01:57:55
因為蔡老師就說了，

01:57:55 - 01:57:56
這兩條罪，

01:57:56 - 01:57:57
原本是可以包含的。

01:57:57 - 01:57:58
讓它包含沒有壞處啊，

01:57:58 - 01:58:00
就競合再解決就好了。

01:58:00 - 01:58:02
我們為什麼一開始把它理解成互斥呢？

01:58:02 - 01:58:06
所以如果依照蔡老師的看法，剛剛我講這個學長的案例。

01:58:07 - 01:58:10
行為人照理說可以同時成立221跟225。

01:58:12 - 01:58:15
然後結合上我們在優先論21或22，那不是也可以嗎？

01:58:15 - 01:58:16
對不對，所以

01:58:17 - 01:58:19
都有不同的說法。

01:58:19 - 01:58:21
好，所以26我們簡單看到這。

01:58:21 - 01:58:26
接下來我們往下看，來看227，與幼年人性交猥褻罪，終於要講性犯罪最後一個條文了。

01:58:30 - 01:58:33
這個性犯罪，這幾年的東西真的越來越多。

01:58:33 - 01:58:37
而且再加上性犯罪，要說是我的專長領域嗎？

01:58:37 - 01:58:39
應該算，因為我碩論就寫性犯罪啊。

01:58:40 - 01:58:42
博論還在考慮。

01:58:42 - 01:58:48
因為我當初用，當初申請博班的時候，我的研究計畫是寫那個被害人承諾那方面的問題。

01:58:48 - 01:58:50
但那方面的問題是不是還是可以跟性犯罪連結？

01:58:51 - 01:58:51
沒錯對不對？

01:58:51 - 01:58:55
所以我還在猶豫說，不知道了，反正才剛入學吧，還有時間嘛。

01:58:56 - 01:58:57
以後會不會繼續往性犯罪寫，也說不定，有可能。

01:58:59 - 01:59:00
因為專長領域啦。

01:59:00 - 01:59:02
所以有些東西就忍不住多講一些，真的是這樣。

01:59:04 - 01:59:06
來，我們來看一下347頁這邊第五點。

01:59:07 - 01:59:10
227，與幼年人性交猥褻罪。

01:59:10 - 01:59:12
這一條就是我碩士的時候寫的。

01:59:12 - 01:59:13
那時候寫這一條。

01:59:13 - 01:59:15
227的話是這樣子。

01:59:15 - 01:59:17
這一條罪的行為，我們跟各位強調喔。

01:59:19 - 01:59:25
227這一條我們在解釋上，不要求被害人要合意性交。

01:59:26 - 01:59:27
解釋上沒有這個要求，知道嗎？

01:59:28 - 01:59:31
227，不需要被害人有合意。

01:59:32 - 01:59:33
再講一次，不需要，不需要好嗎？

01:59:33 - 01:59:36
不需要，227不用被害人有合意。

01:59:36 - 01:59:37
我們只能說啊。

01:59:37 - 01:59:39
在現象上來說，通常犯227的行為人。

01:59:41 - 01:59:43
往往跟被害人是合意性交，因為在司法實務上面。

01:59:43 - 01:59:47
那種被起訴被判227的，十個裡面大概有九個就是跟國中生合意性交那一種。

01:59:51 - 01:59:52
幾乎都是。

01:59:52 - 01:59:55
所以227在實務上呢，通常都是合意性交的情況。

01:59:58 - 02:00:00
可是我跟你們說，解釋

02:00:00 - 02:00:02
上不可以加上這個要件，絕對不可以。

02:00:02 - 02:00:06
因為你起訴上加這個要件的話，反而造成法律適用的困難。

02:00:07 - 02:00:09
那你說性侵嬰幼兒怎麼辦？

02:00:11 - 02:00:13
我以前寫碩論的時候就想到一個問題，

02:00:13 - 02:00:15
後來在國外真的有發生過。

02:00:16 - 02:00:17
就真的無奇不有啦,

02:00:18 - 02:00:22
就是有男生在陰莖上面抹了什麼果醬或蜂蜜之類的東西,

02:00:23 - 02:00:25
引誘那個幼兒去吸他的陰莖。

02:00:25 - 02:00:26
對，就是發生這樣的案例。

02:00:27 - 02:00:28
我記得是國外的新聞,

02:00:28 - 02:00:31
就以前我寫碩論的時候想說，我說搞不好會有這種事，

02:00:31 - 02:00:32
結果真的有。

02:00:32 - 02:00:34
就男生在他的陰莖上面好像抹了什麼果醬吧，

02:00:34 - 02:00:36
然後引誘那個小朋友去舔。

02:00:37 - 02:00:37
對啊，這樣的案例。

02:00:38 - 02:00:40
假設你說，227要同意，

02:00:41 - 02:00:42
要合意性交。

02:00:43 - 02:00:45
那後面一定會說，就被害人沒有真正的意願啊，

02:00:46 - 02:00:47
被害人沒有意願你怎麼合意？

02:00:48 - 02:00:49
那這樣你要怎麼論罪，對不對？

02:00:49 - 02:00:53
所以我們只能說，227在現象上來說，通常是合意沒有錯，

02:00:54 - 02:00:55
但那個不是它規範的要件，

02:00:56 - 02:00:56
瞭解嗎？

02:00:56 - 02:00:56
不是喔。

02:00:57 - 02:01:16
所以各位，227，

02:01:16 - 02:01:42
它沒有要求任何的意願喔。

02:01:42 - 02:01:42
知道嗎？

02:01:43 - 02:01:43
完全沒有喔。

02:01:44 - 02:01:47
不管是合意的、反對的，或是不置可否的，

02:01:47 - 02:01:49
都可以論述。

02:01:49 - 02:01:53
好，接下來括號二，我們來看到它的行為，性交跟猥褻。

02:02:00 - 02:02:05
19歲的甲男跟15歲的乙女是男女朋友，遭乙女家長的反對。

02:02:05 - 02:02:12
甲男跟乙女為了要向大家證明兩個人堅定的愛情，所以在星期六下午三點，在人來人往的百貨公司前面接吻。

02:02:12 - 02:02:13
問說啊。

02:02:14 - 02:02:15
這問題二哈。

02:02:16 - 02:02:20
甲男有沒有觸犯227第四項的與幼年人猥褻罪。

02:02:21 - 02:02:23
來，你看他結論說什麼。

02:02:24 - 02:02:26
他結論很有趣，你還看到這個中間下面這邊。

02:02:27 - 02:02:31
他說甲男乙女是在人來人往的百貨公司前面接吻。

02:02:31 - 02:02:34
這跟私密環境下的接吻有容易引起性慾是不同的。

02:02:34 - 02:02:38
在這種場合接吻，很難認為是基於色慾的動作。

02:02:38 - 02:02:40
所以呢,不能認為是猥褻。

02:02:40 - 02:02:41
結論上說不算。

02:02:42 - 02:02:44
但你知道這個,這個邏輯是什麼意思嗎?

02:02:45 - 02:02:49
他說在這種環境之下接吻,不容易引起性慾,所以不是猥褻。

02:02:49 - 02:02:57
所以反過來的意思就是,那這一對男女如果是在幽暗的MTV包廂接吻的話,超容易引起性慾,所以就變成是猥褻。

02:02:57 - 02:02:59
反過來講不就這個意思嗎，對不對？

02:03:00 - 02:03:01
所以呢。

02:03:02 - 02:03:05
跟未滿16歲的人接吻，算不算是猥褻？

02:03:05 - 02:03:06
算不算？

02:03:07 - 02:03:09
我們用說法是這樣，回到我們剛剛的定義。

02:03:09 - 02:03:09
什麼叫猥褻？

02:03:10 - 02:03:12
客觀上跟性有關的行為，這個就猥褻，對不對？

02:03:13 - 02:03:16
所以同樣是親吻，你要看不同的情境。

02:03:17 - 02:03:18
真的你要看不同的情境。

02:03:18 - 02:03:19
比如說。

02:03:19 - 02:03:22
如果你過年的時候看到你親戚的小孩很可愛。

02:03:23 - 02:03:27
然後你就把這個幼稚園的小朋友抱起來,說叔叔阿姨親一個好不好啊。

02:03:27 - 02:03:29
小朋友說好,你就親他的臉頰。

02:03:29 - 02:03:30
所以你

02:03:30 - 02:03:31
你猥褻幼童。

02:03:31 - 02:03:31
是這樣嗎？

02:03:32 - 02:03:34
如果是這種基於親情的。

02:03:35 - 02:03:36
稍微親人家點，夾一下，你會說這個叫猥褻。

02:03:38 - 02:03:38
還好吧，對不對？

02:03:38 - 02:03:40
所以這一種的不算。

02:03:40 - 02:03:44
親臉頰，有些時候或許可以認為是親情或友情的表示，這種或許不會算猥褻。

02:03:46 - 02:03:47
可是你要想喔。

02:03:47 - 02:03:49
嘴對嘴，甚至是舌吻。

02:03:50 - 02:03:50
那個是不是猥褻？

02:03:51 - 02:03:52
廢話當然是啊。

02:03:53 - 02:03:54
你親戚的小孩再怎麼可愛。

02:03:55 - 02:03:57
你不會把他抱起來舌吻吧。

02:03:57 - 02:03:59
你把你親戚的小孩抱起來舌吻，你跟他爸媽會理你。

02:04:00 - 02:04:00
告你，

02:04:01 - 02:04:01
一定會。

02:04:01 - 02:04:02
對不對？

02:04:02 - 02:04:03
所以舌吻是不是猥褻？

02:04:03 - 02:04:03
是啊，

02:04:03 - 02:04:04
不用懷疑好嗎？

02:04:05 - 02:04:06
舌吻當然是猥褻。

02:04:06 - 02:04:08
所以跟未滿16歲的人舌吻,

02:04:08 - 02:04:09
會不會成立227?

02:04:10 - 02:04:10
會,

02:04:10 - 02:04:10
好嗎?

02:04:10 - 02:04:11
當然會喔。

02:04:11 - 02:04:13
當然有些同學會覺得蛤,

02:04:14 - 02:04:15
跟國中生舌吻是會怎樣？

02:04:16 - 02:04:18
他的身心狀況就會因此而受傷了嗎？

02:04:18 - 02:04:19
好像不會吧。

02:04:20 - 02:04:21
如果你有提出這個質疑的話,

02:04:21 - 02:04:22
那我跟你說，

02:04:22 - 02:04:24
那問題不在猥褻的定義，

02:04:24 - 02:04:26
問題在227的年齡門檻，

02:04:26 - 02:04:27
那個16歲可能太高了。

02:04:28 - 02:04:29
問題在這邊。

02:04:30 - 02:04:32
我們以前寫碩論最後的結論也是

02:04:32 - 02:04:33
我覺得16歲門檻太高

02:04:33 - 02:04:34
可以往下修

02:04:34 - 02:04:35
13、14之類的

02:04:36 - 02:04:37
不只我這樣說啦

02:04:37 - 02:04:38
許玉秀老師的文章，

02:04:39 - 02:04:40
許澤天老師的文章，

02:04:40 - 02:04:41
還有陳子平老師的文章，

02:04:41 - 02:04:43
都有提到類似的事。

02:04:43 - 02:04:46
因為16歲這個門檻從1935年訂到現在，

02:04:46 - 02:04:47
完全沒有變過。

02:04:49 - 02:04:49
除非啦，

02:04:50 - 02:04:51
一開始的門檻訂得不對，

02:04:52 - 02:04:52
否則你想喔，

02:04:53 - 02:04:55
1935年當時就是16。

02:04:55 - 02:04:57
現在2025年經過90年了,

02:04:58 - 02:04:58
這90年間,

02:04:59 - 02:05:00
青少年的身心發展,

02:05:01 - 02:05:02
應該是比以前更早熟。

02:05:03 - 02:05:04
以前青春期來得晚嘛,

02:05:04 - 02:05:05
現在比較早嘛,

02:05:05 - 02:05:07
現在大概小五小六就青春期了嘛,

02:05:08 - 02:05:08
那現在的青少年呢,

02:05:09 - 02:05:10
心理發展上可能也比以前更早熟,

02:05:10 - 02:05:11
資訊越來越多了,

02:05:12 - 02:05:13
所以現在來說的話,

02:05:13 - 02:05:14
這一條這個年齡門檻,

02:05:14 - 02:05:15
我是覺得啦,

02:05:15 - 02:05:16
應該往下修才對,

02:05:16 - 02:05:17
所以你覺得說蛤,

02:05:18 - 02:05:19
跟國中生舌吻一下不會怎麼樣,

02:05:19 - 02:05:20
怎麼樣論這條罪呢？

02:05:21 - 02:05:22
問題就不是猥褻的定義,

02:05:22 - 02:05:24
問題是可能這條罪的年齡門檻太高,

02:05:24 - 02:05:25
可能是這樣子。

02:05:26 - 02:05:26
所以各位啊,

02:05:28 - 02:05:28
這個,

02:05:28 - 02:05:29
如果以前你

02:05:30 - 02:05:32
國高中的時候有交過男女朋友,

02:05:33 - 02:05:35
而你的男女朋友在當時沒有滿16歲,

02:05:35 - 02:05:37
而你又有跟他舌吻的話,

02:05:38 - 02:05:39
就是二二七喔。

02:05:40 - 02:05:41
而且我看你們都還年輕,

02:05:41 - 02:05:43
追訴權時效還沒過喔。

02:05:44 - 02:05:44
對啊,

02:05:44 - 02:05:48
所以如果你們以前國高中的時候有交過未滿16的男女朋友,

02:05:48 - 02:05:49
你們有舌吻,

02:05:50 - 02:05:51
而且甚至還有留下證據的話,

02:05:52 - 02:05:53
不要得罪對方喔,

02:05:53 - 02:05:55
不然對方要告你猥褻是告得成的喔

02:05:55 - 02:05:56
小心喔。

02:05:56 - 02:05:57
好。

02:05:57 - 02:05:57
所以這個是第一個。

02:05:58 - 02:05:59
本，這個第二個喔。

02:05:59 - 02:05:59
本案的行為

02:06:01 - 02:06:02
稱之為下面這個課題。

02:06:03 - 02:06:03
實務說啊,

02:06:03 - 02:06:06
已經結婚的人不受這條罪的保護。

02:06:07 - 02:06:07
什麼叫什麼?

02:06:07 - 02:06:09
說已經結婚的人呢,

02:06:09 - 02:06:11
未滿16歲但已經結婚的話,

02:06:11 - 02:06:12
不受本罪的保護。

02:06:13 - 02:06:14
我看得覺得滿頭問號。

02:06:15 - 02:06:17
就結婚跟性行為的倫理有什麼關係啊?

02:06:18 - 02:06:21
所以這一則實務見解當初作成的背景,

02:06:21 - 02:06:22
很可能你想嘛,

02:06:22 - 02:06:23
那個時代,

02:06:23 - 02:06:25
司法院院字民國二十幾年,

02:06:25 - 02:06:27
當時那個年代民風保守,

02:06:27 - 02:06:29
婚前性行為會覺得是一個很大的罪惡,

02:06:30 - 02:06:32
也許是這個年代下的產物吧,

02:06:32 - 02:06:34
覺得婚姻跟性行為是掛在一起的,

02:06:34 - 02:06:36
但從現在來看很奇怪,

02:06:36 - 02:06:40
就如果是13、14歲就被父母安排結婚,

02:06:41 - 02:06:43
那個婚姻的效力在民法上是有問題的

02:06:44 - 02:06:45
而實務卻說呢,

02:06:45 - 02:06:45
沒關係,

02:06:45 - 02:06:47
已經結婚就有性行為能力。

02:06:47 - 02:06:48
我不懂這個到底是什麼。

02:06:49 - 02:06:49
對啊,

02:06:49 - 02:06:53
就我們覺得過早的性行為對青少年的身心是不好的,

02:06:54 - 02:06:55
那跟他有沒有結婚應該沒關係吧。

02:06:57 - 02:06:58
過早的結婚對青少年也不好啊，

02:06:58 - 02:06:59
對啊，

02:06:59 - 02:06:59
所以

02:07:40 - 02:07:41
這個主見很奇怪。

02:07:42 - 02:07:42
然後再來,

02:07:43 - 02:07:43
350頁,

02:07:44 - 02:07:48
被害人的年齡是客觀處罰條件嗎?

02:07:49 - 02:07:50
這個我們在刑中講過了。

02:07:51 - 02:07:55
227的被害人年齡可以稱得上是本罪的客觀處罰條件嗎？

02:07:56 - 02:07:57
我們再講一次，

02:07:57 - 02:07:58
是不是客觀處罰條件，

02:07:58 - 02:07:59
我們怎麼認定？

02:08:00 - 02:08:03
18歲以下的人犯前條之罪者，得減輕或免除其刑。

02:08:08 - 02:08:14
講講啊，18歲以下的人犯前條之罪呢，且輕或免除其刑，227之一。

02:08:16 - 02:08:21
這個條文啊，它是一個很莫名，真的是一個很奇怪的條文。

02:08:21 - 02:08:24
第一個，他講18歲以下。

02:08:24 - 02:08:26
來所以各位，18歲以下包括18歲。

02:08:26 - 02:08:28
有啊，對不對，以下據點本數計算。

02:08:29 - 02:08:29
所以問題來了。

02:08:30 - 02:08:33
各位，那個責任能力的門檻是多少？

02:08:34 - 02:08:35
是未滿18。

02:08:36 - 02:08:37
再來喔。

02:08:38 - 02:08:44
告訴乃論的門檻，我們229之一也說，未滿18的人犯227，虛偽告訴乃論。

02:08:45 - 02:08:48
所以責任能力的門檻是未滿18歲。

02:08:49 - 02:08:53
犯227條是告訴乃論的門檻，也是未滿18歲。

02:08:53 - 02:08:56
可是227條之一卻是說18歲以下。

02:08:57 - 02:08:59
是不是有矛盾，超怪，對不對。

02:09:00 - 02:09:03
所以有剛好18歲，比如說大一那個年紀。

02:09:04 - 02:09:09
剛好18歲的男生，跟他15歲的女朋友兩個人合意發生性關係。

02:09:11 - 02:09:11
那

02:09:12 - 02:09:13
這個18歲的男生呢。

02:09:14 - 02:09:15
他是完全責任的行為人。

02:09:16 - 02:09:18
他所犯的罪也是非告訴乃論。

02:09:19 - 02:09:21
但他卻可以用27之1給予免刑。

02:09:21 - 02:09:22
這很奇怪，沒有錯。

02:09:22 - 02:09:25
其他都未滿，就只有他是例外。

02:09:26 - 02:09:26
然後

02:09:27 - 02:09:28
這一條也有問題。

02:09:29 - 02:09:31
其實大部分的人也有意識到。

02:09:31 - 02:09:35
一個18、19歲的大學生跟國中女生合意性交，

02:09:36 - 02:09:38
那到底會對國中女生的身心造成什麼侵害？

02:09:39 - 02:09:40
幾乎沒有，對不對？

02:09:41 - 02:09:43
好，那沒有的話，請問立法者意識到這件事啊？

02:09:44 - 02:09:46
這種情況應該不會有什麼侵害。

02:09:46 - 02:09:48
那不會有什麼侵害，為什麼不除罪化？

02:09:49 - 02:09:50
對，要除罪化我們就解決了。

02:09:51 - 02:09:52
為什麼是讓他還是有罪，

02:09:53 - 02:09:54
只是可以減免。

02:09:55 - 02:09:56
就立法者，這個要怎麼說啊。

02:09:58 - 02:09:59
兩邊都想討好，也是。

02:10:00 - 02:10:00
是吧

02:10:00 - 02:10:02
就不敢做得那麼徹底

02:10:02 - 02:10:04
就還是讓他有罪，只是可以見面

02:10:05 - 02:10:09
但我覺得這樣做，不，怎麼說啊，就是要不做就做得徹底

02:10:10 - 02:10:14
當我本人認為說這個行為其實對青少年沒有損害的話，就把它除罪化就好了

02:10:15 - 02:10:16
而不是說讓他還是有罪

02:10:16 - 02:10:18
而且你知道嗎，這個條文還有一個問題啊

02:10:19 - 02:10:21
那假設有個18歲的大醫生

02:10:22 - 02:10:24
他過年看到他在唸國小的表妹

02:10:25 - 02:10:27
那這個18歲大醫生就說，就問他表妹啦

02:10:27 - 02:10:30
想不想我買那個新衣服啊？表妹說想

02:10:32 - 02:10:37
那他說好，想的話，來，表哥可以給你錢，但是呢，你要幫表哥吹喇叭

02:10:38 - 02:10:43
那他在唸國小的表妹，為了要得到零用錢，所以幫他表哥吹喇叭

02:10:44 - 02:10:47
這樣的情形，有沒有符合27G的文義？

02:10:48 - 02:10:50
18歲以下之人犯前條之罪

02:10:50 - 02:10:51
其實有，對不對？

02:10:52 - 02:10:55
但這種情況好像不是立法者原本預設想解決的情形呢。

02:10:56 - 02:10:58
可是都符合法條文義了，不能不檢啊。

02:10:58 - 02:11:00
不檢反而違反罪刑法定

02:11:00 - 02:11:00
對吧

02:11:01 - 02:11:05
所以這個條文，我就說它是一個漏洞百出的規定啊，這個規定得很怪

02:11:05 - 02:11:08
前面的範圍也很怪，然後呢

02:11:10 - 02:11:13
有些真的該無罪的，他又沒有無罪

02:11:13 - 02:11:15
所以這個條文呢,總之啦,很爛的規定

02:11:16 - 02:11:22
好,最後這個專題,性侵無意識能力的嬰幼兒應該怎麼來論罪呢

02:11:25 - 02:11:26
我先講這個事實背景

02:11:27 - 02:11:31
這個事實背景,我都叫他假仙女童案

02:11:31 - 02:11:35
因為他當時發生在高雄縣的茄萣鄉,後來叫高雄市的茄萣區了

02:11:36 - 02:11:37
當時這個案例背景很簡單

02:11:38 - 02:11:40
有一名六歲的女童

02:11:41 - 02:11:44
寒假的時候啊，一個人在圖書館的樓梯間玩耍

02:11:45 - 02:11:46
這時候有個色狼經過了

02:11:47 - 02:11:50
色狼看到這個六歲女童，一個人在樓梯間玩耍呢

02:11:51 - 02:11:58
色狼就把這個女童抱起來，抱起來之後啊，色狼就用手伸到女童的褲子當中

02:11:58 - 02:12:00
而這個色狼呢，就

02:12:00 - 02:12:00
手持插入女童的陰道得逞。

02:12:03 - 02:12:04
而很特別的是

02:12:04 - 02:12:06
這個女童從頭到尾

02:12:06 - 02:12:08
都任由這個色狼擺佈，

02:12:08 - 02:12:09
女童從頭到尾

02:12:09 - 02:12:12
沒有做出任何哭鬧反抗的動作，

02:12:12 - 02:12:13
問說這個色狼

02:12:13 - 02:12:15
成立什麼犯罪。

02:12:17 - 02:12:17
事實就這樣。

02:12:18 - 02:12:23
也就是說，因為他是一個沒有意識能力、缺乏信心的嬰幼兒，那他應該怎麼去論罪？

02:12:24 - 02:12:24
好。

02:12:25 - 02:12:27
原本這個案例很簡單，原本論什麼罪？

02:12:28 - 02:12:29
227對吧。

02:12:29 - 02:12:29
227。

02:12:30 - 02:12:35
各位，這種案例可不可以讓他升起一遍222條第一項的第二款，可不可以？

02:12:36 - 02:12:37
不可以啊，為什麼？

02:12:38 - 02:12:41
女童又沒有反抗，你怎麼說他違反意願，對吧？

02:12:41 - 02:12:44
所以這種案例原本照學說的通說，論述務

02:12:44 - 02:12:46
論的都是227第一項。

02:12:47 - 02:12:48
好，原本都是論第一項，好。

02:12:50 - 02:12:54
當初這個案件在高雄地院也是判27第一項。

02:12:55 - 02:12:57
結果判超輕，判三年兩個月。

02:12:58 - 02:13:01
這個判決出來之後啊，引起社會輿論的反彈。

02:13:02 - 02:13:05
甚至後來還引發了一個社會運動叫白玫瑰運動。

02:13:05 - 02:13:05
我不知道你們有沒有印象。

02:13:06 - 02:13:07
白玫瑰運動2010的事。

02:13:07 - 02:13:10
白玫瑰運動是很莫名其妙的社會運動。

02:13:11 - 02:13:16
因為我記得當初白玫瑰運動的訴求是要性侵犯登記公告。

02:13:16 - 02:13:18
要以美國的梅根法案為範本。

02:13:19 - 02:13:20
我覺得這個很無聊啦。

02:13:20 - 02:13:20
因為。

02:13:21 - 02:13:25
你們要知道性犯罪很少發生在陌生人之間。

02:13:26 - 02:13:28
性侵犯的登記公告真的沒有什麼意義。

02:13:28 - 02:13:30
而且你說性侵犯登記公告的話。

02:13:30 - 02:13:32
那你要他以後怎麼重新做人。

02:13:32 - 02:13:34
那個其實會有一些標籤理論上面的問題啦。

02:13:34 - 02:13:35
好了，這個我們就不說了。

02:13:36 - 02:13:39
反正當時這個判決出來之後啊，引起社會輿論的反彈。

02:13:40 - 02:13:45
很多人說，就是很多對法律似懂非懂的人啊，會說這怎麼可以論述。

02:13:45 - 02:13:47
那個女童才六歲，六歲怎麼會同意。

02:13:49 - 02:13:53
所以當初最高法院也是基於這樣的想法。

02:13:53 - 02:13:56
最後呢，做成997的決議。

02:13:56 - 02:13:58
好，997的決議是這樣說的。

02:14:51 - 02:14:51
好

02:14:51 - 02:14:52
我們來看喔。

02:14:53 - 02:14:56
在這個假訊息女童案爆發之後啊

02:14:56 - 02:14:58
在同年的七月或八月

02:14:58 - 02:14:59
最高法院做成了這個決定。

02:16:00 - 02:16:01
99年的決議

02:16:01 - 02:16:02
我們來看一下352頁這邊。

02:16:03 - 02:16:04
你看喔，決議他這樣問，

02:16:05 - 02:16:09
他說甲對於未滿14歲的

02:16:10 - 02:16:11
乙呢，為性交，

02:16:11 - 02:16:15
但沒有使用強暴脅迫恐嚇催眠術的方法為之，應該如何論罪呢？

02:16:15 - 02:16:16
好，你看結論說，

02:16:16 - 02:16:19
如果乙是七歲以上未滿14歲，

02:16:19 - 02:16:23
甲跟乙合意性交的話，甲應該論227的第一項。

02:16:23 - 02:16:28
那如果甲是對未滿10歲的乙為非合意性交，或者乙未滿七歲呢，

02:16:28 - 02:16:30
甲應該論221的第一項第二款。

02:16:30 - 02:16:31
實務這樣說，

02:16:31 - 02:16:31
好，來

02:16:32 - 02:16:34
為什麼實務會做成這個決議？

02:16:35 - 02:16:36
當然實務的結論，

02:16:37 - 02:16:39
他就是想回應社會的訴求。

02:16:39 - 02:16:41
我就說嘛，我們最高法院很鬧嘛，

02:16:41 - 02:16:43
很喜歡跟社會輿論妥協，

02:16:43 - 02:16:45
他就不敢硬起來跟社會輿論對幹。

02:16:46 - 02:16:48
為什麼最高法院的院長不會出來嗆民眾，

02:16:48 - 02:16:49
你們這些無腦的人！

02:16:50 - 02:16:51
理盲又濫情。

02:16:51 - 02:16:52
好像他們都不敢喔。

02:16:52 - 02:16:54
他們為什麼不硬起來，他們就不敢這樣做啊。

02:16:55 - 02:16:59
所以各位，這樣的案例當中，最高法院他們真正的目的，

02:16:59 - 02:17:02
就是想要讓這個被告獲得重判的機會。

02:17:03 - 02:17:04
所以他才會這樣解釋。

02:17:04 - 02:17:06
那你說他們法律面怎麼論述呢？

02:17:07 - 02:17:09
最高法院最後做成這個決議，

02:17:09 - 02:17:12
除了因為他們想跟社會輿論妥協之外，

02:17:12 - 02:17:15
其實這邊也存在著一些法律概念的誤會。

02:17:15 - 02:17:16
好，怎麼說呢？

02:17:18 - 02:17:22
食物啊，對227一直存在一個根深蒂固的誤會。

02:17:22 - 02:17:26
食物總覺得227這個條文要合意性交。

02:17:27 - 02:17:31
因為他們遇到的案例，227都是那種跟國中女生約砲的嘛。

02:17:31 - 02:17:31
對。

02:17:32 - 02:17:36
所以食物一直有一個根深蒂固的錯誤觀念，覺得性行為要合意才算。

02:17:36 - 02:17:37
好，那你想哦，

02:17:38 - 02:17:39
性行為要合意的話，

02:17:40 - 02:17:42
假性侵女童案那個女童他哪有合意？

02:17:43 - 02:17:44
他是任人擺布。

02:17:44 - 02:17:46
因為他沒有表達任何的意思,對不對?

02:17:46 - 02:17:47
沒有合意,

02:17:47 - 02:17:47
好。

02:17:48 - 02:17:48
所以各位,

02:17:49 - 02:17:50
227哦,

02:17:51 - 02:17:53
要食物說要合意嘛。

02:17:53 - 02:17:55
那假性女童案就沒有合意啊。

02:17:56 - 02:17:57
那沒有合意怎麼辦？

02:17:57 - 02:17:58
不能論227。

02:17:58 - 02:18:00
那不能論227。

02:18:00 - 02:18:02
又你要去考慮到221

02:18:02 - 02:18:03
可是221要違反醫院

02:18:04 - 02:18:05
那這一切有違反醫院嗎

02:18:06 - 02:18:07
好像也沒有

02:18:07 - 02:18:08
那怎麼辦

02:18:08 - 02:18:08
就硬拗

02:18:09 - 02:18:10
對食物就硬拗

02:18:10 - 02:18:13
就硬著說，被害人未滿七歲，因為他無行為能力

02:18:14 - 02:18:17
所以你跟一個無行為能力的人發生性關係呢，也要認為有違反他的意願

02:18:18 - 02:18:19
就只好這樣硬拗

02:18:19 - 02:18:21
這很明顯是違反罪刑法定

02:18:22 - 02:18:24
所以我常說，九九七這個決議

02:18:25 - 02:18:27
就是最高法院他們一步錯，步步錯

02:18:28 - 02:18:29
第一步就錯在

02:18:30 - 02:18:32
二二七其實本來就沒有要求醫院的要素

02:18:33 - 02:18:35
可是食物就第一個把它理解錯了

02:18:35 - 02:18:37
覺得227有醫院的要素

02:18:37 - 02:18:39
拗不了27嘛,怎麼辦

02:18:39 - 02:18:41
食物不可能讓這種人無罪啊

02:18:41 - 02:18:43
所以他們就只好硬拗

02:18:43 - 02:18:46
說未滿七歲,不管怎麼樣呢,你就是在違反他的意願

02:18:47 - 02:18:47
他就這樣來的

02:18:49 - 02:18:53
好,所以這個就是997的決議,他做成的

02:18:54 - 02:18:56
背景,還有他的操作

02:18:56 - 02:18:57
所以我們來看黑板喔

02:18:58 - 02:18:59
上面這一段，他說

02:18:59 - 02:19:00
只要

02:19:00 - 02:19:04
被害人未滿七歲，不管行為人，他用的是什麼手段

02:19:04 - 02:19:05
有沒有違反意願

02:19:05 - 02:19:06
一律都論

02:19:06 - 02:19:07
第一項第二款

02:19:08 - 02:19:11
上面的部分，百分之百違反罪刑法定

02:19:12 - 02:19:13
你有沒有想過七歲怎麼來的

02:19:14 - 02:19:16
我們刑法當中有七歲這個門檻嗎

02:19:16 - 02:19:16
沒有對不對

02:19:16 - 02:19:17
七歲怎麼來的

02:19:18 - 02:19:20
食物竟然說是永眠法的行為能力

02:19:21 - 02:19:22
很莫名對吧

02:19:22 - 02:19:23
這乾性為什麼事

02:19:23 - 02:19:24
所以上面這[redacted]段有問題

02:19:25 - 02:19:26
來，那下面這一段呢

02:19:27 - 02:19:30
被害人滿七歲而未滿14歲的情形

02:19:30 - 02:19:32
情形，食物是說看合意或非合意

02:19:33 - 02:19:35
下面這一段原本看起來好像沒有什麼問題

02:19:36 - 02:19:38
可是我跟你說，下面這一段一樣有問題

02:19:40 - 02:19:41
221啊

02:19:41 - 02:19:42
你可以說他叫做強制性交

02:19:43 - 02:19:45
你也可以說他叫違反月性交

02:19:45 - 02:19:47
但你不可以說221叫非合意性交啦,不行啦

02:19:49 - 02:19:52
因為如果你說221是非合意的話

02:19:53 - 02:19:54
非合意是民法的概念喔

02:19:55 - 02:19:57
雙方意思表示沒有完全合致

02:19:57 - 02:19:58
那就是非合意喔

02:19:59 - 02:19:59
所以

02:20:00 - 02:20:01
如果信託的雙方,比如說,

02:20:03 - 02:20:05
大學生跟他念國中的女朋友交往,

02:20:06 - 02:20:11
女生以為打炮之後,男生就會買最新的iPhone給她,

02:20:11 - 02:20:13
女生是這樣片面以為,

02:20:13 - 02:20:14
而男生根本沒有這個意思,

02:20:15 - 02:20:16
這是不是也是一種意思表示錯誤?

02:20:17 - 02:20:19
所以你要說這個叫非合意嗎？

02:20:19 - 02:20:21
你懂我的意思吧？非合意那個是民法的概念。

02:20:22 - 02:20:27
所以實務見解，它不但把上面這種情況，莫名其妙地你視為222。

02:20:28 - 02:20:33
下面這種情況，實務其實也是很不敏銳地在視你為222。

02:20:34 - 02:20:37
因為有些情況，他就只是雙方意思表示沒有合致而已。

02:20:37 - 02:20:43
而這種情況,如果真的你照這個字面的意思,它也會變成是加重強制性交喔,

02:20:44 - 02:20:45
這問題還蠻嚴重的喔,

02:20:46 - 02:20:53
所以我講喔,這個食物見解,不管是上面的部分,還是下面的部分,它都有罪刑法定上面的問題,

02:20:54 - 02:20:58
上面的部分是你不管被害人的意願怎麼樣都你自說是222,這個有問題,

02:20:58 - 02:21:01
而下面呢,他都偷錯換法律的概念,

02:21:01 - 02:21:04
他把原本的違法行為,變成似是而非合意,

02:21:04 - 02:21:06
所以這個是這個食物見解的問題,

02:21:07 - 02:21:09
好,那你說所以應該怎麼論罪好,

02:21:09 - 02:21:13
多數說會覺得,這邊就應該論227,

02:21:14 - 02:21:15
因為我們就說嘛,

02:21:15 - 02:21:16
原本的道理很簡單，

02:21:17 - 02:21:19
跟未滿14歲的人發生性關係，

02:21:20 - 02:21:22
最基本的條文，就是227，

02:21:23 - 02:21:25
227，並沒有任何疑慮的要素，

02:21:26 - 02:21:28
所以最基本我們一定會論227。

02:21:29 - 02:21:30
再來,

02:21:30 - 02:21:33
那如果有證據證明行為人違反被害人的意願的話,

02:21:33 - 02:21:36
那就再升級變成222,

02:21:36 - 02:21:38
原本不就這麼簡單嗎,對不對,

02:21:38 - 02:21:40
原本一個很基本沒有爭議的法律問題,

02:21:41 - 02:21:43
被最高法院搞成有爭議,

02:21:43 - 02:21:44
搞得那麼複雜，根本就不必要嘛。

02:21:44 - 02:21:49
所以學者會認為說，這種案例呢，我們直接論227就好了。

02:21:49 - 02:21:52
那再來另外一說是論225，

02:21:53 - 02:21:55
這一說你們不記得沒有關係。

02:21:55 - 02:21:57
因為主張這一說的老師後來也都退休了,

02:21:58 - 02:22:00
這個225這一說是當初,

02:22:00 - 02:22:01
997決議的定說,

02:22:02 - 02:22:03
那我可以跟你們說啦,

02:22:04 - 02:22:07
如果我以前碩論不是寫這一條的話，我根本不會注意到這一說。

02:22:08 - 02:22:11
那只是因為我以前碩論寫這個條文，所以我才對這一說有特別的留意。

02:22:12 - 02:22:12
就是，

02:22:12 - 02:22:21
像之前林東茂老師還有鄭逸哲老師，他們是認為說性侵無意思能力的嬰幼兒，可以論225的犯罪。

02:22:21 - 02:22:22
有這個說法，

02:22:22 - 02:22:24
但這兩位老師後來都退休了。

02:22:24 - 02:22:27
林老師退休了嘛，鄭老師是今年寒假已經退休了，

02:22:27 - 02:22:30
所以現在在學界應該沒有人主張這一說。

02:22:31 - 02:22:36
反而現在在學界，學者普遍不會認為說要用225來處理這種問題。

02:22:37 - 02:22:39
因為像許澤天老師講得很簡單，

02:22:39 - 02:22:43
性侵嬰幼兒，法條文義最符合的是哪一條？

02:22:44 - 02:22:45
就227啊，對不對？

02:22:46 - 02:22:49
那你有227不用，你為什麼要捨近求遠去論225？

02:22:50 - 02:22:53
把225用在性侵嬰幼兒的情形，

02:22:53 - 02:22:55
不是說絕對說不通啦。

02:22:56 - 02:23:01
因為嬰幼兒你要說他是精神身體障礙或心智缺陷，不知或不能抗拒。

02:23:01 - 02:23:01
OK,

02:23:02 - 02:23:04
勉強說得通，文意上可能過得去，

02:23:04 - 02:23:05
可是有227你為什麼不用？

02:23:06 - 02:23:08
你為什麼要捨近求遠去用那個225，對不對？

02:23:08 - 02:23:14
所以，多數認為，這種性侵嬰幼兒的案例，我們回歸227就好了。

02:23:14 - 02:23:19
不要去論222，那個違反罪刑法定，也不要去論225，因為沒有必要。

02:23:19 - 02:23:21
所以多數說的主張大概是這樣子。

02:23:22 - 02:23:25
好，所以這個999決議啊，我們大概就看到這邊。

02:23:25 - 02:23:30
後面結合犯、加重結果犯，這個我們就不再特別去論了，這本來準備去講的。

02:23:30 - 02:23:32
好，我們拿出題本來看一下。

02:23:52 - 02:23:55
71頁的第一題，我們上一次是不是有講過？

02:23:56 - 02:23:56
有齁，對不對？

02:23:57 - 02:23:57
第一題我們講過，

02:23:58 - 02:23:58
來看到第二題。

02:23:59 - 02:23:59
71

02:24:00 - 02:24:01
70頁第二題，我們來看一下。

02:24:26 - 02:24:27
70頁第二題，

02:24:27 - 02:24:29
有沒有感覺那個事實很熟悉啊？

02:24:30 - 02:24:31
朱學恆啊。

02:24:32 - 02:24:33
對啊，就朱學恆啊。

02:24:33 - 02:24:34
你們去搜尋新聞,

02:24:34 - 02:24:36
朱學恆強吻那個叫誰?

02:24:36 - 02:24:37
朱,

02:24:37 - 02:24:39
那個鍾沛君吧,好像是一個議員還是誰。

02:24:40 - 02:24:40
就那個事情啊。

02:24:41 - 02:24:44
朱學恆後來被爆出有這件事。

02:24:44 - 02:24:47
然後我記得他還去地檢署那邊自首。

02:24:48 - 02:24:50
自首說他強制猥褻。

02:24:50 - 02:24:51
後來真的就去關了。

02:24:52 - 02:24:53
對，就很莫名其妙。

02:24:53 - 02:24:54
我覺得他盤算錯了啦。

02:24:55 - 02:24:58
朱學恆當初可能是篤定說被害人沒有去提告。

02:24:59 - 02:25:00
然後性騷擾是告訴乃論，

02:25:00 - 02:25:02
早就過告訴期限。

02:25:02 - 02:25:04
可是事實是被害人有去提告。

02:25:05 - 02:25:06
所以朱學恆後來去自首,

02:25:06 - 02:25:07
反而自投羅網。

02:25:07 - 02:25:09
後來真的被判那個強制猥褻,

02:25:09 - 02:25:10
然後後來就去關了。

02:25:11 - 02:25:12
這件事，我們看一下。

02:25:13 - 02:25:14
包廂內只有A。

02:25:15 - 02:25:16
他強吻A女的嘴唇。

02:25:16 - 02:25:19
A女轉頭挪動才停止。

02:25:19 - 02:25:22
所以前面這一段看起來比較像偷襲啦，

02:25:22 - 02:25:22
我覺得。

02:25:23 - 02:25:24
前面比較像偷襲。

02:25:24 - 02:25:25
所以前面的偷襲呢,

02:25:25 - 02:25:29
論的是性騷擾防治法第25條的那個性騷擾罪。

02:25:31 - 02:25:32
好,然後後面。

02:25:34 - 02:25:35
之後,甲男見A,

02:25:35 - 02:25:36
呆坐不知所措。

02:25:37 - 02:25:40
再次不顧A女撇頭的舉止。

02:25:40 - 02:25:43
強行舌吻，碰觸A女的嘴唇得逞。

02:25:43 - 02:25:44
所以後面論什麼罪？

02:25:45 - 02:25:46
強制猥褻？

02:25:46 - 02:25:47
懂嗎？

02:25:47 - 02:25:48
前面是性騷擾，

02:25:48 - 02:25:49
後面是強制猥褻。

02:25:50 - 02:25:52
這很明顯是兩個不同犯意喔。

02:25:53 - 02:25:54
所以我們要怎麼競合？

02:25:55 - 02:25:56
數罪併罰喔。

02:25:57 - 02:25:58
你不能說這個是，

02:25:58 - 02:26:00
你不能說這個是不罰的。

02:26:00 - 02:26:00
前行為不行喔，因為有些人可能會想說，都是同一個女生的同一個性自主，

02:26:05 - 02:26:07
那難道不是不法的前行為嗎？

02:26:07 - 02:26:08
你不能這樣講喔。

02:26:08 - 02:26:11
我們講的，當行為人以這個

02:26:12 - 02:26:15
複數行為侵害被害人的一身專屬法益的時候，

02:26:16 - 02:26:18
那你要認為那個是不同法益喔。

02:26:18 - 02:26:22
不然如果你說這種情況就直接不法前行為的話，

02:26:23 - 02:26:26
那是不是後面強吻第三次第四次第五次第六次都是同一個法益？

02:26:27 - 02:26:29
那這樣是不是侵害一次就得到免死金牌了？

02:26:29 - 02:26:30
不可能啊。

02:26:30 - 02:26:30
對不對？

02:26:30 - 02:26:35
所以這裡的話呢，我們要認為它是一個數罪併罰的案件喔。

02:26:36 - 02:26:37
好，這題是這樣。

02:26:38 - 02:26:39
然後接下來第五題。

02:26:39 - 02:26:40
第五題我們來看一下。

02:26:57 - 02:26:58
好，第五題喔。

02:27:00 - 02:27:00
我們看一下喔。

02:27:01 - 02:27:02
題目有點長。

02:27:04 - 02:27:07
監護人跟被監護的未成年人發生的性關係。

02:27:08 - 02:27:10
第一次的時候啊，

02:27:10 - 02:27:11
是交換條件，

02:27:11 - 02:27:12
買奢侈品。

02:27:13 - 02:27:15
第二次兩個人變成男女朋友，

02:27:16 - 02:27:17
又去性交。

02:27:17 - 02:27:18
好，我們看喔。

02:27:19 - 02:27:20
第一次的部分對什麼罪？

02:27:22 - 02:27:23
228，應該沒有疑問吧。

02:27:23 - 02:27:24
利用嘛，對不對？

02:27:24 - 02:27:27
所以第一次的部分呢，它是一個非常典型的二八，這個比較沒有疑問。

02:27:29 - 02:27:30
第二次呢？

02:27:32 - 02:27:33
第二次兩個人變男女朋友喔。

02:27:35 - 02:27:36
這個是一個考點。

02:27:37 - 02:27:37
是這樣喔。

02:27:38 - 02:27:41
監護人跟被監護的未成年人之間，

02:27:41 - 02:27:42
他們有權勢關係，

02:27:43 - 02:27:47
而且監護人跟被監護人之間他們的生活關係是很親密的，

02:27:47 - 02:27:50
所以通常不會要求性行為跟具體事物要連結。

02:27:51 - 02:27:52
所以第一次一定成立嗎？

02:27:52 - 02:27:53
沒有疑問。

02:27:53 - 02:27:54
重點是第二次。

02:27:55 - 02:27:57
第二次我們還可以認為他們是濫用權勢嗎？

02:27:57 - 02:27:58
那你要想喔！

02:27:58 - 02:28:00
第二次的性情

02:28:00 - 02:28:04
行為人跟被害人之間確實有這個法律關係存在,沒有錯。

02:28:05 - 02:28:06
可是他們變成男女朋友了。

02:28:07 - 02:28:08
他們變成男女朋友之後。

02:28:09 - 02:28:13
你覺得他們的互動模式還會像一般的上對下的關係嗎?

02:28:14 - 02:28:15
應該不會對吧？

02:28:15 - 02:28:15
就好像你想的嘛。

02:28:16 - 02:28:19
如果大學教授跟他指導的女研究生變成情侶關係的話。

02:28:20 - 02:28:22
他們還會用師生的模式在互動嗎？

02:28:23 - 02:28:24
一定不可能，對吧？

02:28:24 - 02:28:25
一定不可能。

02:28:25 - 02:28:28
所以這樣的情況到了後面的一次，我們會說啊。

02:28:28 - 02:28:31
雖然法律上的權勢關係還在。

02:28:31 - 02:28:33
可是因為他們已經變成男女朋友關係了。

02:28:33 - 02:28:37
所以事實上來說，他們的地位已經相對趨於平等。

02:28:37 - 02:28:41
所以這個時候呢,很難再說行為人有濫用他的權勢關係。

02:28:41 - 02:28:43
所以第二次的話呢,應該不算，好嗎？

02:28:43 - 02:28:44
第二次應該不算。

02:28:47 - 02:28:48
好，結果後面啊，他很生氣嘛。

02:28:49 - 02:28:56
他就謊稱自己遭居家附近傳聞已久但尚未落網的蒙面狼性侵。

02:28:57 - 02:28:57
所以怎麼論罪？

02:28:58 - 02:28:59
來，後面那個叫誣告。

02:29:00 - 02:29:02
這個是有指定犯人還是未指定犯人？

02:29:03 - 02:29:05
我們講什麼叫做有指定。

02:29:06 - 02:29:07
講特徵就可以囉。

02:29:07 - 02:29:08
那什麼叫未指定？

02:29:09 - 02:29:12
沒有講特徵，或者是他講的根本是一個不存在的人。

02:29:13 - 02:29:14
我以前舉過例子嘛。

02:29:14 - 02:29:15
我說啊。

02:29:15 - 02:29:20
如果我去報案，我說我在補習班的教室被性侵犯。

02:29:20 - 02:29:24
然後我說呢，性侵我的人是誰，我沒有看清楚臉孔。

02:29:25 - 02:29:26
但我確定他是個男性。

02:29:27 - 02:29:28
這個男性啊。

02:29:28 - 02:29:30
他穿著襯衫。

02:29:30 - 02:29:33
穿著西裝褲，穿著西裝外套。

02:29:33 - 02:29:35
帶著細框的金屬眼鏡。

02:29:36 - 02:29:37
身材偏瘦。

02:29:37 - 02:29:38
而且呢，他是個光頭。

02:29:39 - 02:29:39
有沒有指定？

02:29:40 - 02:29:41
腦中我們畫面是誰，有嗎，對不對？

02:29:41 - 02:29:42
當然有指定啊，所以這題也是啊。

02:29:43 - 02:29:44
蒙面狼。

02:29:45 - 02:29:47
而且好像真的有這個人喔。

02:29:47 - 02:29:49
所以這題是有指定喔，這題不是未指定喔。

02:29:51 - 02:29:52
好，這題我們看到這邊。

02:29:54 - 02:29:55
然後，看一下喔。

02:30:02 - 02:30:04
74頁的11題。

02:30:05 - 02:30:06
看過了嗎？

02:30:07 - 02:30:08
74頁11題。

02:30:08 - 02:30:09
沒有啊，我們來看一下這一題。

02:30:46 - 02:30:51
好，這一題當中啊，假算不算是，有脅迫？

02:30:52 - 02:30:54
我們講脅迫是什麼？

02:30:54 - 02:30:54
惡害的告知，對不對？

02:30:55 - 02:30:58
所以這一題假的意思是說，你不跟我打砲的話，我就要自殺喔。

02:30:59 - 02:31:00
對，他是脅迫。

02:31:00 - 02:31:02
有做，重點是它有沒有違反被害人的意願。

02:31:04 - 02:31:06
這個例子，我記得我上禮拜口頭有舉過吧。

02:31:07 - 02:31:07
我講一個。

02:31:07 - 02:31:13
我說如果一古跟我說，你不幫我吹喇叭的話，我就從九樓跳，九樓跳下去，我死給你看喔。

02:31:15 - 02:31:16
假設我妥協了。

02:31:16 - 02:31:18
你會說一古違反我的意願嗎？

02:31:19 - 02:31:20
當然會有兩種不同的說法嘛。

02:31:21 - 02:31:24
一種說法會覺得說，對啊，我的意思被他影響了啊。

02:31:24 - 02:31:25
我原本不會想做啊。

02:31:26 - 02:31:27
是他這樣子我才做的啊。

02:31:27 - 02:31:29
我的意思被他影響了啊。

02:31:29 - 02:31:29
所以他違揹我的意願。

02:31:30 - 02:31:31
這是一種說法嘛，對不對？

02:31:32 - 02:31:33
當然反過來你也可以說。

02:31:34 - 02:31:35
那你也可以不妥協啊。

02:31:35 - 02:31:37
不妥協就他去死啊，幹你屁事啊。

02:31:38 - 02:31:39
這也是一種說法嘛。

02:31:39 - 02:31:40
所以我們就會講啊。

02:31:40 - 02:31:42
到底什麼是脅迫而違反意願？

02:31:43 - 02:31:44
有一種說法是寬鬆認定。

02:31:45 - 02:31:46
只要被害的意思有影響，這個就算。

02:31:47 - 02:31:49
而另外一種說法是呢？

02:31:50 - 02:31:51
另外一種說法是

02:31:52 - 02:31:55
必須要是一個生命身體上的現實惡害。

02:31:55 - 02:31:57
而且要是被害人本人生命身體喔。

02:31:58 - 02:31:59
這才稱得上是行為人。

02:32:00 - 02:32:01
要違反被害人的意願。

02:32:02 - 02:32:06
還記得吧，兩說不同的看法，這個我們前面都看過了哈，所以這一題就在考這個東西。

02:32:06 - 02:32:07
所以這一題啊，

02:32:07 - 02:32:09
如果採像蔡聖偉老師

02:32:09 - 02:32:11
或許澤天老師的看法，

02:32:11 - 02:32:12
認為說，要被害人本人的

02:32:12 - 02:32:14
生命、身體、性是惡害，

02:32:14 - 02:32:17
才稱得上是違反被害人的意願。

02:32:17 - 02:32:19
如果我們採取這樣的說法的話。

02:32:20 - 02:32:21
那221不能成立嘛。

02:32:22 - 02:32:24
所以這一題只剩什麼？

02:32:24 - 02:32:25
304。

02:32:25 - 02:32:26
知道嗎？只剩304。

02:32:26 - 02:32:32
那有人會問說，304的話，難道不會有剛剛那個違反要件的問題嗎？

02:32:32 - 02:32:33
還真的不會。

02:32:34 - 02:32:35
因為304沒有寫違反意願。

02:32:36 - 02:32:39
304是你強暴脅迫使人為違背意願的作為容忍或不作為，那就算，瞭解嗎？

02:32:40 - 02:32:43
所以這一題當中，就算221不成立。

02:32:43 - 02:32:45
行為也不會無罪。

02:32:45 - 02:32:47
還是可以論304，知道嗎？還是可以論304。

02:32:47 - 02:32:49
一般的器具。

02:32:57 - 02:32:58
好，大概是這樣子喔。

02:32:59 - 02:33:00
其他的，看一下。

02:33:02 - 02:33:03
好了，大概是這樣，OK。

02:33:03 - 02:33:05
那我們就先上到這邊吧。

02:33:06 - 02:33:07
提早個幾分鐘。

02:33:07 - 02:33:07
剛好也到一個段落，我們就先到這邊。

02:33:09 - 02:33:11
下午的話呢，我們再講這個謎域跟隱私的犯罪囉。